دولة ماليزيا
وزارة التعليم العالي (MoHE)
جامعة المدينة العالمية
كلية العلوم الإسلامية – قسم الفقه وأصول

نظام العقوبات في الصومال (القتل السرقة الزنا)

دراسة وصفية تحليلية في ضوء الشريعة الإسلامية

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة (الماجستير) في القضاء والسياسة الشرعية

اسم الباحثة: صفية محمد محمود

الرقم الجامعي:MQD121AU850

تحت إشراف:

الأستاذ المشارك الدكتور موسى عمر كيتا

كلية العلوم الإسلاميه – قسم الفقه و أصوله

١٤٣٤٥\٢٠١٣م



APPROVAL PAGE: صفحة الإقرار

أقرت جامعة المدينة العالمية بماليزيا بحث الطالب _____

من الآتية أسماؤهم:

The dissertation has been approved by the following:

_____

Supervisor **المشرف**

_____

Internal Examiner **الممتحن الداخلي**

_____

External Examiner **الممتحن الخارجي**

_____

Chairman **رئيس لجنة المناقشة**

إقرار

أقررتُ بأنّ هذا البحث من عملي الخاص، قمتُ بجمعه ودراسته، والنقل والاقتباس من المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع البحث.

اسم الطالب : ----------.

التوقيع : ----------

التاريخ : ----------

DECLARATION

I herby declare that this dissertation is result of my own investigation, except where otherwise stated.

. ----------Name of student**:**

Signature: ----------

Date: ----------

جامعة المدينة العالمية

إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية الأبحاث العلمية غير المنشورة

حقوق الطبع ٢٠١٤ © محفوظة

اسم الباحث هنا

عنوان الرسالة هنا

لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أيّ شكل أو صورة من دون إذن المكتوب من الباحث إلاّ في الحالات الآتية:

١-يمكن الاقتباس من هذا البحث والغزو منه بشرط إشارة إليه.

٢-يحق لجامعة المدينة العالمية ماليزيا الاستفادة من هذا البحث بمختلف الطرق وذلك لأغراض تعليمية، وليس لأغراض تجارية أو تسوقية.

٣-يحق لمكتبة الجامعة العالمية بماليزيا استخراج النسخ من هذا البحث غير المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات، ومراكز البحوث الأخرى.

أكدّ هذا الإقرار :----------.

التوقيع:---------- التاريخ: ----------

--

الاستهلال

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾ ﴾ البقرة: ١٧٩

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ ﴿١٨٧﴾ ﴾ البقرة: ١٨٧

الإهداء

إلى والدتي التي وهبتني الحب والحنان،أمي الغالية التي لولاها –بعد الله عز وجل- لما وصلت هذه المرحلة، لقدصبرت وعانت كثيراً لفراق ابنتها لمواصلة الدراسة.

إلى والدي العزيز الذي سهر الليالي ليوفر لنا العيشة والرفاهية أسأل الله أن يجمعني وإياهم في الفردوس الأعلى.

إلى زوجي الحبيب الحنون الغالي الذي وقف معي في كل اللحظات ودعمني ماديا ومعنويا، ووفرلي الجو المناسب لإعداد هذا البحث يارب اجعله في ميزان حسناته.

إلى إخواني وأخواتي.

إليكم جميعا أهدي عصارة جهدي.

الملخص

هذا البحث عبارة عن دراسة وصفية تحليلية لجرائم القتل والسرقة والزنا وعقوباتها في القانون الصومالي مقارنة بالشريعة الإسلامية من حيث الموافقة والمخالفة، ذلك لأن الصومال دولة مسلمة بشعبها، ودينها الرسمي الإسلام كما نص على ذلك دستورها، مما يُفترض أن تكون قوانينُها وأنظمتُها ودستورُها مستقاةً من الشريعة الإسلامية، إلاّ أن الواقع جاء على خلاف هذا الفرض، وقد قامت الباحثة بتقسيم البحث إلى مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، لتتناول المقدمةُ الافتتاحيةَ بأهمية البحث، ومشكلة البحث، وأهداف البحث، والدراسات السابقة، والمنهج المتبع في البحث، وجاء في الفصل الأول المواد المتعلقة بالقتل، كما احتوى الفصل الثاني على المواد المتعلقة بالسرقة، واشتمل الفصل الثالث على المواد المتعلقة بالزنا، واتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي، حيث جمعت المتعلقة بكل من القتل والسرقة والزنا، ومن ثم تحليل تلك المواد وذلك بتكييفها في الشريعة الإسلامية، ثم مقارنة العقوبة الواردة فيه بالشريعة لمعرفة الموافقة والمخالفة، وقد توصلت الباحثة إلى أن القانون الصومالي لم تكن الشريعة هي مصدره ومستمده، على الرغم من كون دين الدولة هو الإسلام، وإنما كان استمداده من القوانين الوضعية التي لا تراعي تعليمات الدين أو العرف عند صياغة موادها، وأوصت الباحثة بضرورة اهتمام الباحثين بما تبقى من مواد القانون، وتناولهم إياها بالبحث والتحليل واقتراح البديل الشرعي لموادها.

ABSTRACT

This research is a descriptive and analysis study on the homicide, theft, adultery and their penalties in the Somali law compared to Islamic law, in terms of the approval, and the violation, because the people of Somalia, are Muslims, and the official religion is Islam as stipulated in the Constitution, which requires that the laws, regulations and constitution derived from Islamic law , but the reality was otherwise this hypothesis, and the researcher dividing the search to the introduction, three chapters and a conclusion, the introduction contained the opening speech on the importance of research, research problem, research objectives, and previous studies, the approach taken in the search, and came in the first chapter articles relating to homicide, the second chapter bears articles relating to theft, and the last chapter studied the articles related to adultery, the researcher has followed the inductive, descriptive and analytical approach, she collected all the articles related to the homicide, theft and adultery, and then analyze these articles and then compared the penalty contained therein Sharia to discover the approval and the violation, the research has concluded that the Somali law despite the fact that the state religion is Islam were not based on Shari'a law as a source, but was derived from statutory law that do not take into account the instructions of religion or custom when drafting articles, and researcher recommended the researchers from Somalia should be interested in the rest of the articles of the criminal law , in terms of study, analysis and critics, then propose a legitimate alternative to its articles.

الشكر والتقدير

أشكر الله تعالى على أن وفّقني لإكمال هذه الرسالة في تخصص القضاء والسياسة الشرعية بقسم الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية راجية منه المزيد كما وعد بذلك في قوله: ﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ ﴾ [1].

ثم أشكر فضيلة الأستاذ المشارك الدكتور موسى عمر كيتا الذي أشرف على هذه الرسالة، فلم يأل جهداً في تقديم توجيهاته القيمة، وإرشاداته الجليلة التي أوضحت لي الطرق، وأنارت لي السبل لكتابة البحث العلمي والاستفادة من المصادر والمراجع العلمية حتّ شقّ هذا البحث طريقه إلى الوجود، أسأل الله تعالى أن يبارك في عمره وعلمه وعمله، وأن يجعله ذخراً للإسلام والمسلمين، وينفع بعلمه الأمة الإسلامية إنه سميع مجيب الدعوات.

وأخيرا أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذه الجامعة المباركة مديرا وعمداء وأساتذة وطلابا، وأخص بالذكر سعادة عميد الدراسات العليا الأستاذ المشارك الدكتور دوكوري ماسيري، وفضيلة عميد كلية العلوم الإسلامية الدكتور مهدي عبد العزيز، وفضيلة رئيس قسم الفقه وأصوله الأستاذ المساعد الدكتور محمد بن سعيد مجاهد، والأستاذ عبد الصمد دوكوري، وكلَّ من أعانني برأي أو دلني على مصدر من مصادر البحث، سائلة المولى أن يجزي الكل خيرا.

---

(١) سورة إبراهيم، الآية ٧.

فهرس موضوعات البحث:

ت	الموضوع	الصفحة
١	صفحة البسملة	أ
	صفحة توصية وتوقيعات لجنة المناقشة	ب
٢	الاستهلال	د
٣	الإهداء	٤
٤	الملخص	٥
٥	Abstract	6
٦	الشكر والتقدير	٧
٧	فهرس موضوعات البحث	٨
٨	المقدمة	1
٩	مشكلة البحث	3
١٠	أهداف البحث	4
١٢	الدراسات السابقة	4
١٣	منهج البحث	4
١٤	هيكل البحث	5
١٥	تقسيمات البحث	5
١٦	الفصل التمهيدي:نظرة عامة عن الصومال،وبيان معاني مصطلحات البحث	9
١٧	المبحث الأول:تعريف موجز لدولة الصومال	9
١٨	المطلب الأول: الاسم، وبيان أصل كلمة (الصومال)	9
١٩	المطلب الثاني: الموقع الجغرافي، وتعداد السكان، والمساحة	15
٢٠	أولا: الموقع الجقرافي	15
٢١	ثانيا: تعداد السكان	16
٢٢	المطلب الثالث: اللغة واللهجات والديانة	16

٢٣	أولا: اللغة واللهجات	16
٢٤	ثانيا: الديانة، والمذهب	18
٢٥	المطلب الرابع: نظام القانون	18
٢٦	الطبقة الأولى: الشريعةالإسلامية	19
٢٧	الطبقة الثانية:القانون المدني	19
٢٨	الطبقة الثالثة: القانون العشائري (حير)	21
٢٩	المبحث الثاني:بيان معاني مصطلحات البحث	22
٣٠	المطلب الأول: تعريف القانون، والنظام، والعقوبة، والجناية، ومفهوم نظام العقوبات الجنائية	22
٣١	أولا: القانون: لغة واصطلاحا	22
٣٢	ثانيا: النظام لغة واصطلاحا	23
٣٣	ثالثا: العقوبة لغة واصطلاحا	23
٣٤	رابعا: الجناية لغة واصطلاحا	24
٣٥	خامسا: مفهوم النظام العقوبات الجنائية	24
٣٦	المطلب الثاني: تعريف القتل، والسرقة، والزنا في اللغة	24
٣٧	أولا: القتل لغة	24
٣٨	ثانيا: السرقة لغة	26
٣٩	ثالثا: الزنا لغة	26
٤٠	الفصل الأول: القتل وعقوبته فى نظام العقوبات الجنائية الصومالي	28
٤١	التوطئة في بيان ما يتعلق بالقتل من أحكام في الفقه الإسلامي، وسرد المواد المتعلقة بالقتل في نظام العقوبات الجنائية الصومالي	28
٤٢	الفرع الأول: بيان ما يتعلق بالقتل من أحكام في الفقه الإسلامي	28
٤٣	أولا: تعريف القتل في الفقه الإسلامي	28
٤٤	ثانيا: بيان أنواع القتل	29
٤٥	ثالثا: حكم ودليل كل نوع من أنواع القتل الثلاثة	37

٤٦	القسم الأول: القتل العمد:تحريم القتل العمد في الكتاب والسنة	37
٤٧	عقوبته في الشريعة الإسلامية	38
٤٨	القسم الثاني: القتل شبه العمد	43
٤٩	تعريف القتل شبه العمد	43
٥٠	عقوبات القتل شبه العمد	44
٥١	القسم الثالث: القتل الخطأ	45
٥٢	تعريف القتل الخطأ	45
٥٣	الأصل في عقوبة القتل الخطأ	45
٥٤	عقوبات القتل الخطأ	46
٥٥	الفرع الثاني: سرد المواد المتعلقة بالقتل في نظام العقوبات الجنائية الصومالي	46
٥٦	المبحث الأول: المواد المتعلقة بالقتل العمد	52
٥٧	المطلب الأول: المادة ٤٣٤	52
٥٨	أولا: نص المادة	52
٥٩	ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة	52
٦٠	ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة	52
٦١	المطلب الثاني: المادة ٤٣٥ قتل الأبناء دفاعا عن الشرف	55
٦٢	أولا: نص المادة	55
٦٣	ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة	55
٦٤	ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة	56
٦٥	المطلب الثالث: المادة ٤٣٦ التسبب في موت شخص برضائه	57
٦٦	أولا: نص المادة	57
٦٧	ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة	57

٦٨	ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة	60
٦٩	المبحث الثاني: القتل الخطأ	64
٧٠	المطلب الأول: المادة ٤٤١	64
٧١	أولا: نص المادة	64
٧٢	ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة للمادة	65
٧٣	ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقةوالمخالفة	66
٧٤	المطلب الثاني: المادة ٤٤٣ القتل أو الإصابة دفاعا عن الشرف:	67
٧٥	أولا: نص المادة	67
٧٦	ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة:	67
٧٧	ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة المافقة والمخالفة	68
٧٨	المطلب الثالث: المادة ٤٤٥	71
٧٩	أولا: نص المادة	71
٨٠	ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة	71
٨١	ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة	75
٨٢	الخلاصة:	77
٨٣	الفصل الثاني: السرقة وعقوباتها في القانون الصومالي	83
٨٤	التوطئة: في بيان ما يتعلق بالسرقة من أحكام في الفقه الإسلامي، وسرد المواد المتعلقة بالسرقة في نظام العقوبات الجنائية الصومالي	83
٨٥	الفرع الأول: بيان ما يتعلق بالسرقة من أحكام في الفقه الإسلامي	83
٨٦	تعريف السرقة	83
٨٧	أنواع السرقة	85

٨٨	شروط السرقة (أي الشروط التي يجب توفرها في السرقة لإقامة الحد على السارق)	85
٨٩	ما تثبت به السرقة	89
٩٠	عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية	90
٩١	الفرع الثاني: سرد المواد المتعلقة بالسرقة في نظام العقوبات الجنائية الصومالي	91
٩٢	المبحث الأول: مقدمات السرقة	94
٩٣	المطلب الاول: المادة ٤٨١	94
٩٤	أولا: نص المادة	94
٩٥	ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة	94
٩٦	ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة	95
٩٧	المبحث الثاني: المواد المتعلقة بالسرقة نفسها	97
٩٨	المطلب الأول:المادة ٤٨٠	97
٩٩	أولا: نص المادة	97
١٠٠	ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة	97
١٠١	ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة	98
١٠٢	المطلب الثاني: المادة ٤٨١ الظروف المشددة	100
١٠٣	أولا: نص المادة	100
١٠٤	ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة	102
١٠٥	ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية	105
١٠٦	المطلب الثالث: المادة ٤٨٢ السرقة التي يعاقب عليها بناء على الشكوى المجنى عليه	108
١٠٧	أولا: نص المادة	108
١٠٨	ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة	109

١٠٩	ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية	111
١١٠	الخلاصة	117
١١١	الفصل الثالث: الزنا وعقوباتها في القانون الصومالي.	122
١١٢	التوطئة: في بيان ما يتعلق بالزنا من أحكام في الفقه الإسلامي، وسرد المواد المتعلقة بالزنا في نظام العقوبات الجنائية الصومالي	122
١١٣	الفرع الأول: في بيان ما يتعلق بالزنا من أحكام في الفقه الإسلامي	122
١١٤	تعريف الزنا اصطلاحا	122
١١٥	أركان الزنا	128
١١٦	تحريم الزنا	129
١١٧	عقوبة الزنا	130
١١٨	شروط الحد	133
١١٩	الفرع الثاني: سرد المواد المتعلقة بالزنا	136
١٢٠	المبحث الأول: المواد المتعلقة جرائم ضد الأخلاق والآداب العامة	139
١٢١	المطلب الأول:المادة ٣٩٨ العنف الجنسي	139
١٢٢	أولا: نص المادة	139
١٢٣	ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة	139
١٢٤	ثالثا:مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة	141
١٢٥	المطلب الثاني:المادة ٣٩٩	143
١٢٦	أولا: نص المادة	143
١٢٧	ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة	144
١٢٨	ثالثا:مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة	144
١٢٩	المطلب الثالث:المادة ٤٢٦	145

١٣٠	أولا: نص المادة	145
١٣١	ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة	145
١٣٢	ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة	146
١٣٣	المطلب الرابع:مادة ٤٢٧ الزنا بالمحارم	147
١٣٤	أولا: نص المادة	147
١٣٥	ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة	147
١٣٦	ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة	150
١٣٧	المبحث الثاني:جرائم غير الطبيعية ترتكب بالعنف	153
١٣٨	المطلب الأول: المادة ٤٠٠	153
١٣٩	أولا: نص المادة	153
١٤٠	ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في الفقه الإسلامي	153
١٤١	ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة	156
١٤٢	الخلاصة	156
١٤٣	النتائج والتوصيات	162
١٤٤	فهرس الآيات	165
١٤٥	فهرس الأحاديث والآثار	167
١٤٦	المصادر والمراجع	170

المقدمة

الحمد لله الذي شرع العقوبات على الجنايات لتكون رادعة للنفوس الظالمة من الإقبال على الظلم والتعدي، وليعيش خلقه في أمن واستقرار وطمأنينة، فله الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على أفضل من قام بتطبيق شرع الله تعالى المتعلق بالعقوبات، فعم الخيرُ العبادَ والبلادَ، وعاش الناس في رخاء وأمن واستقرار، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فإن حكمة الله تعالى اقتضت أن يشرع لعباده ما يحقق لهم المصالح ويدرأ عنهم المفاسد، ويحفظ عليهم ضرورياتهم الخمس التي لا يتصور عيش بدونها، وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، فشرع لهم ما يحفظ عليهم هذه الضروريات من جانبين:

الجانب الأول: جانب الوجود، وذلك بالأوامر والحث والترغيب، فشرع الأحكام محققة لذلك من واجبات ومندوبات ومباحات.

الجانب الثاني: جانب العدم، وذلك بالنواهي، والترهيب والتخويف، وشرع الأحكام التي تحقق هذا المقصد، من تحريم وكراهة، وحدد العقوبات التي تردع من الإقبال والمِساس والتعدي على شيء من هذه الضروريات، فقضى بقتل المرتد حفاظا على الدين، وشرع القصاص لحفظ النفس، وأوجب رجم الزاني أو جلده لحفظ النسل، وحتّم قطع يد السارق لحفظ المال، وحدّد حد شارب الخمر لحفظ العقل.

ولما كان نظام العقوبات الجنائية في دولة الصومال أمرا يشوبه شيء من الغموض وعدم الشفافية أحيانا وذلك بسبب التطبيقات الخاطئة من بعض من وصلوا إلى الحكم، حيث وسّعوا دائرة إنزال العقوبات على جنايات لا يستحق أصحابها تلك العقوبات، مما حدا بالبعض إلى التشكّك من موافقة النظام الصومالي لشريعة الإسلام، كما أن هناك من يدعي بأن نظام القضاء الصومالي ومنه نظام العقوبات مأخوذ بحذافيره من الشريعة الإسلامية، فأصبح الشعب في حيرة من أمره، لا يدري ما هو وجه الصواب بين هذين الاتجاهين من الخطأ، وكانت الأمانة العلمية تقتضي وتتطلب الكشف والفحص الجاد عن الحقيقة المكمونة في هذا الأمر؛ أرادت الباحثة أن تتناول جانباً من نظام العقوبات في القضاء الصومالي بشيء من الدراسة وصفاً وتحليلاً ومقارنة بالشريعة الإسلامية لمعرفة ما وافق الشريعةَ منه وما خالفها، واقتراحَ العقوبة المناسبة في حال المخالفة، راجيةً من الله تعالى أن ينفع به، وعسى أن يستفيد منه المسؤولون عند إعادة النظر في النظام.

هذا؛ وإن طبيعة البحث العلمي في هذه المرحلة (مرحلة الماجستير) تقيد الباحثة في حدود صفحات وكلمات لا ينبغي تجاوزها، لذلك رأت الباحثة أن تقتصر على جناية القتل والسرقة والزنا كحدود بحثها، لدراسة العقوبات المحددة لكل نوع من أنواع كل واحد من هذه الثلاثة، لتفتح الآفاق لغيرها من الباحثين في تناول ما بقي من نظام العقوبات بالدراسة المماثلة.

وسيتناول البحث الجناية من قتل أو سرقة أو زنى، وأنواعها، ثم شرح ما يحتاج منها إلى شرح وبيان، ثم وصف الجناية وتكييفها وتحليلها، ثم ذكر عقوبتها في النظام الصومالي، ومقارنة تلك العقوبة بما ورد في الشريعة الإسلامية.

وسيستند البحث في كل ذلك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال السّلف والعلماء، وكتب الفقه من المذاهب الأربعة، والكتب الحديثة المؤلفة في مجال القانون والشريعة، فإن كان ما ورد في البحث صوابا فمن الله، وهو من وعد بالمزيد، وإن كان خطأ فمن الباحثة وتسأل الله العفو والمغفرة، وعذرها أنها اجتهدت للوصول إلى الحق، ويرجى ممن وقف على شيء من ذلك التنبيه والتوجيه مشكورا مأجورا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الباحثة: صفيّة محمد

مشكلة البحث

إن إشكاليات هذا البحث تكمن في جوانب عدة، بدءاً من معرفة ماهية العقوبات الجنائية بدولة الصومال، وتحديد الجنايات التي يُستحق بها العقوبات، ومن ثم عرض تلك العقوبات على الشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة، خاصة وأن الأفكار تجاه ذلك النظام وتلك العقوبات متضاربة بين قائل بأن نظام القانون الصومالي في العقوبات الجنائية مأخوذ بحذافيره من الشريعة الإسلامية، فهو مطابق تمامًا لها، وبين قائل أو ظانٍّ بأن قانون العقوبات الجنائية لا صلة لها بالشريعة الإسلامية خاصة بعد وجود حالات طُبِّقت فيها العقوبات الجنائية مخالفة تمامًا للشريعة الإسلامية، مما خلق شكوكًا عند البعض، لذا رأت الباحثة حل تلك الإشكاليات؛ وذلك بتناول ذلك النظام، وتلك العقوبات بالدراسة والتحليل، فبرزت مشكلة وإشكاليات هذا البحث في التساؤلات الآتية:

أسئلة البحث:

١- ما هو مفهوم العقوبات الجنائية فى الشريعة الإسلامية وفي الدستور الصومالي؟

٢- ما هي أنواع الجنايات (القتل، والسرقة، والزنا) وما هي عقوباتهافي القانون الصومالي؟

٣- هل قانون العقوبات الجنائية فى الصومال مطابق للشريعة الإسلامية على اعتبار أن الصومال دولة مسلمة بعدد ساكنيها؟

٤- في حالة كون الجواب لا ولو في بعض الجوانب، فكيف يتم توجيه ذلك واقتراح البديل الشرعي لجوانب المخالفات؟

هذه التساؤلات وغيرها هي التي سيجيب البحث عنها في الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى.

أهداف البحث

تَنصبُّ أهداف البحث على النقاط الآتية:

١- بيان مفهوم العقوبات الجنائية في الشريعة الإسلامية وفي القانون الصومالي.

٢- بيان معرفة أنواع الجنايات (القتل والسرقة والزنا) وعقوباتها في القانون الصومالي.

٣- مقارنة العقوبات الجنائية في القانون الصومالي بالشريعة الإسلامية لمعرفة مدى صلتها وعلاقتها بالشريعة الإسلامية موافقة ومخالفة.

٤- ذكر العقوبات الجنائية المخالفة للشريعة الإسلامية —إن وجدت- واقتراح البديل الشرعي لها.

الدّراسات السابقة

لقد قام الباحثون والكُتّاب بكتابة عدد من البحوث والمؤلفات عن دولة الصومال من جوانب عدة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وأما من ناحية تناول القانون الصومالي عموما ونظام العقوبات الجنائية خصوصاً بالدراسة المتفحصة والنقد والتحليل والمقارنة بالشريعة الإسلامية فلا توجد أي دراسة سابقة في ذلك حسب علم الباحثة بعد البحث والتحري.

منهج البحث

سلكت الباحثة في هذا البحث المنهج الاستقرائي ثم الوصفي فالتحليلي، حيث قامت باستقراء جميع أنواع الجرائم المتعلقة بالقتل، والسرقة، والزنا وعقوباتها، ثم وصف تلك الأنواع وشرحها، وأخيرا تحليلها ومقارنة تلك العقوبات لمعرفة موافقتها للشريعة الإسلامية أو عدم موافقتها لها.

وكان الاعتماد في جمع المادة العلمية على قانون أو نظام العقوبات الجنائية الصومالي، لعلاقة البحث المباشرة بذلك.

كما أن البحث اعتمد في وصف وتكييف وتحليل الجنايات، والجرائم، وعقوباتها، على كتب الفقه العامة والخاصة، وكذلك بعض المواد في الدستور الصومالي عند الحاجة.

وقامت الباحثة كذلك بذكر نوع الجناية كما وردت في النظام، ومن ثم تكييفها في نظر الشريعة، ثم إيراد عقوبتها المحددة لها في نظام العقوبات الجنائية في الصومال، ومقارنة تلك العقوبة بالشريعة الإسلامية.

وفي النهاية قامت الباحثة بتقسيم فصول الكتاب إلى مباحث، والمباحث إلى مطالب، ليتضمن كل مطلب النقاط الآتية:

١- نص مادة القانون ببنودها إن وجدت.

٢- التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة.

٣- مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة.

وأخيرا، وضعت الباحثة في نهاية كل فصل خلاصة للتحليلات والمقارنات.

هيكل البحث:

يتكون البحث من مقدمة، وفصل تمهيدي، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس.

تقسيمات البحث:

المقدمة: وتشتمل على:

أهمية الموضوع.

مشكلة البحث.

أهداف البحث.

الدراسات السابقة.

منهج البحث.

هيكلية البحث.

تقسيمات البحث.

الفصل التمهيدي: نظرة عامة عن الصومال، وبيان معاني مصطلحات البحث.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف موجز لدولة الصومال.

المبحث الثاني: بيان معاني مصطلحات البحث، وفيه مطالب:

المطلب الأول: تعريف القانون، والنظام، والعقوبة، والجناية في اللغة، ومفهوم نظام العقوبات الجنائية.

المطلب الثاني: تعريف القتل، والسرقة، والزنا في اللغة.

الفصل الأول: القتل وعقوباته في القانون الصومالي.

وفيه توطئة ومبحثان، وخلاصة:

التوطئة: في بيان ما يتعلق بالقتل من أحكام في الفقه الإسلامي، وسرد المواد المتعلقة بالقتل في نظام العقوبات الجنائية الصومالي.

المبحث الأول: المواد المتعلقة بالقتل العمد.

المبحث الثاني: المواد المتعلقة بالقتل الخطأ.

الخلاصة: في نتائج التحليلات والمقارنات.

الفصل الثاني: السرقة وعقوباتها في القانون الصومالي.

وفيه توطئة ومبحثان، وخلاصة:

التوطئة: في بيان ما يتعلق بالسرقة من أحكام في الفقه الإسلامي، وسرد المواد المتعلقة بالقتل في نظام العقوبات الجنائية الصومالي.

المبحث الأول: المواد المتعلقة بمقدمات السرقة.

المبحث الثاني: المواد المتعلقة بالسرقة نفسها.

الخلاصة: في نتائج التحليلات والمقارنات.

الفصل الثالث: الزنا وعقوباتها في القانون الصومالي.

وفيه توطئة ومبحثان، وخلاصة:

التوطئة: في بيان ما يتعلق بالزنا من أحكام في الفقه الإسلامي، وسرد المواد المتعلقة بالقتل في نظام العقوبات الجنائية الصومالي.

المبحث الأول: في المواد المتعلقة بجرائم الأخلاق والآداب العامة.

المبحث الثاني: في المواد المتعلقة بالجرائم غير الطبيعية.

الخلاصة: في نتائج التحليلات والمقارنات.

الخاتمة: وتشتمل على

أهم النتائج التي توصل إليها البحث، والتوصيات.

الفهارس العلمية.

الفصل التمهيدي: نظرة عامة عن الصومال،وبيان معاني مصطلحات البحث.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف موجز لدولة الصومال.

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الاسم وأصل كلمة الصومال

أولا: الاسم:

الصومال معروف باسم جمهورية الصومال الديمقراطية، وعاصمتها مقديشو، وقد أخذت استقلالها عام ١٩٦٠م.

ثانيا: بيان أصل كلمة "الصومال"

وأما أصل كلمة "الصومال" فقد تباينت آراء الباحثين حول ذلك حتى وصلت إلى ثمانية آراء،"وأغلب هذه الآراء اعتمدت على التفسيرات اللغوية والتأويلات اللفظية التي غالباً ما يلجأ إليها الناس لمعرفة ما أشكل عليهم من معاني الكلمات، كما أنه من الممكن القول بأن هذه التفسيرات لم تستند إلى أدلة تاريخية يمكن الاعتماد عليها و لم ترتكز على أسس علمية منطقية يمكن قبولها، وفي الغالب فإن مصدر هذه الآراء هو الروايات الشفهية المتداولة وسط الصوماليين أو خيال الباحثين الذين حاولوا تحديد المعنى الأصلي لهذه الكلمة"[1]، وقد أورد الدكتور محمد أحمد شيخ علي في بحثه (**القبائل الصومالية، الأصل، والبناء، والوظيفة**) وعلق على كل رأي بما لا مزيد عليه، والباحثة تلخص ما أوردها الدكتور مع تغيير في الترتيب، ومن ثم إبداء الرأي الذي تميل إليه:

---

(١) الدكتور محمد أحمد شيخ علي، القبائل الصومالية، الأصل، والبناء، والوظيفة.

الرأي الأول: أن كلمة الصومال مأخوذة من كلمة حبشية ثم تحريفها وهي (ســـوماهة) ومعناها الكفار أو غير المتحضرين[١]، وهي تسمية أطلقها الأحباش على الصوماليين إبّان غزوات الإمام أحمد بن إبراهيم (غري) على بلادهم، إلا أن هذا ضعيف وذلك لأن كلمة الصومال كانت معروفة قبل زمن الإمام أحمد، وذلك حسب ما يراه عبد المنعم عبد الحليم[٢]، كما أن للكلمة وقعا طيبا في نفوس الصوماليين يعتزون ويفتخرون بها، ولو كانت تحمل في طياتها معنى يمس بالشخصية الصومالية أو كرامتها أو معتقداتها ما كان من المقبول لديهم أن تكون الكلمة اسماً لهم.

الرأي الثاني: أن كلمة الصومال مأخوذة من كلمتين صوماليتين هما (سمـــى) Samey وتعني يد الرمح و (له) Leh وتعني ذو أو صاحب، وجمع الكلمتين يكوّن معنىً جديـــداً وهـــو صاحب الرمح، والرمح هو السلاح السائد وسط المجتمع الصومالي التقليدي[٣]. وهذا أيضا ضعيف وذلك لأن الرمح لم يكن السلاح الوحيد المستخدم لدى المجتمع الصومالي بل إن هناك الخنـــاجر، والسيوف، والسهام، كما أن كلمة سمى "Samay " غير شائعة وسط المجتمع الصومالي ولذلك نجد أن الصوماليين يستخدمون كلمة أخرى أكثر منها شهرة وأوسع منها انتشاراً وهـــي كلمـــة (ورن) "Waran" التي تعني الرمح ويطلق على المقاتل الصـــومالي (ورنلـــي) "Waranle" أي صاحب الرمح وذلك دون بقية الشرائح الأخرى من المجتمع، ويقابل كلمة (ورنلي) كلمة (وداد) Wadaad التي تعني عالم أو رجل دين[٤].

الرأي الثالث: أن كلمة الصومال مكونة من (حرف) وهو (ســـو) Soo ، وهـــو مـــن الحروف المساندة للفعل وخاصة فعل الأمر، و (فعل) وهو مال maal ، ومعناها احلب (الناقة أو البقرة)[٥]. وهذا أيضا ضعيف فإن اللبن وإن كان الغذاء الرئيسي للمجتمع الرعوي الصومالي فإن تكريمهم لضيف عزيز عليهم وخاصة إذا كان من خارج محيطهم فضلاً عن خارج البلاد لا يكون

---

(١) Touval op . cit , p.10.

(٢) عبد المنعم عبد الحليم ، مرجع سابق ، ص١٧٠.

(٣) حسن محمد جوهر، الصومال، سلسلة شعوب العالم، العدد ١٧،(القاهرة، ١٩٦٥) ، ص١٢.

(٤) Lewis, I.M, Understanding Somalia, Haan Associates ,(London , 1993), P.16.

(٥) محمد حاج مختار ، تاريخ الاستعمار الإيطالي في الصومال ، مرجع سابق، ص٤.

بتقديم اللبن فحسب بل إنهم يذبحون له خروفاً أو عجلاً أو بعيراً حسب مقدرة المضيف وحسب مكانة الضيف، وفي أغلب الأوقات – ما لم تكن كل الأوقات – لا يصدر المضيف أوامره إلى شخص آخر لإحضار ما يكرم به ضيفه، بل إنه يقوم بنفسه إحضار الضيافة مما ينفي استخدام المضيف كلمة "احلب" عند مجيء الضيوف، وحتى إذا افترضنا استخدام هذه الكلمة في تلك اللحظة فإن هنالك كلمة أخرى أشهر منها، وأنسب منها استخداماً وأوسع منها انتشاراً وسط الرعاة وهى كلمة (سُولِس) "Soolis" أي (احلب) ولذلك فإن هذه الكلمة كانت أولى أن تطلق على المجتمع الصومالي إذا كانت كلمة الصومال مستمدة من الكلمة الصومالية التي تقابل كلمة " احلب"[١].

الرأي الرابع: أن كلمة الصومال مأخوذة من وادي الصومال في اليمن حيث هاجر منها الجد الأكبر للصوماليين[٢].

الرأي الخامس: أن كلمة الصومال مأخوذة من اسم لمدينة أو جزيرة قديمة كانت في منطقة شمال شرق الصومال والتي كانت تسمى سَمالي Samaale[٣].

وهذان الرأيان ضعيفان أيضا وذلك لأن أغلب القبائل الصومالية التي استوطنت في منطقة شمال شرق الصومال قبائل رعوية قلما تستقر في مكان واحد ولذلك كان انتماؤها إلى أجدادها أقوى من انتمائها إلى أماكن إقامتها التي تتغير بصورة مستمرة ولذلك نجد أن أسماء أسلاف القبائل

---

(١) وعلى الرغم من كون الرأي الثاني والثالث في نظر الباحثة ضعيفا إلا أنه على فرض صحته يظهر سؤال مفاده من الذي أطلق هذا الاسم هل هم الصوماليون أنفسهم أو أن غيرهم من الأجانب الذين كانوا يردون إلى تلك المناطق هم الذين أطلقوه عليهم؟ رأيان للباحثين، والذي يؤيده المنطلق هو أن الأجانب هم الذين أطلقوه عليهم وذلك لكثرة سماعهم لهذه الكلمة تتردد كثيرا إلا أن هذا الإطلاق أيضا يحتاج إلى تحديد من أطلق ومتى أطلق، وأما الرأي الأول أن الإطلاق من الصوماليين أنفسهم فبعيد وذلك لأن حمل الرماح ، وشرب الألبان أو تقديمها إلى الضيوف أمور طبيعية لديهم ولدى القوميات الرعوية المجاورة لها وغير ملفتة لأنظارهم حتى يطلقوها على أنفسهم . والله تعالى أعلم.

(٢) عبد المنعم عبد الحليم، الجمهورية الصومالية الإقليم الجنوبي، (القاهرة ١٩٦٠م)، ص١٧٠؛ أحمد عبد الله ريراش، كشف السدول عن تاريخ الصومال وممالكها السبعة، (بدون ناشر، ١٣٩١هـ) ص٣.

(٣) صلاح العقاد وجمال زكريا زنجبار، سلسلة ألف كتاب العدد ٢٩٩، القاهرة ، ١٩٥٩م، مكتبة الأنجلو المصرية ، ص٢٤٤.

الصومالية الرعوية كلها أسماء أشخاص وليس فيها اسم واحد يدل على أنه مستمد من مكان إقامتهم، وهذا بخلاف القبائل الزراعية الصومالية كما سيأتي توضيحه وهذا لا يمنع من إطلاق مجموعة من القبائل والعشائر القاطنة في منطقة معينة على إسم منطقتهم مثل " ريربري " Reer Bari أي أهل الشرق، و " رير وقويئ " Reer Waqooyi أي أهل الشمال و " رير غلبيد " ReerGalbeed أي " أهل الغرب " ، و " رير كوفور" Reer Koofur أي " أهل الجنوب " لكنه بمجرد انتقالهم من المنطقة فإن الاسم يزول عنهم حيث يطلق عليهم اسم المنطقة الجديدة التي انتقلوا إليها.

الرأي السادس: أن كلمة الصومال مأخوذة من كلمة سمل العربية (فقأ) التي كان يلقب بها زعيم قبلي صومالي سمل عين أخيه[١].

الرأي السابع: أن كلمة الصومال مأخوذة من الكلمة العربية (ذومال) التي كان يلقب بها الجد الأكبر للقبائل الصومالية، وبعد مرور الزمن تم تحريف كلمة (ذومال) إلى (صومال)[٢].

الرأي الثامن: أن كلمة الصومال مأخوذة من اسم الجد الأكبر لبعض القبائل الصومالية الذي كان يسمى سمالي "Samaale"[٣].

وهذه الآراء الثلاثة تشير إلى وجود شخص يحمل الاسم المشتق من كلمة الصومال (سمل ، أو سمالي ، أو ذومال) دون ذكر ما إذا كان صاحب الاسم شخصاً واحداً، أو عدة أشخاص، كما يشير إلى أن هذا الشخص (أو الأشخاص) هو الجد الأكبر لبعض القبائل الصومالية[٤]، الأمر الذي يفتح باب الاجتهاد في تحديد ما إذا كان صاحب الاسم شخصاً واحداً، أو عدة أشخاص؛

---

(١) Burton , Richard , , First Foot Steps in Africa ,(London 1966), p. 87.

(٢) عبد المنعم عبد الحليم ،مرجع سابق ، ص١٦٨.

(٣) أحمد جمعالي محمد ، مملكة اوفات الإسلامية في منطقة القرن الإفريقي وآثارها الحضارية ١٢٠٠-١٥٠٠م ، رسالة ماجستير (غير منشورة) جامعة أمدرمان الإسلامية ١٩٨٥م ، ص٦٤.

(٤) أحمد جمعالي محمد، مرجع سابق، ص٩؛ Cabdulqaadir Salaad Dhoorre, Soomaaliya iyo Taariikhdeedii Hore, P.22.

إذ إنه من الممكن أن يكون سمالي صاحب ثروة كبيرة (ذومال)، وأنه سمل عين أخيه، كما أنه من الممكن أن يكون كل من (ذو مال، وسمل) من أولاد وأحفاد سمالي، ومن الممكن أيضاً أنهم ثلاثة أشخاص تفرعت عنهم القبائل الصومالية الحالية، غير أنه إذا نظرنا إلى الروايات الشفهية الصومالية، وشجرة الأنساب المتداولة لديهم لا نجد اسم (سمل) ولا (ذومال)، بينما نجد أن هنالك سلفاً من أسلاف بعض القبائل الصومالية يسمى بـ(سمالي)، وهو السلف الذي تنتمي إليه قبائل هوية، ودر، وحوادلي، ودبري، وغالجعل، وغري.

وعلى أية حال؛ فإن الباحثة تبعا للدكتور محمد ترجِّح أن يكون هذا الاسم "الصومال" مستمدا من اسم سمالي الذي تطور من اسم لمدينة، أو قبيلة معينة إلى اسم يشمل تحالف القبائل الرعوية المسلمة في شمال الصومال (شمال نهر شبيلي)، ثم انداح تدريجياً إلى بقية أنحاء الصومال، ولعل هجرات القبائل الرعوية الشمالية إلى الجنوب ساهمت في انتشار اسم سمالي على القبائل الجنوبية الأخرى. والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: الموقع الجغرافي، وتعداد السكان، والمساحة:

أولا: الموقع الجغرافي:

تقع الصومال في شرق قارة إفريقيا المعروف بـــ(القرن الإفريقي)[١] يحدها من الشمال الغربي جيبوتي، ومن الجنوب الغربي كينيا، ومن الشمال خليج العدن واليمن، ومن الشرق المحيط الهندي، ومن الغرب إيثوبيا، وتمتلك أطول حدود بحرية في قارة إفريقيا، وأيضا تمتلك موقعا استراتيجيا مهمّا، فهو متاخم لكل من منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي، كما يقع في نقطة لقاء قارتي إفريقيا من الغرب وآسيا من الشرق، ويشرف على البحر الأحمر الذي يربط البحر العربي والمحيط الهندي بالبحر الأبيض المتوسط بواسطة مضيق باب مندب [٢].

وتتميز أرض الصومال بأن معظمها هضبي متموج يرتفع إلى التلال في الشمال مع وجود بعض السهول الساحلية، وسهول نهري جُوبا (Juba) وشَبيلي (Shabelle) اللذين ينبعان من هضبة إيثوبيا في الغرب، ويصب نهر جوبا في المحيط الهندي، بالقرب من كِيسْمايو[٣]، ولكن نهر شبيلي لا يصل إلى المحيط بسبب وجود كثبان رملية، ولذا ينتهي في بعض المستنقعات بالقرب من الجِلِبْ وهي مدينة على بعد ٣٠٠كم من المحيط، جنوب غربي مقديشو[٤].

---

(١) القرن الأفريقي هي شبه جزيرة تقع في شرق أفريقيا في المنطقة الواقعة على رأس مضيق باب المندب من الساحب الإفريقي، وهي التي يحدها المحيط الهندي جنوبان والبحر الأحمر شمالا، وتقع بها حاليا: جيبوتي والصومال وإريتريا ويجاورها كينيا وأثيوبيا وتتحكم مضيق باب المندب. انظر:
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A بتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ٢٠١٣م. يوم الجمعة الساعة 12: 45

(٢) الهمشري، محمد علي، **انتشار الإسلام في إفريقيا**، ط: الأولى:١٤١٨هـ١٩٩٧م، مكتبة العبيكان-رياض،ج١١،ص٩٢، محمود محمد حسن، **الذهب الأسود في الصومال**، مركز الشاهد للبحوث والدراسات الإعلامية، مارس٢٠١٢، ص٧.

(٣) هي مدينة ساحلية في الصومال، وتعرف كونها ثالث أكبر بعد العاصمة مقديشو ومدينة هرجيسا.

(٤) ومدينة مقديشو هي عاصمة جمورية الصومال الديمقراطية. انظر مؤسسة آفران للدراسات الإفريقية، إفريقيا الشرقية،

ثانيا:عدد السكان والمساحة:

يبلغ عدد سكان الصومالي حوالي ٩.٩٢٥.٦٤٠ نسمة، وكان هذا التقدير في يوليو٢٠١١ ويعتمد هذه التقديرات على إحصاء رسمي أجرته حكومة سياد بري في عام ١٩٧٥ إذ يصعب الإحصاء الفعلي للسكان في الوقت الراهن نتيجة كثرة النازحين بسبب الحروب الأهلية المتواصلة والتي ذهبت ضحيتها الآلافُ إن لم تكن ملايين.

وتبلغ مساحة الصومال ٦٣٧,٦٥٧كم مربع[١].

المطلب الثالث: اللغة واللهجات والديانة:

أولا: اللغة واللهجات:

اللغة الصومالية هي اللغة الرسمية لجمهورية الصومال، وتعتبر من اللغات الكوشية[٢].

وهناك ثلاث لهجات في الصومال يتفاهم بها الشعب فيما بينهم وهي:

١- لهجة بنادر أواللهجة الصومالية الساحلية: وهي اللهجة الآساسية، ويفهمها جميع الشعب الصومالي،حيث يتكلم بها سكان مقاطعة بنادر، من أيل(ayl)شمالا، ومركى جنوبا بما في ذلك مدينة مقديشو.

الصومال. انظر: http://www.afran.ir/ar/modules/publisher/item.php?itemid=363 بتاريخ ٢٠١٣/٠٥/٢٤م الساعة الثانية عشر نهارا

(١) محمود محمد حسن، الذهب الأسود في الصومال، مركز الشاهد للبحوث والدراسات الإعلامية، مارس٢٠١٢، ص٧.

(٢) هي مجموعة من اللغات في قرن إفريقية، تصنف ضمن اللغات الأفريقية الآسيوية، سميت على اسم كوش، الذي ذكر في التورات، أنه ابن حام.

٢-لهجة أفماي(afmaay)وهي لهجة يتكلم بها قبيلتان "راحنوين"(rahanweyn) "والدجيل"(dijel) بجنوب الصومال.

٣- لهجة الشمال:[١] يتكلم بها شمال الصومال المعروف حاليا باسم صومال لاند (Somaliland)[٢].

(كانت اللغة الصومالية تكتب بالحروف العربية سنوات عديدة، حتى جاء عالم صومالي اسمه "أحمد شيري جامع"، فنقل الكتابة من الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية، واستخدم جميع الأحرف اللاتينية المستخدمة في الإنجليزية عدا ثلاثة أحرف :p,v,z)[٣].

وتم اعتماد هذه الكتابة كنظام رسمي في البلد منذ عهد الرئيس السابق (محمد سياد بري) [٤]. حيث تم تقديمها لأول مرة في أوكتوبر من عام ألف وتسعمائة اثنين وسبعين.

وتجدر الإشارة إلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الثانية في الصومال، ويعتبر هذا أحد أهم الأسباب التي تربط الصومال بالعالم العربي، ويدرسونها في المدارس من الابتدائية حتى الثانوية.كما يؤكد لنا هذا الكلام الدستور الصومالي في مادته الثانية الفقرة الثانية: (اللغة الصومالية هي اللغة الوحيدة التي يتخاطب ويتفاهم بها الصوماليون، واللغة العربية هي لغة الشعب الصومالي التي تربطه بالأمة العربية، التي هو جزء منها، وهما اللغتان الرسميتان في جمهورية الصومال الديمقراطية)[٥].

---

(١) ما عدى منطقة أيل.

(٢) مرجع سابق

(٣) مؤسسة آفران مصدر سابق.

(٤) الجنرال محمد سياد بري (مواليد ٦ أكتوبر ١٩١٩-توفي ٢يناير ١٩٩٥) ثالث رئيس للصومال

(٥) دستور الصومالي لسنة ١٩٧٩- المادة ٢ ص٣.

أما اللغة الإنجليزية فهي أيضا من اللغات الواسعة انتشارا في البلد حيث يوجد مدارس يدرس بها،كما أن الإيطاليةكانت منذ زمن بعيد من اللغات الرسمية، ولكنها صارت شبه معدومة الآن، فلا يتكلم بها إلا عدد قليل من الأجداد الذين عاشوا في عصر الاستعمار.

ثانيا: الديانة، والمذهب:

الشعب الصومالي بأكمله متماسك بالشريعة الإسلامية، ويؤكد الدستور هذا القول في مادته الثانية الفقرة الأولى: (الإسلام دين الدولة)[1]وهم على المذهب الشافعي.

المطلب الرابع: نظام القانون

يتكون نظام القانون في الصومال من ثلاث طبقات، وهي: الشريعة الإسلامية، والقانون المدني، والقانون العشائري، ويطلق عليه اسم "الحِيْر" وهو ما يتحاكم إليه الشعب عرفيا.

(١) الدستور الصومالي: المادة الثانية الفقرة الأولى ص٣.

الطبقة الأولى: الشريعةالإسلامية:

كان للشريعة الإسلامية دور مهم في حياة المجتمع الصومالي، حيث كانت هي المرجعَ الأساسيَ الذي تستمد منه القوانين أثناء وضع أي دستور من تلك الدساتير العديدة التي تشكلت على مدار الحكوماتالمتعاقبة على الحياة السياسية في الصومال، ومع ذلك لم يتخطى العمل بها بعض المسائل المتعلقة في الأحوال الشخصية مثل: الزواج، والطلاق، وحساب المواريث، والمشاكل الأسرية الأخرى، ولكن الأمور قد تغيرت بعض الشيء بعد اندلاع الحرب الأهلية حيث وجد العديد من المحاكم الشرعية والتي انتشرت في أغلب مدن وبلدات الصومال[1].

وأصبح من دور المحاكم الشرعية الذي أوجده الفراغ السياسي هو الحكم بين الشعب حيث كان يصدر الأحكام في مختلف القضايا بشقيها المدني والجنائي وكان من مهام هذه المحاكم حفظ الأمن وضبط الإنفلات الخارج عن القانون ومحاسبة المجرمين المخالفين للقانون بحبسهم ومحاكمتهم.

الطبقة الثانية:القانون المدني:

على الرغم من الدمار الواسع الذي حل بالنظام القضائي الصومالي في أعقاب سقوط نظام سياد بري إلا أنه تمت إعادة بناء هيكل النظام القضائي الصومالي وتفعيله من جانب الحكومات المحلية الصومالية مثل حكومتي أرض البنط وأرض الصومال المتمتعين بالحكم الذاتي، أما بالنسبة للحكومة الفيدرالية الانتقالية فقد تم وضع نواة النظام القضائي الجديد خلال العديد من المؤتمرات الدولية التي أقيمت في نيروبيا وجيبوتي لهذا الخصوص.

---

(١) http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84#.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.A7.D9.86.D9.88.D9.86

وبالرغم من الاختلافات السياسية المتباينة بين كل تلك المناطق العاملة بالنظام القضائي الصومالي إلا أنهم مشتركون جميعاً في نظام قانوني واحد مستمد من النظام القضائي الصومالي القديم الذي كان موجودا منذ عهد سياد بري من حيث:

– وجود دستور يعطي أولوية إصدار الأحكام النابعة من الشريعة الإسلامية أوالأحكام الفقهية وما اتفق عليه جملة علماء المسلمين، وذلك على الرغم من أن تحكيم الدين لايتم العمل به فعليا إلا في الأمور المتعلقة بالأحوال المدنية مثل: الزواج، والطلاق، والمواريث، والأمور المدنية الأخرى، كما سبقت الإشارة إليه.

– احترام الدستور للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل القوانين ذات الصلة، كما يضمن الدستور حرية القضاء وهو ما تكفله اللجنة القضائية العليا.

– بناء النظام القضائي على ثلاثة محاور رئيسة وهي: المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، والمحاكم الابتدائية.

– إبقاء العمل بالقوانين الموضوعة قبل الانقلاب العسكري الذي جاء بسياد بري للسلطة لحين إصدار تشريعات وقوانين أخرى بديلة)[1]..

(١) ويكيبيديا مرجع سابق

الطبقة الثالثة: القانون العشائري (الحِيْر)

لسنوات عديدة كان الصوماليون يتمتعون بنظام قانوني أسسوه بطريقتهم الخاصة مستمد من أحكامهم العرفية، هذا النظام أطلقوا عليه اسم "الحِير" وهو عبارة عن قوانين متفق عليها حسب العرف إلا أنه ليست هناك جهة رسمية تنسب إليها هذه القوانين، بل يرجع في كل قضية من القضايا إلى شيوخ القبيلة لإصدار الحكم المناسب.

كما أن هذا القانون ليس مدون حتى تكون له مراجع يوضع فيها.

وفيما يلي بعض مبادئ الحير:

- دفع الدية أو الغرامة في الجرائم الموجهة ضد الأفراد مثل التشهير والسرقة والقتل والإيذاء الجسدي والاغتصاب، بالإضافة لتقديم العون مادياً ومعنوياً لأهالي الضحية لفتره زمنية معينة.

- الحرص على إقامة التزامات العائلية مثل دفع المهور عند الزواج كذلك تنفيد عقوبات النشوز.

- وضع القوانين المنظمة لاستخذام الموارد الطبيعية بأنواعها المختلفة مثل المراعي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى.

- توفير العون المادي والمعنوي للنساء اللاتي تزوجن أو أنجبن حديثا .

- مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق إعطائهم الدواجن الحية لتربيتها والاستفادة منها[1].

(١) ويكيبيديا مرجع سابق نفس الصفحة

المبحث الثاني:بيان معاني مصطلحات البحث.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف بمفهوم القانون والنظام، العقوبة الجناية.

أولا: القانون:

القانون لغة: مقياس كل شيء وطريقه، ويأتي بمعنى الأصل، وليست لغة عربية، فقيل هي لغة رومية، وقيل فارسية[١].

القانون اصطلاحاً: أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه[٢].

وقيل: (مجموعة القواعد المنظمة لسلوك وعلاقات الأشخاص في المجتمع على وجه ملزم). هذا في معناه العام، أما في معناه الخاص فهو: (كل قاعدة أو مجموعة من القواعد تضعها السلطة التشريعية لتنظيم أمر معين)[٣]، وهذا تعريف حسن مفصَّل.

---

(١) فيروز آبادي، مجد الدين، **القاموس المحيط**، مسسة الطباعة للنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، ط: الثامنه: ١٤٣٦ه،٢٠٠٥م، ح٢، ص١٥٨. الرازي، زينا لدين، **مختار الصحاح**، محقق: يوسف شيخ محمد، المكتبة العصرية دار النموذجية، بيروت-صيدا، ط: الخامسة ١٤٢٠ه، ١٩٩٩م، ج١، ص٢٦١.، **المعجم الوسيط**، مجموعة من المؤلفين: إبراهيم مصطفى، احمد زياد، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعوة، ج٢، ص٧٦٣.

(٢) المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج١، ص٧٦٣.

(٣) الخليلي، حبيب إبراهيم، مدخل للعلوم القانونية، ص١.

ثانيا: النظام:

النظام لغة: (النظام) الخيط ينظم فيه اللؤلؤ وغيره، والترتيب والاتساق ويقال نظام الأمر قوامه وعماده، والطريقة يقال ما زال على نظام واحد)[١].

وتعريف آخر:((نظام) مأخوذ من الفعل نظم، بمعنى الاستقامة والاتساق والتمام، تقول نظمت الأمر فأنتظم أي أقمته فاستقام وهو على نظام واحد أي نهج غيرمختلف) [٢].

النظام اصطلاحا:

(تأليف الكلمات والجمل المترتبة المعاني متنا سبة الدلالاةعلى حسب ما يقتضيه العقل) [٣]

ثالثا: العقوبة:

العقوبة لغة:(والعقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعله سوءاً، والاسم العقوبة، وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا: أخذه به) [٤].

العقوبة اصطلاحاً: (هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع) [٥].

---

(١) معجم الوسيط مرجع سابق، فصل النون، ص٩٣٣

(٢) الجرجاني، علي بن محمد بن على الزين الشريف، **التعريفات**،،ط الأولى١٤٠٣ه١٩٨٣م نشر: دار الكتب البيروت ح١ ص:٢٤٢

(٣) كتاب التعريفات ،مرجع السابق نفس الصفحة.

(٤) ابن المنظور، محمد إبن المكرم ، **لسان العرب**، ط:٣(١٤١٤)، النشر: دارالصادر بيروت، ،ج١،ص٦١٩.

(٥) عبد القادر عودة، **التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي**، النشر:دار الكاتب العربي، بيروت، ج:١ ص:٦٠٩ .

مفهوم العقوبة في أنظمة القانون الوضعي:(العقوبه إيلام قسري مقصود، يحمل معنى اللوم الأخلاقي والاستهجام الاجتماعي، يستهدف أغراضا أخلاقيا، ونفعية محددة سلفا، بناء على القانون، تنزله السلطة العامة في مواجهة الجميع بحكم القضاء على من ثبتت مسؤليته عن الجريمة بالقدر الذي يتناسب مع الجريمة.)[1].

رابعا: الجناية:

الجناية لغة:(اسم لما يجنيه المرء من شر وما يكتسبه).

وفي الاصطلاح الفقهي: (اسم لفعل محرم شرعاً)[2].

خامسا: مفهوم نظام العقوبات الجنائية:

مجموعة من المواد القانونية التي تحدد العقوبات المناسبة لكل جريمة يتم ارتكابها في مجتمع ما، ويقوم على رعايتها والتحقق فيها مختلف أنواع المحاكم بالدولة.

المطلب الثاني: تعريف القتل، والسرقة، والزنا في اللغة.

أولا: القتل:

القتل في اللغة: مصدر قَتَل يقتل قتلا إذا أماته أو أذله، يقول ابن فارس: (القاف والتاء واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على إذلالٍ وإماتةٍ. يقال: قتَلَهُ قَتْلاً) أي أماته، أو أذله.

ويأتي القتل بمعان أخرى منها:

---

(١) بلال، أحمد عوض،النظرية العامة للجزاء الجنائي، ط:أولى، نشر: دار النهضة العربية، ١٩٠٥ ج١،ص:١٣.

(٢) التشريع الجنائي مرجع سابق، ص٣٤٤.

اللعن والطرد ومنه قوله تعالى: ﴿قُتِلَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَآ أَكۡفَرَهُۥ﴾[1]، وقوله: ﴿قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُۖ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ﴾[2].

الخضوع: يقال: تقتلت الجارية للرجل حتى عشقها أي خضعت له حتى أحبها.

المزج يقال: قتلت الخمر بالماء إذا مزجت.

العدو: يقال القِتْل العدو، ومنه قوله: ... في بلد كثير الأقتال أي الأعداء.

المِثْل: يقال: هما قِتْلان أي مثلان.

التأنِّي: يقال: تَقَتَّلَ لحاجَتِه أي تأنَّى. وتقتّلت المرأةُ في مِشْيَتِها أي تَثَنَّتْ[3]

وتجدر الإشارة إلى أن القتل والموت يجتمعان في إزالة الروح، إلا أن هناك فرقا بينهما؛ إذ إن القتل هو نقض البنية الحيوانية، ولا يقال له قتل في أكثر الحال إلا إذا كان من فعل آدمي، وقال بعضهم القتل إماتة الحركة. ومنه يقال ناقة مقتلة، إذا كثر عليها الاتعاب حتى تموت حركتها، وأما الموت فهو عرض أيضا يضاد الحياة مضادة الروح، ولا يكون إلا من فعل الله، والميتة الموت بعينه إلا أنه يدل على الحال، والموت ينفي الحياة مع سلامة البنية، ولابد في القتل من انتقاض البنية، يقول المناوي: القتل أصله إزالة الروح كالموت لكن إذا اعتبر بفعل المتولي له يقال قتل وإذا اعتبر بفوات الحياة يقال موت[4].

---

(١) سورة: عبس، الآية:١٧.

(٢) سورة المنافقون: الآية:٤.

(٣) ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، ج٥، ص٥٦-٥٧، ابن منظور الإفريقي، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج١١،ص٥٥٢ ، الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر، طبعة جديدة، مكتبة لبنان، ناشرون بيروت، ١٩٩٥ ص ٥٦٠).

(٤) المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية، ط١ دار الفكر بيروت، ١٤١٠هـ ص ٥٧٤) (الفروق اللغوية ١/٤٢٠).

ثانيا: السرقة:

السرقة في اللغة: سَرَق الشيء يسْرِقه سَرَقاً وسَرِقاً أي أخذه في خفاء وستر، يقول ابن فارس (السين والراء والقاف أصلٌ يدلُّ على أخْذ شيء في خفاء وسِتر. يقال سَرَقَ يَسْرِق سَرِقَةً. واستَرَقَ السَّمع، إذا تسمَّع مختفياً)[1].

إذن السرقة هي (أخذ الشئ من الغير على وجه الخفية)[2].

ثالثا: الزنا:

الزنا في اللغة: الزنا والزنى بالمد والقصر، من زنى يزني زِنى وزناء أي فجر، وزانى فلانا أي نسبه إلى الزنا، ويأتي بمعنى ضاق يقال: زَنَا: ضَاقَ وزنَّى عليه تَزْنِيَةً : ضيَّقَ. ووِعاءٌ زَنِيٌّ : ضَيِّقٌ، وفي الحديث: (لا يُصَلِّيَنَّ أَحدُكم وهو زَنّاءٌ)[3]. أَي مُدافِعٌ لِلبَوْل متضيق منه، ويقال لآخر ولد الرجل زنية[4].

---

(١) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج٣،ص١٥٤،ابن منظور، لسان العرب، ج١٠، ص١٥٥.

(٢) جرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ج : ١ ،ص:١١٨

(٣) أخرجه الربيع في جامعه، انظر: الأزدي، البيع بن حبيب، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، تحقيق محمد إدريس وعاشور إبراهيم، دار الحكمة، مكتبة الاستقامة، بيروت، ١٤١٥، ص: ١٢٤. ابن الأثير، مجد الدين، **النهاية في غريب الحديث والأثر**، المحقق: طاهر أحمد-محمود الطناحي، مكتبة العلمية –بيروت ١٣٩٩ه-١٩٧٩م، ج٢، ص٣١٤.

(٤) ابن منظور، لسان العرب، ج١٤، ص٣٥٩، الفيروز آبادي، مجد الدين، **القاموس المحيط**، تحقيق: مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي،ط الثامنة،١٤٢٦ه-٢٠٠٥م، بيروت لبنان،

الفصل الأول: القتل وعقوبته في نظام العقوبات الجنائية الصومالي

وفيه توطئة ومبحثان:

التوطئة: في بيان ما يتعلق بالقتل من أحكام في الفقه الإسلامي، وسرد المواد المتعلقة بالقتل في نظام العقوبات الجنائية الصومالي. وفيها فرعان:

الفرع الأول: بيان ما يتعلق بالقتل من أحكام في الفقه الإسلامي.

أولا: تعريف القتل في الفقه الإسلامي.

لقد وردت عن العلماء عدة تعريفات للقتل بعبارات مختلفة منها:

أولا: تعريف البابرتي[١]، فقد عرف القتل بأنه: "فعل من العباد تزول به الحياة[٢]".

ثانيا: تعريف الجرجاني[٣]. حيث عرف القتل بأنه: "فعل يحصل به [٤]زهوق الروح[٥]".

---

(١) محمد بن محمد بن محمود، أكمل دين أبو عبد الله بن شيخ شمس الدين بن شيخ جمال الدين الرومي البابرتي، علامه بفقه الحنفية،نسبته إلى بابرتي(قرية من أعمال دجيل ببغداد)، رحل إلى حلب ثم إلى قاهرة وعرض عليه القضاء مرارا فأمتنع ومن مؤلفاته:شرح تلخيص الجامع الكبير، العناية في شرح الهداية، وشرح مشارق الأنوار، توفي بمصر سنة:٧٨٦هـ. للزركلي، الأعلام،ج٧،ص:٤٢.

(٢) البابرتي، محمد، **العناية شرح الهداية**، دار الفكر، ج:١٠،ص:٢٠٣.

(٣) أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس الجرجاني، قاضي البصرة وشيخ الشافعية بها في عصره، ولد في تاكو قرب(إستراباد) ودرس في شيراز، له نحو خمسين مصنفا: منها كتاب التعريفات، الديباج المهذب في مصطلح الحديث،ونحو مير، توفى٨١٦م، الزركلي، خير الدين، **الأعلام**، ط:خامسة عشر أيار/مايو٢٠٠٢منشر: دارالعلم للملايين ج:١ص:٢١٤.

(٤) خروج روح المقتول بفعل آدمي، الرصاع، محمد، **شرح حدود ابن عرفة**، ط:الأولى، ١٣٥٠ه، مكتبة العلمية،

(٥) الجرجاني، التعريفات ج:٣، ص:١٧٢.

وهذا التعريف يشمل القتل العمد بحق والقتل بغير حق، وفي تعريف آخر: أصل القتل إزالة الروح كالموت ولكن إذا اعتبر بفعل المتولي له،يقال قتل،وإذا اعتبر بفوات الحياة يقال موت[1].

فالقتل إذن: هو أن تزهق روح إنسان بفعل إنسان آخر، أو بفعل نفسه، أما إذا كان الإزهاق بلا فعل إنسان سمي موتا[2].

ثانيا: بيان أنواع القتل:

اختلف العلماء في أنواع القتل فمنهم من قسمه إلى قسمين عمد وخطأ،ومنهم من قال ثلاثة، عمد وشبه العمد والخطأ، ومنهم من قال أربعة عمد وشبه عمد والخطأ وما أجري مجرى الخطأ، إذن نعرض أقوال العلماء وأدلة كل قول لمعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف ثم أخذ رأي الراجح.

القول الأول:

يري الإمام مالك[3] رحمه الله أن القتل ينقسم إلى قسمين: عمد وخطأ، أما شبه العمد فلا يقول به إلا في حالة قتل الوالد لولده[4].

---

(١) المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ج١،ص:٢٦٨.

(٢) الزيلعي، فخر الدين، **تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي**، ط:الاولى١٣١٣ه، المطبعة الكبرى الأميرية بولاق، مصر، ١٣١١ه ج٦ص٩٧.

(٣) هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي بفتح الباء نسبة إلى ذي أصبح، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأعلام، ومؤسس المذهب المالكي، عربي الأصل من التابعين، ولد بالمدينة المنورة وعاش كل حياته بها في مهبط الوحي، ومات بها سنة١٧٩ه ودفن بالبقيع، ومن مؤلفاته كتاب الموطأ طل يحرره أربعين عاما جمع فيه عشرة آلاف حديث، ثم المدونة وقد صنفها سحنون التنوخي، واحتوت على جميع أراء مالك المخرجة على أصوله، وهي من أهم كتب التي حفظت مذهب الإمام مالك. مالك ابن انس، ابن فرحون، إبراهيم،**الديباج المذهب**، تحقيق: محمد الأحمدي، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة ج١، ص٨٢.

(٤)ابن فرحون، إبراهيم، **تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام**،ط:الاولى ١٤٠٦ه-١٩٨٦م ،مكتبة الكليات

قال الباجي[1]: أما شبه العمد فاختلف قول المالك فيه فمرة أثبته ومرة نفاه، فروى ابن القاسم وغيره عنه في المجموعة وغيرها، أن شبه العمد باطل، إنما هوعمد أو خطأ[2].

والعمد هو أن يقصد من يعلمه معصوماً بما يقتل غالباً[3]، سواء أن يقتل بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط أو حجر كبير يقتل غالباً، فعلى ذلك أن العمد نوعان أحدهما: أن يضرب بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والسنان وما في معناه مما يحدد فيجرح، من الحديد، والنحاس، والرصاص، والذهب، والفضة، والزجاج، والحجر، والقصب، فهذا كله إذا جرح به جرحاً كبيراً فمات به فهو قتل عمد، ولا خلاف فيه بين العلماء.

والنوع الثاني: القتل بغير المحدد مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله كالعصا ونحوه مما له ثِقَل ولا حدّ له، فهذا عمد[4].

أما القتل الخطأ فهو: أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصده[5].

دليل المالكية:

الأزهرية، ج٢، ص٢٢٧.

(١) سليمان بن الخلف ابن سعد التجيبي القرطبي أبو الوليد الباجي فقيه مالكي كبير من رجال الحديث، ولد في باجة بالأندلس فولى القضاء في بعض أنحائها، وتوفي بالمرية سنة ٤٧٤ه ومن مؤلفاته: سراج في علم الحجاج، وإحكام الفصول في أحكام الأصول. انظر: الزركلي، الأعلام، ج٣، ص:١٢٥.

(٢) الباجي، سليمان بن خلف، **المنتقى شرح الموطأ**، ط: الاولى:١٣٣٢ه، مطبعة السعادة- بجوار محافظة مصرالدار ح٧ ص:١٠٠.

(٣) ابن تيمية، تقي الدين، **السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية**، ط:الاولى ١٤١٨ه، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية، ،ج:١،ص:١١٤.

(٤) ابن قدامة، موفق الدين، **المغني** مرجع سابق، ج٨ ص ٢٦٠-٢٦١.

(٥) ابن التيمية، السياسة الشرعية في أصول الراعي والرعية، ج١ ص ١١٩.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ ﴾[1]، وقال جل شأنه: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾[2]. فالله سبحانه وتعالى قد ذكر في الآية الأولى: القتل الخطأ وفي الآية الثانية: القتل العمد، فلا مجال لشبه العمد بينهما.

القول الثاني:

يرى جمهور الفقهاء: كأبي حنيفة[3]، وبعض المالكية[4]، وجمهور الشافعية[5]، وجمهور الحنابلة[6]، أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:القتل العمد، والقتل الخطأ، والقتل شبه العمد، ويسمى عند بعضهم: عمد الخطأ.

أدلتهم:

استدل أصحاب هذا القول من السنة النبوية بالآتي:

---

(١) النساء، الأية: ٩٢ .

(٢) النساء، الأية ٩٣.

(٣) السرخسي، المبسوط: محمد، دار المعرفة بيروت، ١٤٠٦ه-ج٢٦ ص٥٩

(٤) المنتقى شرح الموطأ، المؤلف أبو الوليد سليمان بن الحلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي(المتوفى:٤٧٤)، طبعة الأولى، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، ج٧ ص١٠٠

(٥) الأم، ابو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ت:٢٠٤ه-٨٢٢م، الطبعة: الثانية، دار المعرفه بيروت، سنة النشر:١٣٩٣ه، النشر:١٣٩٣ه، ج٧ ص٣٤٨.

(٦) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المؤلف:عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي موفق الدين أبو محمد المعروف ب(بن القدامه) ت:٦٢٠ه، الطبعة الأولى، دار الفكر بيروت، سنة النشر:١٤٠٥ه ،ج:٨،ص:٢٠٧-٢٠٨، الخرقي، أبو القاسم، متن الخرقى على مذهب أبي عبد الله أحمد ابن حنبل الشيباني، ط:١٤١٣ه،١٩٩٣م، دار الصحابة للتراث، ج١، ص١٢٣.

١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِ أَوْلَادِهَا" [١].

وجه الدلالة:

الحديث ظاهر في أن القتل إذا كان بآلة لا تقتل غالبا كالسوط والعصا، فلا قصاص فيه وهو شبه عمد، كما سماه المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيه دية مغلظة، مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها.

قال أبو جعفر: ذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا: لا قود على من قتل الرجل بعصا أو حجر وممن قال بذلك أبو حنيفه[٢]. رضي الله عنه، وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما فقالوا: إذا كانت الخشبة مثلها يقتل فعلى القاتل بها القصاص وذلك عمد. وإن كان مثلها لا يقتل ففي ذلك الدية وذلك شبه العمد[٣].

٢- عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ((اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ[٤] عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا[١]، وورثها ولدها ومن معهم[٢]،

---

(١) السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث، **سنن أبي داود**، المحقق: محمد محي الدين، النشر: مكتبة العصرية-صيدا- بيروت، كتاب الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد، حديث رقم:٤٥٤٧، ج٤، ص١٨٥. ابن ماجة، أبو عبد الله محمد القزويني، **سنن ابن ماجه**، محقق: محمد فؤاد، النشر: دار إحياء الكتب العربية- فيصل عيسى البابي الحلبي، كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة، جديث رقم:٢٦٢٧، ج٢، ص٨٧٧.

(٢) هو الإمام أبو حنيفة، وإسمه نعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي فقيه العراق، وأحد أئمة الإسلام، والسادة الأعلام، وأحد أركان العلماء، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتنوعة وهوأقدمهم وفاة، توفي: رجب سنة خمسين ومائة، وعن ابي معين سنة إحدي وخمسين، وقال غيره: سنة ثلاث وخمسين، فتم له من العمر سبعون سنة. انظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر، **البداية والنهاية**، الطبعة الأولى: ١٤٠٨ه-١٩٨٨م، ج١٠،ص:١١٤.

(٣) الطحاوي، أبو جعفر، **شرح معاني الآثار**، طبعة:الأولى، ت:١٤١٤ه-١٩٩٤م، عالم الكتب، ، ج٣، ص:١٨٦.

(٤) معنى الغُرَّة: عبد أو أمة. وأصل المعنى من البياض، أو خيرة الشيء، وأطلق على العبد أو الأمة لأنه من خير ما يملكه

فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجَعِهِ[٣] الَّذِي سَجَعَ))[٤].

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن القتل في هذه الحالة كان شبه العمد، وذلك لقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، والعمد لا تعقله العاقلة، و لم يكن الخطأ لأن الضرب على هذا الوجه لا يكون كذلك، فيلزم أن يكون القتل هنا شبه عمد، ويحمل الحجر هنا على الصغير الذي لا يقتل غالبا، فلا قصاص فيه والدية على العاقلة وهو الحق[٥].

٣- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُه)) قَالَ :وَزَادَنَا خَلِيلٌ، عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ: ((وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ))[٦].

الإنسان آنذاك. انظر: ابن الأثير، أبو السعادات، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج١، ص٢٤١، أيضا الزمخشري، الفائق في غريب الحديث والأثر، ج١، ص١١.

(١) والعاقلة: هي القرابة التي تعطي الدية من قبل القاتل، الزمخشري، الفائق في غريب الحديث والأثر، ج١، ص٢٤١.

(٢) البخاري، محمد ابن إسماعيل أبو عبد الله، **صحيح البخاري**، المحقق: محمد زهير، النشر دار طوق النجاة، ط الأولى:١٤٢٢، كتاب الديات، باب جنين المرأة، حديث رقم:٦٩١٠، ج٩، ص١١.

(٣) والسَجَع: القصد المستوى على نسق واحد. ابن الأثير، النهاية في عريب الحديث والأثر، ج٢، ص٣٤٣.

(٤) متفق عليه: انظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري مع الفتح، دار المعرفة بيروت ١٣٧٩، ج١٠، ص ٢١٨، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم بشرح النووي، دار إحيا التراث العربي- بيروت، ط الثانية: ١٣٩٢، ج١١، ص١٧٧.

(٥) حسن، يوسف علي، الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد وأجزيتها المقررة في الفقه الإسلامي، دار الفكر. جزء:١، ص:٢١١.

(٦) السجستاني، أبو داود، **سنن أبي داود**، كتاب الديات، حديث رقم ٤٥٦٥، ج٤، ص١٩٠. وقد انكر ابن الحزم صحة هذا الحديث وقال أنه مرسل ، ابن حزم، أبو محمد، **المحلى بالآثار**، دار الفكر- بيروت، كتاب الدماء والقصاص، باب من كلام في شبه العمد وهو عمد خطأ ج١٠، ص٢٧١.

القول الثالث:

يري بعض الحنفية كالكاساني[1]، وبعض الحنابلة كالخطاب[2]، أن القتل ينقسم إلى أربعة أقسام:

قتل عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما جرى مجري الخطأ، وقد فرق أصحاب هذا الرأي بين الخطأ وما أجري مجراه، فالخطأ عند هؤلاء قد يكون في نفس الفعل، وقد يكون في ظن الفاعل،كما هو عند أصحاب القول الثاني، من الشيخي: إن الخطأ قسمان إما الخطأ في القصد بأن يرمي شخصا ظنه صيداً فإذا هو آدمي، أو يرمي حربياً فيصيب آدميا معصوم الدم، وإما الخطأ في الفعل بأن يرمي غرضاً فيصيب آدمياً فإنه أخطأ في الفعل لا القصد فيكون معذورا[3].

أما ما أجري مجرى الخطأ، فقد جعلوه قسما مستقلا ووضعوا له حالتين:

الأولى: أن يكون معنى الخطأ من كل وجه، وهو أن يكون عن طريق المباشرة كنائم ينقلب على شخص فيقتله، أويقع شخص من أعلى على آخر فيقتله، فهذا القتل في معنى الخطأ من كل وجه لانتفاء القصد[4].

الثانية: أن يكون معنى الخطأ من وجه وهو أن يكون القتل بالتسبب، كمن حفر بئراً فيقع فيها إنسان فيموت، ففي هذه الحالة لم يحصل القتل من الحافر، لأنه لم يباشره، وإنما عليه الضمان لتعديه بالحفر[1].

---

(١) الكاساني، علاء الدين، **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع طبعة:الثانية**، ١٤٠٦ه-١٩٨٦م دار الكتب العلمية ج٧،ص٢٣٣.

(٢) المقدسي، عبد الرحمن، **شرح الكبير على متن المقنع**، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ط: بدون، ج٩، ص٣١٩.

(٣) داماد أفندي، عبد الرحمن، **مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر**،ط:بدون دار أحياء التراث العربي-بيروت لبنان، ج:٢، ص٦١٧.

(٤) حسن، الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد،المؤلف ،ج١،ص٢١٩

القول الرابع:

وأصحاب هذا القول قسموا القتل إلى خمسة أقسام، حيث قالوا: أن القتل إما أن يكون عمداً، أوشبه عمد، أوخطأ، أو ما جري مجرى الخطأ، وما ليس بعمد ولا خطأ، ولا أجري مجري الخطأ. وقال بهذا الرأي أبو بكر الرازي الشهير بـــ(الجصَّاص)من الحنفية[٢].

الرأي الراجح:

بعد ما تقدم من أقوال العلماء في مسألة أنواع القتل نلاحظ أن الفقهاء قد اتفقوا على نوعين من القتل وهما القتل العمد، والخطأ، واختلفوا في إثبات الأنواع الثلاثة الأخرى، شبه العمد وما أجري مجري الخطأ، والقتل بالسبب، كما يرى بعض الفقهاء أن القتل بالسبب صورة من صور القتل العمد، فيكون الاختلاف الجوهري بين الفقهاء في شبه العمد، ونلاحظ أن الفرق بين التقسيم الثلاثي والرباعي والخماسي، إنما هو اختلاف في صور كيفية حدوث القتل، هذه الأنواع من القتل ليس لها أثر في الأحكام المترتبة عليه، لأن أصحاب التقسيم الثلاثي يردون القسمين الأخيرين من التقسيم الخماسي إلى القتل الخطأ ، وإلا فلا خلاف في الحكم المترتب عليهما من حيث الجملة.

أما: المرداوي والزركشي وبعض المتأخرين كأبي الخطاب فزدادوا قسما رابعا، ولا نزاع أنه باعتبار الحكم الشرعى لا يزيد على ثلاثة أوجه: عمد وهو ما فيه القصاص، أو الدية، وشبه العمد، وهو ما فيه دية مغلظة من غير قود، وخطأ وهوما فيه دية مخففة، انتهي.

قال المرداوي: قلت: (الذي نظر إلى الأحكام المترتبة على القتل جعل الأقسام ثلاثة أوجه، والذي نظر إلى الصور: فهي أربعة بلا شك، وأما الأحكام فمتفق عليها)[١].

---

(١) الكاساني، بدائع الصنائع، ،ج٧،ص٢٧١-٢٧٢

(٢) السرخسي، محمد، **المبسوط**، ط:بدون، دار المعرفة-بيروت، ١٤١٤ه-١٩٩٣م ج:٢٦،ص:٥٩-٦٠ .

ونفى المالكية والظاهرية القتل شبه العمد وليس عندهم حجة قوية في قولهم، إلا أنه لم يرد في كتاب الله سوى قسمان فقط، فعدم وروده في القرآن لا يضر لأنه ليس هو الأصل الوحيد في الشرع، وهناك أصل آخر وهو السنة، وقد ثبت شبه العمد في الأحاديث النبوية التي تقدمت وقال بصحتها أكثر من واحد من العلماء،

وأيضا فإن شبه العمد موجود ومتصور في العقل، إذ في القتل شبهان: شبه من العمد آخر من الخطأ، ففي تغليب جانب العمد إضاعة لجانب شبه الخطأ، وفي تغليب جانب الخطأ إضاعة لجانب شبه العمد، وفي كلا الأمرين ابتعاد عن العدالة، فذلك يقتضي وجود قسم ثالث يكون بين العمد والخطأ تحقيقا للعدالة، وإنصافا للجانبين المتنازعين. والله تعالى أعلم.

ولكن نظام العقوبات الجنائية في القانون الصومالي اعتمد قسمين فقط على مذهب المالكية وهما القتل العمد، والقتل الخطأ، ولم يتطرق إلى ذكر القسم الثالث كما سيأتي.

ثالثا: حكم ودليل كل نوع من أنواع القتل الثلاثة.

تقدم آنفا أن الراجح من تقسيمات العلماء للقتل هو التقسيم الثلاثي إلى عمد وخطأ وشبه عمد، وهنا يتم عرض حكم كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ودليله.

القسم الأول: القتل العمد:

القتل العمد هو:تعمد الضرب بالسلاح أوما يجري مجرى السلاح، أي ضرب شخص قصدا بما لا تطيقه بنيته،حتى إن ضربه بحجر عظيم أو خشب عظيم فهو عمد على خلاف مع الحنفية[٢].

---

(١) المرداوي، علاء الدين، **الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف**،ط:ثانيةب، مطبعة دار إحياء التراث العربي ،ج٦، ص٤٣٤.

(٢) الجرجاني، التعريفات ،ج١،ص١٧٢.

إذن القتل العمد: هو أن يقصد القتل بحديد له حد أو طعن كالسيف، والسكين، والرمح وما أشبه دلك، أو ما يعمل عمل هذه الأشياء في الجرح، والطعن كالنار، والزجاج، والرصاص، وكذلك الآلة المتخذة من النحاس، وكذلك القتل بحديد لا حد له كالعمود، ونحو ذلك[1].

تحريم القتل العمد في الكتاب والسنة:

القتل العمد في الشريعة الإسلامية يعتبر من الكبائر ومن أعظم الجرائم، وقد جاء في القرآن والسنة تحريمه وتحديد عقوبته.

تحريم القتل من القرآن: قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾[2].

تحريم القتل من السنة: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ))[3].

عقوبته في الشريعة الإسلامية:

عقوبة القاتل العمد في الشريعة الإسلامية لها جانبان:

١- عقاب في الآخرة: وهو الإثم والوعيد[1]، قال تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾[2].

---

(١) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج٧،ص٢٣٣.

(٢) سورة الإسراء، الآية:١٧.

(٣) متفق عليه. انظر: البخاري: **صحيح البخاري مع الفتح**، كتاب الديات، باب قول الله تعالى:(أن النفس بالنفس والعين بالعين..)، حديث رقم: ٦٨٧٨، ج٩، ص٥. مسلم، **صحيح مسلم بشرح النووي**، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، ج٣، ص١٣٠٢.

٢- عقاب في الدنيا: للقتل العمد أكثر من عقوبة تتمثل في الجوانب الآتية:

أ- القصاص أو الدية.

ب- الكفارة.

ج- الحرمان من الميراث.

---

(١) ابن الحجر العسقلاني، أحمدبن علي، **فتح الباري شرح صحيح البخاري**، دار المعرفة-بيروت،١٣٧٩، ج١٢،ص١٧٨-١٩٠.

(٢)سورة النساء، الآية٣٩.

تعريف القصاص اصطلاحا:

القصاص هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل[١]. ومعنى القصاص المماثلة، أي مجازاة الجاني بمثل فعله وهو القتل. تجب عقوبة القصاص بارتكاب جريمة القتل العمد في الشريعة[٢].

شروط القصاص[٣]:

فالقصاص له شروط بعضها يرجع إلى القاتل وبعضها إلى المقتول وبعضها إلى القتل نفسه، وبعضها إلى ولي القتيل، وتورد الباحثة هنا الشروط التي تراها راجحة في نظرها مع الاكتفاء بالإشارة إلى وجود الخلاف فيما فيه خلاف والإحالة إلى مظانه، فتقول:

أما الذي يرجع إلى القاتل فأربعة:

أولا: أن يكون عاقلا.

والثاني: أن يكون بالغا.

والثالث: أن يكون متعمدا في القتل.

والرابع: أن يكون القاتل مختارا[٤]، وفي المكره خلاف بين العلماء[٥].

---

(١) الجرجاني، تعريفات، ،ج١،ص١٧٦.

(٢) عبد القادر العودة، التشريع الجنائي، ج:٢،ص:١١٣.

(٣) الكاساني، بدائع الصنائع في تر تيب الشرائع، ج٧، ص٢٣٤.

(٤) ابن قدامه، المغني، ج٢، ص٢٦٧.

(٥) السرخسي، المبسوط، ج٢٣، ص٧٣. ابن رشد الحفيد، أبو الوليد، **بداية ،المجتهد ونهاية المقتصد**، ط:بدون ، دار الحديث القاهرة، ١٤٢٥ه-٢٠٠٤م ، ج:٤،ص:١٧٨، الشافعي، أبو عبد الله، **الأم**، دار المعرفة بيروت، ت: ١٤١٠ه، ١٩٩٠م، ط بدون، ج٦، ص٤٤. ابن قدامه، المغني، ج٢، ص٢٦٧.

وأما الشروط التي ترجع إلى المقتول فثلاثة:

الأول: أن لا يكون جزء القاتل: يعني أن لا يكون والدا للمقتول[١]. وفيه خلاف بين العلماء[٢].

الثاني: أن لايكون ملكا للقاتل: وفيه خلاف بين العلماء[٣].

الثالث أن يكون معصوم الدم مطلقاً: لا يقتل المسلم بالكافر لعدم العصمة.

وأما الذي يرجع إلى نفس القتل: فهو أن يكون القتل مباشرة.

وأما الذي يرجع إلى ولي القتيل: فهو أن يكون الولي معلوما[٤].

الثاني من عقوبات القتل العمد: الكفارة:

الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر لأنها تغطي الذنب وتستره، والأصل فيها الإجماع[٥]. وسنده قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ

---

(١) المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ح:٩، ص:٤٧٣.

(٢) المرغيناني، علي ابن أبي بكر، **الهداية في شرح بداية المبتدي**، المحقق: طلال يوسف، دار إحياءتراث العربي- بيروت- لبنان، ج٤، ص٤٤٥، الشافعي، الأم، ج٦، ص٣٦، الصنعاني، سبل السلام، ج٢، ص٣٤٠. القرطبي، الجامع لأحكام، ج٢، ص:٢٥٠.

(٣) المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج٨، ص٢٩٠. والشافعي للأم، ج٧، ص٣٣٧. المقدسي، المغني لإبن قدامه، مرجع سابق.

(٤) مرجع سابق، ج٧،ص٢٣٩-٢٤٠.

(٥) البهوتي، منصور، **كشاف القناع عن متن الإقناع**، دار الكتب العلمية، ج٦،ص:٦٥

رَقَبَةٍ مُّؤۡمِنَةٖۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿٩٢﴾ [1].

الثالث: الحرمان من الميراث:

الأصل في ذلك ما أخرجه ابن ماجه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ - قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، فَقَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ((لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ))[2].

ثم اختلف العلماء على أي قتل يمنع من الميراث وفي تفاصيل هذا الأمر يرجى الرجوع إلى المراجع المذكورة في الهامش[3].

---

(١) سورة النساء، الآية٩٢.

(٢) ابن ماجه، أبو عبد الله، **سنن إبن ماحه**، محقق محمد فؤاد دار إحياء الكتب العلمية، في كتاب: الديات، باب القاتل لايرث، حديث رقم:٢٦٤٦ ج٢، ص٨٨٤.

(٣) مالك، ابن أنس، **المدونة**: ط:الأولى، ١٤١٥ه-١٩٩٤م، دار الكتب العلمية، ج:٤،ص:٣٤٧.، السرحسي، المبسوط ج:٣٠،ص٤٧.، الشربيني، شمس الدين، **مغني المحتاج إلي معرفة معاني الألفاظ المنهاج**، ط:الأولى١٤١٥ه-١٩٩٤م دار الكتب العلمية ج:٤ ص ٤٧، المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج:٧،ص:٣٦٨.

القسم الثاني: القتل شبه العمد:

تعريف القتل شبه العمد:

أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح، ولا أجري مجرى السلاح، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما إذا ضربه بحجر عظيم، أو خشبة عظيمة، فهو عمد، وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يُقتل به غالباً، كالسوط والعصا الصغير والحجرالصغير[1].

وعند الشافعية: "شبه العمد هو أن يكون عامداً في الفعل مخطئا في القصد، مثل أن يقصد ضربه بما لا يقتل مثله غالبا"[2].

أما عند الحنابلة: أن يقصد إصابته بما لا يقتل غالبا فيقتله[3].

وعليه فإنهم جميعاً اتفقوا على أن القتل شبه العمد هو أن يتعمد شخص ضرب آخر بما ليس معداً للقتل ولا يقتل مثله غالباً، وإنما اختلفوا في تحديد ما لا يقتل غالباً، فعند أبي حنيفة كل ما ليس بمحدد، فالقتل به شبه عمد، وعند غيره كل ما غلب على الظن أنه لا يقتل غالبا فهو شبه عمد، وكلما غلب على الظن أنه يقتل غالبا فهو عمد حتى لو كان غير محدد، وهذا هو ما تميل إليه الباحثة حفاظا على النفوس من التعدي عليها. والله تعالى أعلم.

---

(١) الجرجاني، كتاب التعريفات ج١ ص:١٢٥.

(٢) النووي، المجموع شرح المهذب، ج١٩ ص٥.

(٣) المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد، ج٣ ص٢٥١.

عقوبات القتل شبه العمد:

أولا: الدية:

تعريف الدية: هوالمال الذي هو بدل النفس[1].

الأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة :

أما الكتاب في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ﴾[2].

وأما السنة فروى أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم كتاباً إلى أهل يمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه: ((وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ))[3].

ثانيا: الكفارة:تجب الكفارة عقوبة أصلية على القتل شبه العمد مع الدية وقد تم تعريف الكفارة وبيان دليل وجوبه في موضوع القتل العمد.

ثالثا: الصيام:الصيام عقوبةبدلية لعقوبة الكفارة عند عدم وجود الرقبة، وهو شهران متتابعان.

رابعا: الحرمان من الميراث: وقد تكلمنا سابقا عن هذا الموضوع في موضوع القتل العمد.

---

(١) المصدر نفسه،ج١، ص١٠٦. البهوتي، **كشاف القناع**، ج٦، ص٥.

(٢) سورة النساء، الآية٩٢.

(٣) السجستاني، **سنن أبي داود**، كتاب الديات ج٢ ص٢٧٩.

القسم الثالث: القتل الخطأ:

تعريف القتل الخطأ:

هو ما ليس للإنسان فيه قصد، وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد ويسير شبهة في العقوبة حتى لايؤثم المخطئ، ولا يؤخذ بحد ولا قصاص[1].

القتل الخطأ فقد يكون في نفس الفعل، وقد يكون في ظن الفاعل، أما الأول فنحو أن يقصد صيدا فيصيب آدميا، أوأن يقصد رجلا فيصيب غيره، وأما الثاني: فنحو أن يرمي إلى إنسان على ظن أنه حربي أو مرتد فإذا هو مسلم[2].

الأصل في عقوبة القتل الخطأ:

قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ ﴾[3].

---

(١) الجرجاني، تعريفات ج١ ص٩٩.

(٢)الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج٧ ص:٢٣٤.

(٣) سورة النساء، الآية:٩٢

عقوبات القتل الخطأ:

منها وجوب الدية:

هي عقوبة أصلية وليست بدلا من عقوبة أخرى لأن عقوبة القتل الخطأ روعي في تقديرها إنعدام القصد، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٌ))[1].

ثانيا: الكفارة: وقد تكلمنا عن هذا الموضوع في عقوبة القتل العمد.

ثالثا: الصوموقد تكلمنا عن هذا الموضوع في عقوبة القتل العمد.

رابعا: الحرمان من الميراث.وقد تكلمنا عن هذا الموضوع في عقوبة القتل العمد.

الفرع الثاني: سرد المواد المتعلقة بالقتل في نظام العقوبات الجنائية الصومالي:

جرائم ضد حياة الأفراد وسلامتهم

المادة (٤٣٤) كل من ارتكب جريمة القتل يعاقب بالإعدام.

المادة (٤٣٥): **قتل الأبناء دفاعا عن الشرف:**

١- كل من تسبب في وفاة الطفل بعد ولادتة مباشرة أو جنين أثناء ولادته دفاعاً عن الشرف الشخصي أو شرف أحد أصوله أو فروعه يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

٢- يعاقب بذات العقوبة كل من حرض على اتكاب هذه الجريمة.

---

(١)ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب دية القتل الخطأ، حديث رقم:٢٦٣١، ج٢ ص٨٧٩.

المادة (٤٣٦): **التسبب في موت شخص برضائه**[1].

١- كل من تسبب في وفاة شخص برضاه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر سنة.

٢- يعاقب الجاني بالإعدام إذا ارتكب الجريمة:

أ- ضد شخص لم يبلغ الثامن عشر من عمره.

ب- ضد شخص معتوه.

ج- ضد شخص تحصّل الجاني على رضاه بالعنف أو التهديد أو الإيحاء أوالتحايل

المادة (٤٣٧) **الشروع في الانتحار**

كل من حاول إزهاق روحه بارتكاب فعل كاف لإحداث الوفاة يعاقب بالسجن مدة أقصاها خمس سنوات أو بغرامة أقصاها عشرة آلاف شلن صومالي.

المادة (٤٣٨) **التحريض أو المساعدة على الإنتحار**:

١- كل من حرض شخصاً أو ساعده على الانتحار أوسهّل له بأية وسيلةٍ ارتكاب هذه الجريمة يعاقب في حالة وقوعاً لانتحار بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. فإذا لم تتم جريمة الانتحار فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز الخمس سنوات بشرط ألا يترتب على المحاولة إصابة جسيمة أو شديدة الجسامة.

---

(١) قانون العقوبات لجمهورية الصومال الديمقراطية لسنة ١٩٧٠، طبعة: بمعرفة مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع

٢- تزداد العقوبة إذا كان الشخص الذي تعرض للتحريض أو المساعدة ممن يندرجون تحت إحدى الفئات المشار إليها في البندين أ،ب من الفقرة (٢) من المادة ٤٣٦. ومع ذلك فإذا لم يبلغ الشخص المذكور الرابعة عشر من عمره، أو كان ناقص الأهلية فتطبق الأحكام الخاصة بالقتل.

المادة (٤٣٩) **التعدي:**

١- كل من تعدّى على آخر بالضرب و لم ينجم عن هذا التعدى مرض جسماني أو عقلي يعاقب بناء على شكوى المجنى عليه بالسجن مدة أقصاها ستة شهور أو بغرامة أقصاها ثلاثة آلاف شلن صومالى.

٢- لايطبق الحكم السابق إذا اعتبر القانون الفعل ركنا أوظرفا مشددا فى جريمة أخرى.

المادة (٤٤٠) **الإصابة:**

١- كل من أصاب آخر إصابة نشأة عنها مرض جسماني أو عقلي يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز ثلاث سنوات .

٢- تعد الإصابة جسيمة وتوقع عقوبة السجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات.

أ- إذا نشأ عن الفعل مرض يهدد حياة المجنى عليه أ مرض أو عجز يمنعه عن مزاولة حرفته المعتادة لمدة أربعين يوماً.

ب- إذا اقتضى الفعل مستديم فى حاسة أو عضو.

ج- إذا كانت المجنى عليها حبلى وأفضى الفعل إلى تعجيل الولادة.

٣- تعد الإصابة شديدة الجسامة وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تتجاوز إثنتا عشرة السنة إذا نجم عن الفعل:

أ- علة من المحقق أو من المرجح عدم شفاؤها.

ب- فقدان حاسة من الحواس.

ج- فقدان عضو أو بتره بحيث يصبح عديم الجدوى أو فقدان القدرة على استعمال عضو من الأعضاء أو فقدان المقدرة على الإنجاب أو صعوبة مستديمة وخطيرة فى النطق.

د- تشوه الوجه أو عاهة مستديمة فيه.

ه- إجهاض المحنى عليها.

المادة (٤٤١)

كل من تسبب فى وفاة آخر بارتكابه فعلا من الأفعال المشار إليها فى المادتين ٤٣٩ و ٤٤٠ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

المادة (٤٤٢): **القتل أو الإصابة بواسطة أحد الوالدين:**

١- إذا ما ارتكب أحد الوالدين إحدى الجرائم المشار إليها فى المواد:٤٣٨،٤٣٦،٤٣٤

فتعدل العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كالآتى:

أ- تخفض عقوبة الإعدام إلى السجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات ولا تزيد على خمس عشرة السنة.

ب- تخفض عقوبة السجن مابين النصف والثلث.

المادة (٤٤٣) **القتل أو الإصابة دفاعا عن الشرف:**

١- كل من فاجأ زوجه أو إحدى بناته أوأخواته فى حالة زنا فقتل فى ثورة غضب جامحة زوجه أو بنته أو أخته دفاعا عن شرفه وشرف الأسرة.

وتسرى العقوبة ذاتها على كل من تسبب وهو فى نفس الظروف فى موت الطرف الآخر الذى يفاجئه أثناء ارتكابه الزنا من زوجه أو بنته أو أخته.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.

٢- إذا تسبب الجاني وهو فى ذات الظروف في إصابة أحد من الأشخاص المذكورين آنفا فتخفض العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٤٤٠ بواقع الثلث.

فإذا حدثت الوفاة نتيجة الإصابة فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن السنتين ولا تتجاوز ثمانى سنوات.

٣- لا عقاب على الشخص الذى ارتكب ضد الأشخاص المذكورين آنفا الفعل المشار إليه فى المادة ٤٣٩ وكان واقعا تحت نفس الظروف .

المادة (**٤٤٥**):

١- كل من تسبب فى موت آخر بإهماله الناشئ عن خطئه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تتجاوز خمس سنوات.

٢- تطبق أحكام المادة (٤٤)[1]. في حالة وفاة أكثر من شخص أو وفاة شخص وإصابه شخص أو أكثر على أن لا تتجاوز العقوبة في مجموعها اثنتي عشرة سنة.

---

(١) يعاقب بالعقوبات المقررة بالجرائم المختلفة، كل من ارتكب فعلا واحدا انطوى على مخالفة أكثر من نص من نصوص القانون، وكل من ارتكب أكثر من مخافة لنص واحد. ويجب في هذه الحالة جمع العقوبات المقضى بها في الحكم الواحد، على أن لا يتعدى الحد الأقصى محدد قانونا.

المبحث الأول: المواد المتعلقة بالقتل العمد:

المطلب الأول: المادة رقم ٤٣٤:

أولا: نص المادة:

نصت المادة (٤٣٤) على أن: (كل من ارتكب جريمة القتل يعاقب بالإعدام).

ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة.

يلاحظ أن المادة (٤٣٤) أصدرت حكما عاما بأن من ارتكب هذه الجريمة أن عقوبته القتل دون تفرقة بين القتل العمد، وشبه العمد، والخطأ، وكذلك بين من صدر منه القتل وغيره، وكذلك الحالات والملابسات التي وقع فيها القتل، ولكن بالرجوع إلى المواد الأخرى من القانون نجد أن المقصود من جريمة القتل ههنا هو ما عدا ما جاء في الاستثناءات وهو القتل العمد المحض، وهو قصد الجاني إزهاق روح المجني عليه، وذلك بضربه بسلاح حاد أو بما يغرق الجسم أو بشيء مثقل يقتل غالباً في مكان مميت قاصداً بذلك مجرد القتل و لم يكن القاتل والداً للمقتول، ولا قصد القتل دفاعا عن الشرف أو السمعة، ولا كان القتل بطلب اختياري من القتيل الكامل الأهلية.

ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة

وبعد معرفة المقصود من القتل في المادة يتبين أن ما ورد فيها من حيث العموم والجملة هو الأصل والأساس من عقوبة القتل لقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ﴾[1]. وقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ

(١) سورة البقرة، الآية:١٧٨

وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾ [1]. وغير ذلك من الآيات،

وفي السنة: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ))[2].

ولكن بالنظر والتأمل في المادة يتبين ما يأتي:

أولا: أن المادة لم تشر إلى أولياء المقتول، وأنهم هم الذين يملكون هذا الحق في المقام الأول، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴾[3]. ومن هنا كان نص المادة مخالفا لما في الشريعة الإسلامية.

ثانيا: أن المادة خلت عن الإشارة إلى إمكانية حصول العفو من أهل المقتول، والانتقال إلى الدية، أو العفو بدون أي مطالبة بالدية، كما هو بيّن في حكم القرآن حيث قال تعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾[4]، وهذا في العفو والانتقال من القصاص إلى الدية، وقوله تعالى: ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ﴾[5]، وهذا في العفو مطلقا من غير مطالبة بالدية.

---

(١) سورة المائدة، الآية:٤٥

(٢) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى (النفس بالنفس...) حديث رقم: ٦٨٧٨، ج٩، ص٥، ومسلم في كتاب القسامة، باب مايباح به دم المسلم، ج٣، ص١٣٠٢.

(٣) سورة الاسراء: الآية:٣٣.

(٤) سورة البقرة: الآية:١٧٨.

(٥) سورة المائدة: الآية٤٥.

ويمكن أن يقال إن المادة نصت على الحكم العام ولكن التفصيل بيد القاضي من حيث تحقيق مناط عقوبة الإعدام واتخاذ الخطوات التنفيذية، وذلك بالرجوع إلى أولياء المقتول وأخذ مشورتهم ومعرفة مواقفهم قبل تنفيذ العقوبة.

ومع ذلك تبقى إشكالية، وهي أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وأيضا نصت المادة على عقوبة الإعدام فكان ينبغي أن تنص أو تشير ولو بصورة مجملة إلى سلطان أولياء الدم.

ويمكن أن نشير ههنا إلى أن ولي الأمر أو الرئيس أو القاضي حسب الصلاحياته أن يحكم على القاتل بالإعدام تعزيراً أو حد حرابة حتى بعد عفو أولياء المقتول، وذلك إذا رأى أن بقاء مثل هذا المجرم في المجتمع يهدد الأمن العام، ويكون خطرا على نفوس المواطنين وذلك عملا بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾[1].

ولعل نص المادة لاحظ هذا التخويل أو السلطة فجاءت عامة من غير تفريق بين هذه المواقف، ولذا لم يستخدم لفظ القصاص وإنما قيل: الإعدام ليشمل القصاص وموقف الراعي[2]. معاً، ومهما يكن من شيء فإن التوضيح مطلوب رفعا للإشكالية. والله تعالى أعلم.

وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كبديل لصيغة هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي: **كل من ارتكب جريمة القتل العمد العدوان بلا شبهة ولم يكن أحد أصول المقتول يعاقب بالإعدام قصاصاً أو تعزيرا.**

المطلب الثاني: المادة ٤٣٥ قتل الأبناء دفاعا عن الشرف.

---

(١) سورة المائدة: الآية٣٣.

(٢) هو من ولي أمرا بالحفظ والسياسة كالملك والحاكم والرئيس، معجم الوسيط، ج١،ص ٣٥٦.

أولا: نص المادة:

١- كل من تسبب في وفاة الطفل بعد ولادتة مباشرة أو جنين أثناء ولادته دفاعاً عن الشرف الشخصي أو شرف أحد أصوله أو فروعه يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن عشرة سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

٢- يعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب هذه الجريمة

ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة.

صدرت المادة بلفظ كل وهو من ألفاظ العموم، مما يدل على أن هذه العقوبة الواردة فيها تشمل جميع من تسبب في وفاة الطفل، سواء كان والداً أم غيره، ولكن بالرجوع إلى المواد الأخرى مثل المادة رقم ٤٣٤: (**كل من ارتكب جريمة القتل يعاقب بالإعدام**)، وكذلك المادة ٤٣٦ في الفقرة الثانية: (**يعاقب الجاني بالإعدام إذا ارتكب الجريمة ضد شخص لم يبلغ الثامن عشر من عمره**) يتبين أن المقصود هنا بالقاتل هو أحد الوالدين كالأب مثلا أو الجد وإن علا، والأم أو الجدة وإن علت، لأن هذه الصفة تعد مانعة من القصاص، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل الوالد بولده)، ويؤكد ذلك عنوان المادة: قتل الأبناء دفاعاً عن الشرف. وبعد تحديد القاتل في هذه المادة، يجدر بنا النظر في الحكم الوارد فيها من حيث الموافقة والمخالفة للشريعة الإسلامية.

ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة

لم توجب المادة عقوبة الإعدام على الجاني في هذه الحالة، وذلك لكونه أحد أصول المجني عليه، وهذا طبعا موافق للشريعة الإسلامية، حيث قد أجمع الفقهاء على أن الوالد لا يقتل بولده ...

وأما فرض عقوبة السجن للمدة المذكورة فيمكن تخريجه على أن ذلك من باب التعزير، وسد الذريعة لئلا يتخذ مثل هذا النوع من القتل ذريعة إلى انتشار هذه الظاهرة بحيث يُعتدى على الأبناء بإزهاق أرواحهم لأتفه الأسباب.

والتعزير لا حد له، وإنما يرجع فيه إلى نظر الإمام أو القاضي واجتهاده، حيث يحدد العقوبة بما يحفظ الأمن والاستقرار وحفظ الأرواح، وعدم تفشي الفوضى وانتشار القتل، وربما يصل التعزير إلى القتل إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك.

وهنا ينبغي الإشارة إلى مسألة أغفلتها المادة، وهي: وجوب الدية على القاتل في هذه الحالة:

تجب على القاتل في هذه الحالة دية مغلظة في ماله الخاص، ويحرم عليه الميراث، كما جاء في عهد عمر رضي الله عنه، أن رجلاً قتل ابناً له عمداً فرفع إلى عمر بن الخطاب فجعل عليه مائة من الإبل: ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ثنية، وقال لا يرث القاتل شيئا، فلو لا أني سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ))[1]؛ لقتلتك[2].

وعليه فإن مضمون المادة من حيث العموم موافق للشريعة والسياسة الشرعية ومراعاة المصالح، وإن كانت ناقصة من جانب عدم التنصيص على الدية، وحرمان القاتل من الميراث وغيرذلك، إلا أنه يمكن أن يقال بأن المادة إنما نظرت فقط في القتل والعقوبة الأصلية فيه دون الجزئيات الأخرى. والله تعالى أعلم.

وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كتتميم لصيغة هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي: **كل من تسبب في وفاة الطفل بعد ولادتة مباشرة أو**

---

(١) أخرجه الترمذي في كتاب الديات، حديث رقم: ١٤٠٠، ج٣، ص٧٠. وإبن ماجه، اخرجه باب لا يقتل الوالد بولده، حديث رقم:٢٦٦١ ج٢، ص٨٨٨.

(٢) الزيلعي، جمال الدين، نصب الراية لآحاديث الهداية، باب ما يوجب القصاص، ج٤، ص٣٣٩.

جنين أثناء ولادته من أصوله دفاعا عن الشرف الشخصي أو شرف أحد أصوله أو فروعه يعاقب تعزيرا بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، مع وجوب الدية عليه من ماله الخاص وحرمانه من الميراث.

المطلب الثالث: المادة ٤٣٦ التسبب في موت شخص برضائه:

أولا: نص المادة:

نصت المادة (٤٣٦) على الآتي:

١- كل من تسبب في وفاة شخص برضاه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.

٢- يعاقب الجاني بالإعدام إذا ارتكب الجريمة:

أ- ضد شخص لم يبلغ الثامنة عشر من عمره.

ب- ضد شخص معتوه.

ج- ضد شخص تحصّل الجاني على رضاه بالعنف أو التهديد أو الإيحاء أوالتحايل.

ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة

تناولت هذه المادة في طيها بندين اثنين، البند الأول فيمن قُتل برضاه وكان هذا الرضا معتبرا في القانون. والبند الثاني على العكس من ذلك أي فيمن قُتل برضاه إلا أن رضاه غير معتبر إما لصغر سنه، وإما لسفهه وفقدان عقله، وإما لأن الرضا جاء نتيجة ظروف معينة كالتهديد أو العنف أو الإيحاء أو غير ذلك.

فأما البند الأول فقد نص على ارتكاب جريمة القتل بطلب من المقتول أو برضائه وكان رضا مثله معتبراً وصالحاً قانونياً، وحدد عقوبته بالسجن من ست سنوات كحد أدنى إلى خمس

عشرة سنة كحد أعلى، وإذا نظرنا إلى هذا القتل نجد أنه يندرج تحت القسم الأول من القتل وهو القتل العمد، ومرتكب هذه الجريمة يسمى قاتلاً عمداً في الشريعة.

ويلاحظ أن المادة صدرت بلفظ كل الدال على العموم والشمول مما يعني عدم التفرقة بين أن يكون القاتل أصلا للمقتول أو غير ذلك، إلا أن هناك مادة أخرى نصت على استثناء الوالد وتخصيصه بتخفيض العقوبة إلى نصف المدة المذكورة أو ثلثها وهي المادة ٤٤٢ حيث جاء فيها ما نصه:

(إذا ما أرتكب أحد الوالدين إحدى الجرائم المشار إليها فى المواد ٤٣٤[١]،٤٣٦[٢]،٤٣٨[٣]، ٤٤٠[١]، ٤٤١، فتعدل العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كالآتى:

---

(١) المادة (٤٣٤) (كل من ارتكب جريمة القتل يعاقب بالإعدام).

(٢) المادة(٤٣٦) **التسبب في موت شخص برضائه:**

نصت المادة "٤٣٦" على الآتي:

١- كل من تسبب في وفاة شخص برضاه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة.

٢- يعاقب الجاني بالإعدام إذا ارتكب الجريمة:

أ- ضد الشخص لم يبلغ الثامن عشر من عمره.

ب- ضد شخص معتوه.

ج- ضد شخص تحصّل الجاني على رضاه بالعنف أو التهديد أو الإيحاء أوالتحايل.

كل من تسبب في وفاة شخص برضاه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة.

٢- يعاقب الجاني بالإعدام إذا إرتكب الجريمة:

أ- ضد شخص لم يبلغ الثامن عشر من عمره.

ب- ضد شخص معتوه.

ج- ضد شخص تحصَّل الجاني على رضاه بالعنف أو التهديد أو الإيحاء أوالتحايل.

(٣) **المادة(٤٣٨) التحريض أو المساعدة علي الانتحار:**

أ- تخفض عقوبة الإعدام إلى السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.

ب- تخفض عقوبة السجن مابين النصف والثلث.

ومحل الشاهد هنا هو التقسيم الثاني (ب).وأما البند الثاني فهو فيمن قُتل برضاه أيضا إلا أن مثل هذا الرضا لا يعتبر في القانون، وحُددت عقوبته بالإعدام.

١- كل من حرض شخصا أو ساعده علي الإنتحار أوسهل له بأية وسيلة إرتكاب هذه الجريم يعاقب في حالة الوقوع الإنتحار بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي عشرة سنوات. فإدا لم تتم الجريمة الإنتحار فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز الخمس سنوات بشرط أن يترتب علي المحاول إصابة جسيمة أو شديدة الجسامة.

٢- تزداد العقوبة إذا كان الشخص الذي تعرض للتحريض أو المساعدة ممن يندرجون تحت إحدى الفئات المشار إليها في البندين أ،ب من الفقرة (٢) من المادة ٤٣٦. ومع ذلك فإذا لم يبلغ الشخص المدكور الرابعة عشر من عمره، أو كان ناقص الأهلية فتطبق الأحكام الخاصة بالقتل.

(٢) المادة (٤٤٠) **الإصابة**

١- كل من أصاب آحر إصابة نشأة عنها مرض جسمانى أو عقلى يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز عن ثلاثة سنوات .

٢- تعد الإصابة جسيمة وتوقع عقوبة السجن مدة لاتقل عن ثلاثة سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات.

أ- إذا نشأ عن الفعل مرض يهدد حياة المجنى عليه أ مرض أو عجز يمنعه عن مزاولة حرفته المعتادة لمدة أربعين يوما.

ب- إذا إقتضى الفعل إاى فعل مستديم فى حاسة أو عضو.

ج- إذا كانت المجنى عليها حبلى وأفضى الفعل إلى تعجيل الولادة.

٣- تعد الإصابة شديدة الجسامة وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ستة سنوات ولا تتجاوز إثنتى عشرة السنة إذا نجم عن الفعل:

أ- علة من المحقق أو من المرجح عدم شفاؤها.

ب- فقدان حاسة من الحواس.

ج- فقدان عضو أو بتره بحيث يصبح عديم الجدوى أو فقدان القدرة علي إستعمال عضو من الأعضاء أو فقدان المقدرة علي الأنجاب أو صعوبة مستديمة وحطيرة فى النطق.

د- تشوه الوجه أو عاهة مستديمة فيه.

ه- إجهاض المجنى عليها.

وهذا قتل عمد عدوان غير محفوف بأي شبهة يمكن أن تدرأ القصاص عن مرتكبه، وذلك لأن هذا الرضا ليس صحيحاً لأن الصغير والمجنون والمعتوه ليسوا أهلا للرضا، ولا يعتبر رضاهم نافذا في القانون، وكذلك من رضي عن طريق الإكراه والعنف والتهديد فرضاه أيضا غير معتبر في القانون.

ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة:

العقوبة التي حددها قانون العقوبات الجنائية في البند الأول هي السجن على كل من ارتكب مثل هذه الجريمة وإن كان هناك تفاوت في مدة السجن بين أن يكون الجاني أحد أصول المقتول (الوالدين) وبين أن يكون غير ذلك، و لم تقل بالقصاص في هذه الحالة، وبذلك تعتبر هذه العقوبة مخالفة لما حددته الشريعة الإسلامية من أن عقوبة القاتل المتعمد القصاص إذا لم يكن أحد أصول المقتول، أو الدية عند الانتقال إليها، إلا أن هناك إشكالاً هو أن هذه الجريمة جاءت نتيجة لرضا المقتول فهل يمكن اعتبار ذلك شبهة مسقطة لعقوبة القصاص أو أن الرضا في هذا المجال غير معتبر بل هو ملغى في نظر الشارع؟

ترى الباحثة أن رضا المقتول بقتله غير معتبر بل هو باطل بطلاناً مطلقاً، وذلك لأن رضاه أتى على غير محله، فإن الرضا يعتبر فيما يملكه الإنسان، أما ما ليس ملكا له فليس له أن يتنازل عنه بحال من الأحوال، وإذا تنازل لم يعتبر هذا التنازل، فحياة الإنسان ليست ملكا له، وإنما هي أمانة والمالك هو الله سبحانه وتعالى، وبذلك يصبح المقتول آثماً لأنه فرّط في الأمانة وارتكب ما نهى الله تعالى عنه في قوله: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓاْ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾[1]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾[2]. هذا في حق المقتول.

---

(١) سورة البقرة: الآية:١٩٥.

(٢) سورة النساء: الآية:٢٩.

وأما القاتل الذي أقبل على إزهاق روح غيره مدعيا أنه إنما قتله بطلب منه أو برضائه، وأن المقتول قد أبرأه من دمه، فهل يقبل منه ذلك ويشكل شبهة أو حجة مسقطة للقصاص عنه؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن القتل في هذه الحال لا يعتبر انتحارا، لكن لا يجب به القصاص، وتجب الدية في مال القاتل، هذا هو المذهب عند الحنفية ماعدا زفر، وإليه ذهب بعض الشافعية[١]، ورواه سحنون عن مالك[٢]، ووصفه بأنه أظهر الأقوال؛ لأن الإباحة لا تجري في النفوس، وإنما سقط القصاص للشبهة باعتبار الإذن، والشبهة لاتمنع وجوب المال، فتجب الدية في مال القاتل لأنه عمد، والعاقلة لا تحمل دية العمد[٣].

القول الثاني: أن القتل في هذه الحال قتل عمد، ولا يأخذ شيئاً من أحكام الانتحار، ولهذا يجب القصاص، وهذا قول عند المالكية، وإليه ذهب زفر من الحنفية[٤]، وبعض من الشافعية[٥]، لأن الأمر بالقتل لم يقدح في العصمة، لأن العصمة في النفوس مما لا تحتمل الإباحة بحال، وإذنه لا يعتبر لأن القصاص لوارثه لا له، ولأنه أسقط حقاً قبل وجوبه[٦].

القول الثالث: أن القتل في هذه الحال له حكم الانتحار، فلا قصاص على من قتله ولا دية، وهذا مذهب الحنابلة[٧]، والأظهر عند الشافعية [٨]، وهو رواية عند الحنفية[١]، ورواية مرجوحة في في مذهب مالك[٢].

---

(١) النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين ج٩ ص١٣٧.

(٢) عليش، محمد ابن أحمد، منح الجليل شرح مختصر الخليل ج٩ ص١١.

(٣) ابن النجيم، الأشباه والنظائر، ج١ ص١١٠، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج٧ ص١٨٠.

(٤) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج٧ ص١٨٠.

(٥) الغزالي، أبو حامد، **الوسيط في المذهب**، تحقيق:أحمد محمود، ط الأولى ١٤١٧، دار السلام- القاهرة ج٦ ص٢٦٤.

(٦) عليش، محمد ابن أحمد، **منح الجليل شرح مختصر خليل**، دار الفكر-بيروت، تاريخ: ١٤٠٩ه،١٩٨٩م ج٩ ص١٠.

(٧) المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج٩ ص٤٥٥، النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج٩ ص١٣٧.

(٨) الغزالي، الوسيط في المذهب، مرجع سابق.

ولئن كانت الباحثة قد ترجح لديها القول الأول القائل بأن الفرض أن يجب على الجاني القصاص ولكن سقط ذلك لوجود الشبهة المتمثلة في إذن المجني عليه بإنهاء حياته، وبفرض الدية على الجاني من ماله الخاص؛ إلا أن اعتماد القول الثالث في هذا المقام أنسب لعدم الحكم على القانون بمخالفة الشريعة، وذلك لإسقاطه القصاص والدية معا عن الجاني، وتبقى مسألة التعزير، فتكون العقوبة المذكورة في القانون من باب التعزير لاستتباب الأمن والاستقرار والمحافظة على حرمة النفوس، وبذلك لا تكون المادة مخالفة للشريعة الإسلامية، والله تعالى أعلم.

وتحددت العقوبة في البند الثاني من المادة بالإعدام أي قتل الجاني، إلا أن هذه العقوبة أيضا خاصة بالقاتل الذي لا يكون أصلا للمقتول، فإن كان من أحد الأصول فإنه ينتقل من الإعدام إلى السجن حسبما تقدم تفصيله، وبذلك تكون العقوبة الواردة في هذا البند مناسبة وموافقة للشريعة الإسلامية من حيث الأصل، وإن كان القانون قد أغفل دور أولياء المقتول في صلاحية الانتقال من القصاص إلى العفو وأخذ الدية، أو العفو من غير مطالبة بالدية، ومن هنا يمكن اعتبار القانون ناقصا في تحديد كل ما يتعلق بالقاتل في هذه الحالة.

وأما سجن القاتل الذي هو أصل للمقتول فهذا من باب التعزير، وأمر ذلك موكول إلى ولي الأمر والسلطان، فلا يكون في ذلك مخالفة للشريعة. والله تعالى أعلم.

وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كتتميم لصيغة هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية في نظرها، وهي:

١- كل من تسبب -من غير الوالدين- في وفاة شخص برضاه وكان رضاه معتبرا شرعا، يعاقب تعزيرا بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.

---

(١) الحدادي، أبو بكر، **الجوهرة النيرة**،طالأولى: ١٣٢٢، المطبعة الخيرية ج٢ ص٢٥٥.

(٢) المواق، محمد ابن يوسف،**التاج والإكليل لمختصر خليل**، ط الاولى:١٤١٦ه-١٩٩٤م، دار الكتب العلمية، ج٨أ ص٢٩٧.

٢- يعاقب الجاني غير الوالدين بالإعدام قصاصا أو تعزيرا إذا ارتكب الجريمة:

أ- ضد شخص لم يبلغ الثامن عشر من عمره.

ب- ضد شخص معتوه.

ج- ضد شخص تحصّل الجاني على رضاه بالعنف أو التهديد أو الإيحاء أوالتحايل.

المبحث الثاني: القتل الخطأ:

المطلب الأول: المادة ٤٤١

أولا: نص المادة:

كل من تسبب فى وفاة آخر بارتكابه فعلا من الأفعال المشار إليها فى المادتين (٤٣٩)[١]، و(٤٤٠)[٢]؛ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

---

(١) ونصها كما يأتي:

١- كل من تعدى على آخر بالضرب و لم ينجم عن هذا التعدى مرض جسمانية أو عقلية يعاقب بناء على الشكوى المجنى عليه بالسجن مدة أقصاها ستة شهور أو بغرامة أقصاها ثلاثة آلاف شلن صومالى.

٢- لايطبق الحكم السابق إذا اعتبر القانون الفعل ركنا أوظرفا مشددا فى جريمة أخرى.

(٢) ونصها كما يأتي:

١-كل من أصاب آخر إصابة نشأة عنها مرض جسمانى أو عقلى يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز ثلاثة سنوات .

٢- تعد الإصابة جسيمة وتوقع عقوبة السجن مدة لاتقل عن ثلاثة سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات:

أ- إذا نشأ عن الفعل مرض يهدد حياة المجنى عليه أ مرض أو عجز يمنعه عن مزاولة حرفته المعتادة لمدة أربعين يوما.

ب- إذا إقتضى الفعل إاى فعل مستديم فى حاسة أو عضو.

ج- إذا كانت المجنى عليها حبلى وأفضى الفعل إلى تعجيل الولادة.

٣- تعد الإصابة شديدة الجسامة وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ستة سنوات ولا تتجاوز إثنتى عشرة السنة إذا نجم عن الفعل:

ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة للمادة

بالنظر إلى هذه المادة والمادتين المشار إليهما (٤٣٩ و ٤٤٠) كما في الهامش، يمكن القول بأن نوع القتل ههنا هو الخطأ أو شبه العمد عند من يقول به، وذلك لأن المادة نصت على التعدي بالضرب، يعني لم يكن القصد من الضرب قتل المضروب، وهذا طبعا مشروط بألا يكون هذا الضرب بشيء يقتل مثله غالبا كآلة مثقلة من حجر أو عصا أو غير ذلك، فإن كان ثمت فيكون الحكم قتلا عمدا عند الجمهور، وشبه عمد عند الحنفية على ما سبق بيانه.

وإنما كان هذا القتل خطأ لأن الضارب لم يكن يقصد بهذا الضرب قتل المضروب، غاية ما في الأمر أنه قصد إيقاع الضرب بغير حق، وقد بينت المادة أن عقوبة هذا المتعدي الذي أدى ضربه إلى وفاة المضروب هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

وبالنظر إلى الاستثناءات الواردة على المادة فيمكن القول بأن الجاني أو المتعدي بالضرب إما أن يكون أحد أقرباء المجني عليه أو لا يكون كذلك.

فإن كان أحد أقرباء المجني عليه، فإما أن يكون التعدي ابتداء وإما أن يكون نتيجة ظروف وملابسات، كأن يجد بنته أو زوجه أو أخته في حالة ارتكاب معصية كبيرة كالزنا مثلا.

فإن كان التعدي ابتداء بلا سبب، فإن القانون لم يفرق في هذه الحالة بين القريب وغيره فتطبق ذات العقوبة عليه.

أ- علة من المحقق أو من المرجح عدم شفاؤها.

ب- فقدان حاسة من الحواس.

وأما إن كان التعدي بسبب ظروف وملابسات؛ فإنه لا عقوبة على الجاني في هذه الحالة حسب نص القانون.

وأما إذا لم يكن المتعدي أحد أقرباء المجني عليه، فإما أن يكون التعدي ابتداء، وإما أن يكون نتيجة ظروف وملابسات كأن يجد المجني عليه يرتكب الفاحشة مع أحد قريباته من بنت أو أخت أو زوج، فإن كان الثاني فإن عقوبته تخفف فتتراوح ما بين السنتين إلى ثمان سنوات، أما إن كان الأول وهو التعدي ابتداء فتُطبَّق عليه العقوبة الواردة في المادة.

وبعد التحليل والاطلاع على الاستثناءات الواردة على المادة، ومعرفة نوعية القتل التي هي القتل الخطأ أو شبه العمد فسوف نقارن الحكم الوارد في المادة بالحكم الشرعي لمعرفة الموافقة والمخالفة

ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقةوالمخالفة

لقد تقدم آنفا أن نوع القتل في المادة (٤٤١) هو القتل الخطأ أو شبه العمد وعليه فإن الشريعة لا تفرق بين القريب وغيره في هذه الحالة بل تسوي بينهما وتكون عقوبته هي المطالبة بالدية إضافة إلى تحرير الرقبة أو صيام شهرين متتابعين لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ ﴾[1].إلى آخر الآيات.

وعليه فيمكن القول بأن الاستثناء الوارد في المواد الأخرى من القانون لا أساس لها في نظر الشارع، إلا أن تكون العقوبة الواردة من باب التعزير وذلك باب واسع متروك لنظر الإمام واجتهاده، ولكن التعزير لا يقوم مقام الحد أو الدية والكفارة وإنما يضاف إليها. والله تعالى أعلم.

---

(١) سورة النساء، الآية:٩٣.

وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كبديل لصيغة هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي:**كل من تسبب فى وفاة آخر بإرتكابه فعلاً من الأفعال التي لا تقتل غالباً كالضرب بما لا يقتل عادة ونحوه يعاقب تعزيراً بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة إضافة إلى إلزامه بدفع الدية.**

المطلب الثاني: المادة٤٤٣القتل أو الإصابة دفاعا عن الشرف:

أولا: نص المادة

١- كل من فاجأ زوجه أو إحدى بناته أو أخواته في حالة زنا فقتل فى ثورة غضب جامحة زوجه أو بنته أو أخته دفاعا عن شرفه وشرف الأسرة.

وتسرى العقوبة ذاتها على كل من يتسبب وهو فى نفس الظروف فى موت الطرف الآخر الذى يفاجئه أثناء ارتكابه الزنا مع زوجه أو بنته أو أخته؛ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.

٢- إذا تسبب الجاني وهو في ذات الظروف في إصابة أحد من الأشخاص المذكورين آنفا فتخفض العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٤٤٠ بواقع الثلث .

فإذا حدثت الوفاة نتيجة الإصابة فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن السنتين ولا تتجاوز ثماني سنوات.

٣- لا عقاب على الشخص الذى ارتكب ضد الأشخاص المذكورين آنفا الفعل المشار إليه فى المادة ٤٣٩ وكان واقعاً تحت نفس الظروف.

ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة:

بالنظر إلى نص هذه المادة نجد أن المجني عليه (المقتول) متلبس بارتكاب الفاحشة، سواء كان قريبا أم غيره، وإنما قسمت المادة القتل إلى قسمين:

الأول: أن يعتدي الجاني على المجني عليه بقتله مباشرة.

الثاني: أن يعتدي الجاني على المجني عليه بالضرب ويؤدي هذا الضرب إلى وفاته حالا أو لاحقا.

فالعقوبة الواردة على الجاني في القسم الأول، وهو أن يعتدي الجاني على المجني عليه بالقتل مباشرة هي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر.

وبإمعان النظر نجد أن نوع القتل في هذه الحالة حسب نظر الشارع هو القتل العمد العدوان، وذلك لإقبال الجاني على ارتكاب الجريمة بغض النظر عن السبب الداعي إليه.

والعقوبة الواردة على الجاني في القسم الثاني، وهو أن يعتدي الجاني على المجني عليه بالضرب أو الإصابة فتؤدي إلى وفاته هي السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز ثمان سنوات.

وبتدقيق النظر أيضا نجد أن نوع القتل حسب نظر الفقه الإسلامي هو القتل الخطأ أو شبه العمد عند من يقول به، وعليه فيعامل الجاني على هذا الأساس.

وبعد تحديد نوعية القتل في الحالتين آن الأوان أن نقارن ما ورد في المادة من عقوبة بالشريعة الإسلامية.

ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة

لقد تقدم أن نوع القتل في القسم الأول هو العمد العدوان، إلا أن المادة جعلت عقوبته السجن فقط من غير تفريق بين أن يكون القاتل أصلا للمقتول أو لا، وبذلك تكون المادة قد خالفت الشريعة من وجهين:

الأول: عدم إيجاب عقوبة القتل العمد العدوان على القاتل.

الثاني: عدم التفريق بين أن يكون القاتل أصلا للمقتول أو لا.

وقد تقدم غير مرة أن عقوبة القتل العمد العدوان في الشريعة الإسلامية هي القصاص أو بدله وهو الدية أو عفو أهل المجني عليه إلا أن يكون القاتل أصلا للمقتول فيسقط القصاص في هذه الحالة، وبذلك نجد أن المادة مخالفة لحكم الشريعة الإسلامية.

وهنا ينبغي الإشارة إلى موضوع مهم وهو ارتكاب القتل دفاعا عن الشرف وفيه التفصيل الآتي:

أولا: إذا كان القاتل أصلاً للمجني عليه فرأى بنته في حالة الزنا فقتل في ثورة من الغضب فلا قصاص عليه، لأنه لا قصاص بين الفرع والأصل في الظروف العادية فمن باب أولى في مثل هذه الظروف كما قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يقتل الوالد بولده)).

أما إذا قتل الطرف الآخر الذي وجد متلبسا بحالة الزنا مع ابنته فيجب في حقه أحد أمرين:

أولا: أن يأتي ببينة (أربعة شهداء) أنه فعلا رأى مع ابنته وهو يزني، وأن يكون الزاني محصنا ففي مثل هذه الحالة لا قصاص عليه ولا دية عند بعض العلماء كما سيأتي.

وأما إيجاب القانون السجن على القاتل فإنما يخرّج ذلك على أنه عقوبة تعزيرية لاستتباب الأمن وحماية النفوس من التعدية عليها بدعوى الدفاع عن الشرف فيتخذ ذريعة للقتل، والعقوبات التعزيرية ليس لها حد في الشريعة الإسلامية وإنما يترك الأمر فيها للقاضي يحكم بما يراه مناسبا، وعليه فلا إشكال في وجود هذه العقوبة.

ثانيا: ألا يأتي ببينة أصلا، أو أتى ببينة وكان الزاني غير محصن فعقوبته حينئذ هي القصاص أو الدية أو العفو لأنه قتل عمد عدوان لغير الفرع، ولا تعتبر دعوى الدفاع عن الشرف، وبذلك يعلم أن القانون خالف الشريعة في هذه الحالة حيث لم يوجب القصاص ولا الدية على القاتل وإنما اكتفى بإيجاب السجن عليه فقط. والله تعالى أعلم.

أما إذا كان القاتل زوجا فإما أن يقتل زوجته أو الطرف الآخر أو هما معا، وعلى كلا التقديرين فإن العلماء اتفقوا على أنه يجب على القاتل إقامة البينة فيما ادعاه لإسقاط القصاص عنه،

وأنه إذا لم يقم بينة فعليه القصاص، واتفقوا كذلك على أنه إن أقام البينة وكان الجاني ثيبا أنه لا دية عليه، واختلفوا في البكر على قولين:

القول الأول: عليه الدية وبه قال الحنفية والمالكية.

القول الثاني: لا دية عليه وبه قال الحنابلة وابن القاسم من المالكية، وقول عند الشافعية[1].

وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كبديل لصيغة هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي:

١- كل من فاجأ زوجه أو إحدى بناته فى حالة زنا فقتل فى ثورة غضب جامحة زوجه أو بنته دفاعا عن شرفه وشرف الأسرة وأقام بينة على ما ادعاه يعاقب تعزيرا بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.

٢- كل من فاجأ إحدى أخواته فى حالة زنا فقتل فى ثورة غضب جامحة أخته أو الطرف الآخر دفاعا عن شرفه وشرف الأسرة وأقام بينة على ما ادعاه يعاقب تعزيرا بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، أما إذا لم يقم البينة فعليه القصاص أو بدله.

٣- إذا تسبب الجاني وهو فى ذات الظروف في إصابة أحد من الأشخاص المذكورين آنفا وأقام البينة فتخفض العقوبة التعزيرية المنصوص عليها فى المادة ٤٤٠ بواقع الثلث.

فإذا حدثت الوفاة نتيجة الإصابة فيعاقب تعزيرا بالسجن مدة لا تقل عن السنتين ولا تتجاوز ثماني سنوات إضافة إلى إلزامه بدية القتل الخطأ.

---

(١) انظر تفاصيل المسألة في: بدر الدين العيني، أبو محمد، **عمدة القاري شرح صحيح البخاري**، دار إحياء التراث العربي بيروت، ج:٢٤،ص:٢١، القرافي، أبو العباس، **الذخيرة**، المحقق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي –بيروت، ط الأولى: ١٩٩٤م،ج٤، ص٢٩٦، الماوردي، الحاوي الكبير، ج١٣،ص٤٥٧، ابن قدامة، المغني، ج٩، ص١٨٤، ابن المفلح، برهان الدين، **المبدع في شرح المقنع**، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان،ط الأولى:١٤١٨ه،١٩٩٧م ج٧،ص٤٦٤.

المطلب الثالث: المادة ٤٤٥

أولا: نص المادة

١- كل من تسبب فى موت آخر بإهماله الناشئ عن خطئه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تتجاوز خمس سنوات.

٢- تطبق احكام المادة "٤٤" في حالة وفاة أكثر من شخص أو وفاة شخص وإصابة شخص أو أكثر على ألا تتجاوز العقوبة في مجموعها اثنتي عشرة سنة.

ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة

بين نص المادة ٤٤٥ من قانون العقوبات الجنائية أن كل من تسبب في موت آخر بإهماله الناشيء عن خطئه وعدم اهتمامه أو أخذه الحذر والحيطة الذي نشأ عن خطئه هي السجن مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تتجاوز خمس سنوات، وذلك حسب شناعة الفعل، وحسب حال القاتل في نظر القاضي.

فيحتمل نص هذه المادة من القانون الصور التالية للتسبب في القتل بالإهمال:

أولا: أن يكون المتسبب قد أحدث في المكان العام شيئا يؤدي إلى قتل الناس، كحفر البئر في الطريق العام من غير وضع إشارة أو حائط عليها فيقع فيها أحد المارين فيموت.

ثانيا: أن يركِّب أو يضع شيئا حادا أو ثقيلا في مكان عال بدون إحكام فيقع على أحد فيقتله.

ثالثا: أن يرى شخصاً غير راشد أو غير قادر على إنقاذ نفسه مقبلا على هلاكه وهو قادر على إنقاذه أو صرفه فلم يفعل، كما لو رأى صغيراً مقبلاً على النار، أو أعمى مقبلاً على حفرة عميقة أو شارع عام، أو رأى غريقا يستغيث أو غير ذلك وهو قادر على الإنقاذ فلم يفعل، فهذا نوع من الإهمال.

ويلاحظ في الصورة الأولى والثانية أن القتل هنا بالتسبب بالفعل حيث إن هذا الشخص بإهماله وعدم أخذه الحذر والاحتياط تسبب في القتل، وهذا ولا شك أنه قتل شبه عمد عند من يقول به، أو عمد عندمن لا يرى شبه عمد، ويسمى القتل بالتسبب.

وأما في الصورة الثالثة، فإن نسبة القتل إلى الشخص فيها مبنية على مسألة مشهورة عند العلماء وهي: هل الترك يعتبر فعلا بحيث يؤاخذ به التارك، أو لا يعتبر فعلا فلا يؤاخذ؟

فيه خلاف بين العلماء ذكره صاحب المذكرة في أصول الفقه فقال: "الثالث : الترك والتحقيق أنه فعل وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، خلافاً لمن زعم أن الترك أمر عدمى لا وجود له ، والعدم عبارة عن لا شيء، والدليل على أن الترك فعل الكتاب والسنة واللغة.

وأما دلالة الكتاب على أن الترك فعل ففى آيات من القرآن العظيم كقوله تعالى : ﴿ لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ﴾ ، فسمى الله جل وعلا عدم نهى الربانيين والأحبار لهم صنعاً والصنع ارخص مطلقاً من الفعل فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فعل بدليل تسمية الله له صنعاً . وكقوله تعالى: ﴿ كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴾ فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا وهو واضح و لم أر من الأصوليين من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل، وقال السبكي في طبقاته[1]: إن قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُوا۟ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾[2]؛ يدل على أن الترك فعل، قال: لأن الأخذ التناول والمهجور المتروك فصار المعنى تناولوه متروكا أي فعلوا تركه هكذا قال.

---

(١) السبكي، تاج الدين،**طبقات الشافعية الكبرى**، المحقق: د.محمود الطناحي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط الأولى: الثانية ١٤١٣ه، ج١، ص١٠٠.

(٢) سورة الفرقان: الآية: ٣٠.

وأما دلالة السنة: ففى أحاديث كقوله: ((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ))[1]. فسمى ترك الأذى إسلاماً وهو يدل على أن الترك فعل.

وأما اللغة فكقول الراجز.

لئن قعدنا والنبي يعمل، لذاك منا العمل المضلل.

فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد، وقد سمى هذا الترك عملا فى قوله: لذاك منا العمل المضلل[2].

وهذا الذي يترجح لدى الباحثة أن الترك قسم من أقسام الأفعال، وبقي الآن النظر في هذا التارك من حيث العقوبة المحددة له في الشريعة الإسلامية، فقد اتفق العلماء على أن التارك لغيره حتى يهلك وهو قادر على إنقاذه أنه آثم بهذا الترك، ولكن هل يجب عليه الضمان؟ فهذا الذي وقع في الخلاف على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

قال الحنفية والشافعية: لا يجب الضمان على من ترك أو منع الطعام للمحتاج حتى مات[3].

القول الثاني:

---

(١) البخاري، **صحيح البخاري مع الفتح**، حديث رقم: ١٠، ج١، ص١١.

(٢) الشنقيطي، محمد الأمين بن المختار، **مذكرة في أصول الفقه**، ص٣٧.

(٣) النووي، **روضة الطالبين وعمدة المفتين**، ج٣، ص٢٨٥.، الخطيب، الشربيني، **مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج**، ج٥، ص٣٥٤.

ذهب المالكية إلى وجوب الضمان على من ترك المضطر القابل على الهلاك، فاتفقوا على أن الضمان يكون بالدية إذا لم يقصد بالامتناع القتل، أما إذا قصد بالامتناع قتل الطرف الآخر فلهم في ذلك قولان: الأول: يكون الضمان القصاص، والثاني: يكون الضمان الدية. [1].

القول الثالث:

للحنابلة في وجوب الضمان على شخص يمكنه إنجاء غيره من هلكة فلم يفعل وجهان:

الوجه الأول: لا يضمنه إذا لم يسأل العون كما لو لم يعلم بحاله.

الوجه الثاني: إذا سأل و لم يفعل يضمن، وضمانه الدية[2].

وبعد تمحيص الأقوال الثلاثة ترى الباحثة أن الراجح في هذاما قالته المالكية وهو: لزوم الضمان، ويكون الضمان إما الدية؛ وهو إذا لم يقصد القتل بامتناعه، أو القصاص؛ إذا امتنع من المساعدة عمدا، كمن رأى صغيراً قابلاً على النار فلم يمنعه، أو غريقا وهو قادر على إنقاذه فلم يفعل، وإنما يسقط القصاص لوجود الخلاف في اعتبار الترك فعلا، وإنما رجحت الباحثة هذا القول وذلك لحماية النفوس وإلزام كل واحد في المجتمع بالدور الذي يستطيع القيام به تجاه مجتمعه، فيسود التعاون والتعاضد على البر والإحسان الذي حث عليه الكتاب والسنة.

ويلاحظ أن نص القانون لم يعط أي توضيح لصورة القتل المقصودة ههنا، ولكن هذه الصور التي ذكرناها كافية في تصوير المسألة.

ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة

---

(١) محمد ابن أحمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج٢، ص١١٢.

(٢) ابن المفلح، الفروع،ج٩، ص٤٣٢،٤٣١.

فأولا: لم يفرق النص بين أن يكون هذا المتسبب والدا أو غيره، وهذا شيء طيب في حالة اعتبرنا العقوبة هنا مجرد تعزير، كما هو وارد في بعض الصور، خاصة في الصورة الثالثة التي ذكرناها في حالة أن الترك لم يعتبر فعلا وهو مرجوح لدى الباحثة، فتكون العقوبة الواردة في نص المادة تعزيرية، وهذا مناسب لحال أولئك الذين يمتنعون عن التعاون والمساعدة في حال استطاعتهم مما يعني عدم اهتمامهم بإخوانهم وهذا يتناقض مع مبدأ التضامن والتكامل الاجتماعي المطلوب في المجتمع المسلم فيؤدي إلى التباغض وعدم الاستقرار والثقة بين الأفراد مما يسبب بلبلة في نظام الدولة وأمنها، فيكون لزاما على ولي الأمر والقاضي أن يضعوا عقوبة تناسب حال هذا الصنف من الناس.

وأما إذا اعتبرنا الترك فعلا كما هو الراجح لدى الباحثة،فهذا يكون قتلاً خطأ أو شبه عمد كما هو بيّن في الصور الثلاثة التي تقدم ذكرها؛ فإن حكم المادة بهذا الاعتبار يعد قاصرا عن بيان ما جاء في الشريعة الإسلامية من أن القتل الخطأ وشبه العمد عقوبته دية مسلّمة إلى أهل المقتول وتحرير رقبة أو الصيام في حال عدم وجود الرقبة بالتفصيل الذي تقدم غير مرة. والله تعالى أعلم.

وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كبديل لصيغة هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي: **كل من تسبب فى موت آخر بإهماله الناشئ عن خطئه يعاقب تعزيرا بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تتجاوز خمس سنوات إضافة إلى إلزامه بدفع الدية.**

الخلاصة:

وبعد دراسة وتحليل المواد المتعلقة بهذا الفصل، وبيان التكييف الفقهي لنوع الجريمة الواردة في كل مادة، ومقارنتها بالشريعة الإسلامية لبيان الموافقة والمخالفة تبين ما يأتي:

أولا: أن هناك موادا وافقت العقوبات الواردة فيها الشريعة الإسلامية من أكثر الجوانب وذلك بعد عرضها على المذاهب الفقهية المعتمدة، وهذه المواد هي:

المادة "٤٤١"، ٤٣٦، ٤٤٣، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٦.

المادة ٤٣٦:

الجريمة التي وردت في المادة:

وردت في المادة نوعان من الجريمة: الأول: قتل شخص برضائه مع كون رضاه معتبرا في القانون. والثاني قتل شخص برضائه مع كون رضاه غير معتبر في القانون.

العقوبة التي وردت في القانون:

ففي النوع الأول: يسجن الجاني مدة تتراوح ما بين ست سنوات إلى خمس عشرة سنة.

وفي النوع الثاني: يقتل الجاني.

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف هذه الجريمة في الفقه الإسلامي على أنها قتل عمد عدوان.

نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:

فبعد المقارنة وجد أن القانون وافق الشريعة الإسلامية في عقوبة الجاني في النوع الثاني وهي القصاص (الإعدام) إلا أن فيه قصوراً من ناحية عدم إعطاء حق العفو لأولياء الدم، وأما في النوع الأول فليست هناك مخالفة أيضاً في عدم قتل القاتل على مذهب كل من الحنفية والشافعية والحنابلة، إلا أن الحفنية يرون وجوب الدية على القاتل من ماله الخاص فيكون القانون قاصراً من هذا الجانب، وخالف القانون الشريعة على مذهب المالكية والظاهرية الذين أوجبوا القصاص على الجاني.

المادة ٤٤١:

الجريمة التي وردت في المادة:

وردت في المادة جريمة القتل غير المباشر أي التسبب في وفاة شخص عن طريق الضرب أو الإصابة البالغة التي نتج عنها موته.

العقوبة التي وردت في القانون:

السجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات ولا تتجاوز خمسة عشر سنة

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف الجريمة الواردة في المادة على أنها قتل خطأ أو قتل شبه عمد عند من يقول به.

نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:

فبعد المقارنة وجد أن القانون لم يخالف الشريعة الإسلامية في عدم الحكم على الجاني بالقتل وذلك لكون القتل خطأ أو شبه العمد، ويمكن اعتبار العقوبة الواردة فيه (السجن) من باب التعزير، ولكن القانون لم يذكر عقوبة القتل الخطأ التي هي الدية وتحرير الرقبة أو الصوم عند

عدمها وبذلك يعتبر قاصرا في بيانه لعقوبة القتل الخطأ أو شبه العمد، وما ورد فيه من استثناءات ليس لها اعتبار في نظر الشارع.

المادة "٤٤٣"

الجريمة التي وردت في المادة:

وردت في المادة جريمة القتل أو الإصابة المؤدية إلى الوفاة دفاعاً عن الشرف.

العقوبة التي وردت في القانون:

في حالة القتل المباشر دفاعا عن الشرف يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.

وفي حالة القتل بسبب الإصابة دفاعاً عن الشرف يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن السنتين ولا تتجاوز ثماني سنوات.

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف هذه الجريمة في الفقه الإسلامي على أنها قتل عمد عدوان، هذا في النوع الأول

أما في النوع الثاني فقد كُيّف على أنه قتل خطأ أو قتل شبه عمد عند من يقول به.

نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:

فبعد المقارنة وجد أن القانون خالف الشريعة في النوع الأول من ناحيتين:

الأولى: عدم إيجاب القصاص على الجاني وقد ارتكب القتل العمد العدوان.

الثاني: عدم التفريق بين أن يكون القاتل أصلا للمقتول أو لا.

وأما في النوع الثاني فإن القانون لم يخالف في عدم إيجاب القصاص، ولكنه قصّر في بيان إيجاب الدية وتحرير الرقبة أو الصوم على الجاني.

المادة (٤٣٤)

الجريمة التي وردت في المادة:

وردت في المادة جريمة القتل مطلقا وبلفظ عام.

العقوبتة التي وردت في القانون:

العقوبة الواردة في القانون هي الإعدام.

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف هذه الجريمة في الفقه الإسلامي على أنها قتل عمد محض.

نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:

فبعد المقارنة وجد أن القانون وافق الشريعة الإسلامية في الجملة، وإن كان قد أغفل بعض الجوانب المتعلقة بهذا القتل من أحكام، كسلطان أولياء الأمور على القصاص، أو العفو ببدل وهو الدية أو العفو بلا بدل، وكذلك كون القاتل أصلاً للمقتول.

المادة ٤٣٥:

الجريمة التي وردت في المادة:

قتل الطفل بعد ولادته أو جنين أثناء ولادته دفاعا عن الشرف الشخصي أو شرف أحد الأصول أو الفروع.

النوع الثاني: التحريض على ارتكاب مثل هذه الجرائم.

العقوبة التي وردت في القانون:

السجن مدة لاتقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف هذه الجريمة على أنها قتل عمد، بواسطةأحد الوالدين كالأب مثلا أو الجد وإن علا، والأم أو الجدة وإن علت.

نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:

فبعد المقارنة وجد أن القانون وافق الشريعة الإسلامية من حيث الجملة في عدم إيجاب القصاص على الجاني لكونه أحد أصول المجني عليه، وقد أجمع الفقهاء من حيث الجملة على أن الوالد لا يقتل بولده، وإنما أوجب القانون عقوبة السجن ويمكن اعتبارها من باب التعزير.

إلا أن القانون ناقص من جانب عدم التنصيص على الدية، وحرمان القاتل من الميراث وغيرذلك، ويمكن أن يقال بأن المادة إنما نظرت فقط في القتل والعقوبة الأصلية فيها دون الجزئيات الأخرى. والله تعالى أعلم.

ثانيا: أن هناك موادا تبدو في ظاهرها مخالفة، ولكن يمكن تخريجها بما يصححها ويجعلها موافقة لروح الشريعة الإسلامية، وهذه المواد هي: ٤٤٥

المادة٤٤٥:

الجريمة التي وردت في المادة:

وردت هذه المادة جريمة التسبب فى موت شخص بالإهمال والترك.

العقوبة التي وردت في القانون:

عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تتجاوز خمس سنوات.

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف هذه الجريمة على أنها قتل خطأ أو شبه عمد بفعل الجاني في الصورتين الأوليين اتفاقا، وفي الصورة الثالثة بناءاً على أن الترك فعل.

نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:

فبعد المقارنة وجد أن القانون لم يخالف الشريعة الإسلامية في عدم معاقبة الجاني بالقصاص إذا اعتبرنا هذا القتل خطأ أو شبه عمد، كما هو بيّن في الصورة الأولى والثانية، وكذلك في الثالثة عند من اعتبر الترك فعلا؛ ولكن بالنظر إلى أن القانون لم يقض بمطالبة الجاني بالدية والتحرير أو الصوم فإنه يعتبر قاصراً. والله تعالى أعلم

الفصل الثاني: السرقة وعقوباتها في القانون الصومالي.

وفيه توطئة ومبحثان، وخلاصة:

التوطئة: في بيان ما يتعلق بالسرقة من أحكام في الفقه الإسلامي، وسرد المواد المتعلقة بالسرقة في نظام العقوبات الجنائية الصومالي.

الفرع الاول: بيان ما يتعلق بالسرقة من أحكام في الفقه الإسلامي

تعريف السرقة:

إن الإسلام قد حرص على المال فشرع ما يضمن حفظه من كل الجوانب (جانب الوجود وجانب العدم) وجعله أحد الضروريات الخمس التي يجب حفظها والذود عنها، ومن حكمة الله تعالى ورحمته بخلقه أنه فرض العقوبة على كل من اعتدى على مال الغير فأخذه خفية، وجعل هذه العقوبة هي قطع يد سارق جزاء له فقال: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [1]. وسوف نتناول في هذا المطلب تعريف السرقة في اصطلاح أهل الفقه فنقول:

لا يختلف التعريف الاصطلاحي عن التعريف اللغوي كثيرا إلا أن بعض الفقهاء أضافوا في التعريف الاصطلاحي بعض القيود التي هي من شروط القطع وليس لمطلق السرقة.

وسنورد بعض التعريفات المتعلقة للسرقة لدى المذاهب الأربعة:

تعريف الحنفية:

"أخذ الشيء من الغير على وجه الخُفْيَة بغير الحق"[2].

تعريف المالكية:

أخذ مكلف نصاباً من مال محترم لغيره، خفية بلا شُبْهة[3].

تعريف الشافعية:

"أخذ مال الغير خفية من حِرْزُ مثله بشروط مخصوصة"[4].

---

(١) سورة المائدة: الآية: ٣٨.

(٢) ابن نجيم، بحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج:٥ ص٥٤.

(٣) الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف ج: ٤،ص:٤٦٩.

(٤) الرملي، نهاية المحتهد إلى شرح المنهاج ج:٧ ص:٤٣٩.

تعريف الحنابلة:

" أخذ مال محترم لغيره على وجه الاختفاء، وإخراجه من حرز مثله ولا شبهة له " [1].

فبالنظر إلى هذه التعريفات في المذاهب الأربعة نجد أنهم يتفقون على أن السرقة هي أخذ مال الغير على سبيل الاختفاء وبغير حقه أو بلا شبهة.

أنواع السرقة:

السرقة في الشريعة الإسلامية نوعان:

١- سرقة عقوبتها الحد. ٢- وسرقة عقوبتها التعزير.

فالسرقة التي عقوبتها الحد نوعان هما: السرقة الصغرى، والسرقة الكبرى

فالسرقة الصغرى: هي أخذ مال الغير خفية.

أما السرقة الكبرى فهي أخذ مال الغير على سبيل المغالبة، وتسمي الحرابة[2]. ، ولا تدخل في هذا الموضوع، فيقتصر كلامنا على السرقة الصغرى.

شروط السرقة (أي الشروط التي يجب توفرها في السرقة لإقامة الحد على السارق):

---

(١) البهوتي، كشاف القناع ج٦ ص:٦١٢.

(٢) ابن عابدين، محمد أمين، **رد المحتار على در المختار**، ط:الثانية ١٤١٢ه-١٩٩٢م دار الفكر- بيروت ج:٤،ص:٨٢

فالشروط في السرقة أنواع بعضها يرجع إلى السارق، وبعضها يرجع إلى المسروق، وبعضها إلى المسروق منه وبعضها يرجع إلى المسروق فيه.

أولا: الشروط التي ترجع إلى السارق:

فأما الشروط التي ترجع إلى السارق فاثنان هما:

١- العقل.

٢- والبلوغ، لأن الأهلية شرط لوجوب القطع فلا يقطع يد صغير، ولا مجنون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنّ: ((القَلَمَ رُفِعَ عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ))[١].

ولأن القطع عقوبة فيستدعي جناية، وفعلهما لا يوصف بالجنايات، ولهذا لم يجب عليهما سائر الحدود، ولكن السارق إن كان يجن مدة ويفيق أخرى، فإن سرق في حال جنونه لم يقطع وإن سرق في حال الإفاقة قطع[٢].

ثانيا: الشروط التي ترجع إلى المسروق:

وأما المسروق فإن له شرائط مختلف فيها فمن أشهرها:

أولا: النصاب:

اتفق الأئمة الأربعة على اشتراط النصاب في المال المسروق حتى يعتبر سرقة موجبة للقطع، ولكنهم اختلفوا في مقدار النصاب الموجب للقطع على أقوال:

---

(١) البحاري، **صحيح البحاري مع الفتح**، كتاب الحدود، ج٨، ص١٦٥.

(٢) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، ج٧، ص:٦٧.

القول الأول: أن النصاب الموجب للقطع هو عشرة دراهم فما فوقها، وبه قال الحنفية[1].

دليل هذا القول: لما رواه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ[2] كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ[3].

القول الثاني: أن النصاب الموجب للقطع هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم وبه قال المالكية[4]. والشافعية[5]. والحنابلة[6]. في أصح الروايات عنهم.

دليل هذا القول ما روي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا))[7].

ثانيا: أن يكون مالا مطلقاً لا قصور في ماليته:

وهو أن يكون مما يتموله الناس، ويعدونه مالاً، وما لا يتموله الناس فهو تافه، ولا قطع في مال تافه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كَانَتْ الْيَدُ لَا تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ))[8].

---

(١) السرخسي، المبسوط، ،ج:٩،ص:١٣٧.

(٢) المجنّ من الجنة وهي السترة والميم زائدة، والمراد به في الحديث التُّرْس أو التِّرَسَة. انظر: ابن الأثير، **النهاية في غريب الحديث والأثر**، ج٤، ص ٦٢٥.

(٣) النسائي، **سنن النسائي**، حديث رقم: ٤٩٥٦، ج٨، ص٨٤. الترمذي، **سنن الترمذي**، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، ج٣، ص١٠٣.

(٤) ابن الرشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج٤، ص٢٣٠

(٥) الشافعي، محمد ابن إدريس، **المسند** ، دار الكتب العلمية- بيروت، ١٤٠٠م، كتاب القطع في السرقة، ج:١، ص:٣٣٤.

(٦) بهاء الدين، عبد الرحمن، **العدة شرح العمدة**، دار الحديث- القاهرة، ١٤٢٤ه-٢٠٠٣م، ج١، ص٦٠٤.

(٧) البخاري، **صحيح البخاري مع الفتح**، حديث رقم: ٦٧٨٩، ج٨، ص١٦٠.

(٨) ابن أبي شيبه، عبد الله بن محمد، مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق محمد عوامة، طبعة دار السلفية وطبعة دار القبلة، ج٩، ص٤٧٦.

ثالثا: أن لا يكون للسارق فيه ملك:

أن لا يكون للسارق فيه ملك ولا تأويل الملك أو شبهته، لأن المملوك أو ما فيه تأويل الملك أو شبهته لا يحتاج فيه إلى مسارقة الأعين، فلا يتحقق ركن السرقة، وهو الأخذ على سبيل الخفية والاستسرار على الإطلاق[1].

رابعا: أن يكون معصوماً ليس للسارق فيه حق الأخذ:

لأن ما ليس بمعصوم لا يؤخذ مجاهرة، ولا قطع في سائر المباحات التي لا يملكها أحد، ولا في المباح المملوك وهو مال الحربي في دار الحرب[2].

خامسا: أن يكون مالا محرزاً:

قال أبو حنيفة: أن معنى الحرز لا تعلق له بالملك إذ هو اسم للمكان معد للإحراز يمنع من الدخول فيه إلا بالإذن[3].

ثالثا: الشروط التي ترجع إلى المسروق منه:

وأما شرط الذي يرجع إلى المسروق منه فهو أن يكون له يد صحيحة، وهي يد الملك، أو يد الأمانة أو يد الضمان.

رابعا: الشروط التي ترجع إلى المسروق فيه:

---

(١) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج٧، ص٧٠.

(٢) المصدر نفسه، ج٧ ص٧١.

(٣) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج:٧،ص:٦٧

والشرط الذي يرجع إلى المسروق فيه، وهو المكان: فهو أن تكون السرقة في دار العدل، فلا يقطع في دار الحرب ودار البغي لأنه لا يد للإمام في دار الحرب ولا على دار البغي، فالسرقة الموجودة فيهما لا تنعقد سببا لوجوب القطع[1].

ما تثبت به السرقة:

تثبت السرقة بأحد أمرين هما: البينة والإقرار[2].

أولا: البينة:

وهي شهادة الشهود، وتثبت السرقة بشهادة شاهدين فإن قل العدد عن اثنين أو كان أحدهما امرأة، أو كان أحدهما شاهد رؤية والآخر شاهد سماع، فلا قطع بشهادتهما، ولكن إن أصبح العدد الرجل وامرأتين ،وشهادة شاهد رؤية وشاهدي سماع، فإن لم يكن غير هذه الشهادات في السرقة يمنع القطع وإذا شهد شهود في السرقة فلا تقبل شهادتهم مجملة، ولا بد أن يسأل الحاكم الشاهدين عن السرقة ما هي؟ ومن أين أخرجها؟ وإلى أين أخرجها؟ فإن غابا قبل أن يسألهما الحاكم لم يقطع السارق لاحتمال أن يكون ذلك دون النصاب أو من غير حرز فإن قالا إنها مما يجب فيه القطع وغابا قبل أن يسألهما لم يقطع إلا أن يكون من أهل العلم ومذهبهما مذهب الحاكم[3].

ثانيا: الإقرار:

---

(١) مصدر نفسه، ج٧،ص: ٨٠.

(٢) الكاساني، مصدر سابق،ج٧، ص٨١

(٣) ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج١ ص:٣٠٦.

تثبت السرقة بالإقرار ولو بعد حين من السرقة، لأن التقادم لا يؤثر على الإقرار، وإذا أقر السارق مرة واحدة قطعت يده في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يقطع ما لم يقر مرتين[١].

وعند المالكية تثبت بإقرار الحر و لم يشترطوا التكرار[٢].

وعند الشافعية لايقام على السارق حد إلا بأن يثبت على إقراره حتى يقام عليه الحد[٣].

أما عند الحنابلة: فقد شترطوا في الإقرار مرتين[٤].

فمن هذه النقول يتبين أن الحنفية غير أبي يوسف وكذلك الحنابلة يشترطون التكرار في الإقرار ، أما المالكية والشافعية فقد ذهبوا إلى أن الإقرار يكفي في إثباته مرة واحدة ولا يحتاج إلى تكرار.

عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية:

عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية القطع، لقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾[٥].

---

(١) السرخسي، المبسوط، ج٩، ص١٨٢.

(٢) ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج٤، ص٢٣٧.

(٣) المزني، مختصر المزني، ج٨، ص٣٧١.

(٤) الخرقي، مختصر الخرقي،ج١، ص١٣٥.

(٥) سورة المائدة،الآية:٣٨.

الفرع الثاني: سرد المواد المتعلقة بالسرقة في نظام العقوبات الجنائية الصومالي:

المادة (٤٨٠):

١- كل من استولى على المنقولات المملوكة للغير بحرمانه من حيازتها قاصدا الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائه شلن ولا تتجاوز خمسة آلاف شلنا صومالى.

٢- عند تطبيق قانون العقوبات يعتبر من المنقولات القوة الكهربائية وغيرها من القوى ذات القيمة الاقتصادية.

المادة (٤٨١) الظروف المشددة:

١- تكون العقوبة بالسجن من سنة إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف شلن ولا تتجاوز عشر آلاف شلن[١]. صومالى:

أ- إذا دخل الجانى مبنى أو مكانا معدا للسكن بقصد إرتكاب الجريمة .

ب- إذا استعمل الجانى العنف ضد الأشياء أو لجأ إلى أية وسيلة من وسائل الاحتيال.

ج- إذاكان الجانى يحمل سلاحا أو موادا مخدرة حتى ولو لم يستخدمها .

د- إذا ارتكب السرقة (بخفة اليد) أو بخطف منقولات من يد آخر أومن جسمه.

ه- إذا حدثت السرقة بواسطة ثلاثة أشخاص أو أكثر أو حتى بواسطة شخص واحد تخفّى أو ادّعى أنه موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة.

---

(١) عملة صومالية كانت تعادل دولارين عند وضع القانون سنة ١٩٧٠.

و- إذا حصلت السرقة في أمتعة المسافرين الموجودة في أي نوع من أنواع عربات النقل على أرصفة المحطات أو الموانى أو الفنادق أو فى أماكن أخرى يقدم فيها الطعام أو الشراب.

ز- إذا وقعت السرقة على منقولات في المكاتب العامة أو المؤسسات أو على المنقولات موضوعة تحت الحراسة أو الحجز التحفظي أو معروضة بحكم الضرورة أو العادة أو تكون ملكا عاما للدولة أو مخصصة للخدمة أو المنفعة العامة ،أو للدفاع أو العبادة.

ح- إذا وقعت السرقة على ثلاثة رؤوس أو أكثر فى قطيع متجمع من الأغنام أو الأبقار أو الخيل ولو لم تكن متجمعة في شكل قطيع.

ط- في حالة قيام ظرفين أو أكثر من الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة أو فى حالة وجود ظرف منها مع آخر في الظروف المشار إليها في المادة ٣٩ تكون عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفين من الشلنات ولا تزيد على الخمسة عشر الفا من الشلنات الصومالية.

المادة ٤٨٢ **السرقة التى يعاقب عليها بناء على شكوى المجنى عليه:**

١- فى الحالة المشار إليها في المادة ٤٨٠[1].توقع عقوبة السجن مدة أقصاها سنة أو بغرامة أقصاها ألفان من الشلنات الصومالية وتكون العقوبة على الجريمة بناء على شكوى المجني عليه:

أ- إذا ارتكب الجاني الفعل بقصد واحد هو الإفادة المؤقته من المنقولات التى استولى عليها ثم أعادها مباشرة بعد استعمالها.

ب- إذا ارتكب السرقة في المنقولات تافهة القيمة بقصد مواجهة حالة ضرورة عاجلة وخطيرة.

ج- إذا تضمن الفعل قطعا أو تكديسا أو جمعا من حقول شخص آخر لم تنقل المحاصيل منها بعد.

٢- لا تطبق هذه الأحكام إذا وجد توافق فى أحد الطروف المبنية من البند إ، ب، ج،د من الفقرة ١ من المادة السابقة

(١) كل من استولى على المنقولات مملوكة للغير بحرمانه من حيازتها قاصدا الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائه شلن ولا تتجاوز خمسة آلاف شلنا صومالى.

المبحث الأول: مقدمات السرقة:

المطلب الاول: المادة ٤٨١:

لقد احتوت هذه المادة على بنود بعضها متعلقة بمقدمات السرقة، والبعض الآخر متعلق بالسرقة نفسها، وعليه تورد الباحثة البنود المتعلقة فقط بمقدمات السرقة ههنا، وتنقل ما عدا ذلك إلى المبحث الثاني والمخصص لدراسة المواد المتعلقة بالسرقة نفسها، مع الحفاظ على الطريقة المتبعة في تقسيم كل مطلب إلى نقاط ثلاث، وهي:

أولا: نص المادة

١- تكون العقوبة بالسجن من سنة إلى ستة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف شلن ولا تتجاوز عشر آلاف شلن صومالي:

أ- إذا دخل الجاني مبنى أو مكاناً معداً للسكن بقصد ارتكاب الجريمة.

ب- إذا استعمل الجاني العنف ضد الأشياء أو لجأ إلى أية وسيلة من وسائل الاحتيال.

ج- إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو مواداً مخدرة حتى ولو لم يستخدمها.

ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة:

أما القضية الأولى وهي ارتكاب مقدمات السرقة، فإن البنود (أ و ب و ج) تنص على هذا الأمر، كالدخول إلى مبنى سكني لقصد السرقة، أو استخدام العنف والاحتيال أو حمل سلاح أو المواد التي تخدر، ويظهر هذا الأمر جليا إذا أمعنا النظر في المواد، حيث إن البند (أ) ينص على الدخول بقصد ارتكاب الجريمة، ومعنى ذلك أن الداخل لم يرتكب الجريمة عمليا وإنما نوى فعلها بدخوله، كما أن البند (ب) يشير إلى استخدام العنف أو اللجوء إلى أية وسيلة أخرى للاحتيال ولكن لم تتم عملية السرقة أو الجريمة، والبند (ج) واضح أيضاً في الإشارة إلى هذه النقطة وهي جملة (ولو لم يستخدمها)، فكأن هذه المادة تعامل مقدمة الجريمة أو وسيلتها معاملة الغاية منها،

فتعاقب على مجرد الوسيلة وإن لم تتحقق الغاية، وعليه فتُكيّف الأنواع الواردة في هذه البنود الثلاثة على أنها تصرفات أو مقدمات ووسائل إلى الجريمة التي هي السرقة.

وبعد هذا التحليل نعرض هذه المادة ببنودها على الشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة.

ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة:

لقد سبق الكلام عند تحليل وتكييف الجرائم الواردة في المادة، وتقسيم تلك الجرائم إلى وسائل (مقدمات) ومقاصد (الجريمة نفسها)، ونتكلم هنا عن المقدمات ويرجع في المقاصد إلى المبحث الثاني:

فإن المادة لم تفرق عند إقرار العقوبة بين من ارتكب مقدمة الجريمة (السرقة) وبين من ارتكب السرقة نفسها بل جمعت الكل على عقوبة واحدة، وفي ذلك مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية، فإن الشريعة لم تعامل مرتكب المقدمات عند تنفيذ الأحكام كمرتكب الجريمة نفسها، بل فرقت بينها، وإن كانت تنظر إلى فعلهما من حيث الحكم بنظرة واحدة وهي نظرة الحرمة، بحيث يحرم ارتكاب مقدمات الجريمة لا لذاتها ولكن لئلا يؤدي إلى ارتكاب الجريمة نفسها، ومن هنا فإن الباحثة رأت أن تتناول القضيتين بشيء من التفصيل، كما يأتي:

فالبنود الثلاثة الأولى (أ، ب، ج) كُيّفت على أنها مقدمات للجريمة (السرقة) ولكن لم تحصل الجريمة نفسها في الواقع، ومن هنا تعتبر العقوبة الواردة في المادة من باب التعزير، وقد سبق غير مرة أن التعزير باب واسع وتحديده إلى الإمام أو القاضي، وقد حدد القانون العقوبة البدنية والمالية بالحد الأدنى والأعلى حسب الظروف والملابسات، ومادام أن مرتكب المقدمات تستحق التعزير؛ فليست هناك أية مخالفة للشريعة الإسلامية، وهذا القدر كاف في صلاحية تلك العقوبة، فإذا أضفنا إلى ذلك أن الشريعة دائما تسعى إلى سد باب الجريمة وذلك بسد الطرق والوسائل المؤدية إليها بوضع العقوبات التعزيرية، بل إن الشريعة أحيانا تعامل الوسائل بنفس معاملة المقاصد،

ولذلك جاء في القاعدة الفقهية المقاصدية: أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإذا نظرنا إلى القاعدة نجد أنها تنص على الأحكام وهذا يحتمل أمرين:

الأمر الأول: الوسيلة تأخذ حكم الغاية من حيث الحرمة؟

وهذا طبعا محل اتفاق بين العلماء، فليس هناك خلاف في أن وسيلة السرقة مثلاً محرمة مثل السرقة وهكذا سائر الجرائم.

الأمر الثاني: الوسيلة تأخذ حكم الغاية من حيث العقوبة.

وهنا ينبغي الإشارة إلى أن الحدود لا تقام إلا بارتكاب الجريمة التي وضع الحد لها، لذلك فإن من شرع في عملية السرقة و لم يتمكن من السرقة لا يقام عليه الحد الذي هو قطع اليد، وإنما يعزر وقد يصل التعزير إلى ما فوق قطع اليد ولكنه لا يكون حداً.

وكل ذلك يؤكد أن هذه المادة موافقة لروح الشريعة من حيث الجملة.

ويلاحظ أن المادة جاءت بصيغة عامة لكل جريمة و لم تخصص السرقة وحدها، ولكنها وردت ضمن موضوع السرقة لذلك اعتبرناها من قبيل العام المخصوص. والله تعالى أعلم.

وعليه فليس هناك حاجة إلى اقتراح صيغة أخرى ما دامت الصيغة الموجودة لم تخالف مقاصد الشريعة.

المبحث الثاني: المواد المتعلقة بالسرقة نفسها

المطلب الأول:المادة ٤٨٠

أولا: نص المادة:

١- كل من استولى على المنقولات مملوكة للغير بحرمانه من حيازتها قاصدا الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائه شلن ولا تتجاوز خمسة آلاف شلنا صومالى.

٢- عند تطبيق قانون العقوبات يعتبر من المنقولات القوة الكهربائية وغيرها من القوى ذات القيمة الاقتصادية.

ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة.

هذه المادة وإن كانت مندرجة تحت موضوع السرقة إلا أن محتواها لا يعبر عن السرقة المعروفة في الشريعة الإسلامية وهي أخذ مال الغير خفية بلا شبهة، وهذا يظهر جلياً في نص المادة حيث عبرت بلفظ: استولى و لم تقل سرق، وهذا يدخل في باب الغصب وليس في باب السرقة في الفقه الإسلامي، ولكن لما كان هناك شبه بين الغصب والسرقة من ناحية أخذ مال الغير بلا شبهة، وإنما يفترقان في كيفية هذا الأخذ، فالغاصب يأخذه بقوة وعلى سبيل العلانية، بخلاف السارق الذي يأخذ خفية، لذا سوف نتناول هذه المادة بشيء من التفصيل والتحليل ومن ثم عرضها على الشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة فنقول:

نصت المادة على أن كل من استولى على المنقولات المملوكة للغير سواء أكان من جنس النقود أو الحيوان أو المواصلات أو غير ذلك فيحرم صاحبه من حيازتها، ويكون قصده من هذا الاستيلاء الحصول على كسب غير مشروع سواء كان هذا الكسب لخاصة نفسه أو لصالح غيره أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة شلن ولا تتجاوز خمسة آلاف شلن صومالي.

وبما أنه قد سبق أن ذكرنا أن هذا الاستيلاء من قبيل الغصب وليس من قبيل السرقة فلنعرض الحكم الوارد في القانون على الشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة.

ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة:

لقد تقدم أن هذا النوع يكيف في الفقه الإسلامي على أنه غصب وليس سرقة وعليه فيجدر بنا بيان معنى الغصب لغة واصطلاحا أولا ثم ذكر الحكم الشرعي فيه.

أولا: معنى الغصب في اللغة عبارَةٌ عن أَخْذِ الشَّيْءِ على وَجْهِ الْغَلَبَةِ وَالْقَهْرِ سَوَاءٌ كان مُتَقَوِّمًا أو غَيْرَهُ يُقَالُ غُصِبَتْ زَوْجَةُ فُلَانٍ وَوَلَدُهُ وَيُطْلَقُ على حَمْلِ الْإِنْسَانِ على فِعْلِ ما لَا يرضاه يُقَالُ غَصَبَنِي فُلَانٌ كَذَا[1].

ثانيا: معنى الغصب في الاصطلاح:

للغصب تعريفات عدة منها:

الْغَصْبُ شَرْعًا: أَخْذُ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ مُحْتَرَمٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ على وَجْهٍ يُزِيلُ يَدَ الْمَالِكِ إنْ كان في يَدِهِ أو تَقْصِيرَ يَدِهِ إنْ لم يَكُنْ في يَدِهِ على سَبِيلِ الْمُجَاهَرَةِ[2].

هو أخذ رقبة الملك أو منفعته بغير إذن المالك على وجه الغلبة والقهر دون حرابة[3].

هُوَ مَنْعُ الْإِنْسَانِ مِنْ مِلْكِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ[4].

---

(١) ابن منظور الإفريقي، **لسان العرب** ج١ ص٦٤٨، الفيومي، **المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي**، المكتبة العلمية بيروت ج٢ ص٤٤٨، الرازي، **مختار الصحاح**، مكتبة لبنان بيروت ط/ج، ١٩٩٥، ص٤٨٨.

(٢) ابن نجيم الحنفي، **البحر الرائقشرح كتر الدقائق**،دار المعرفة بيروت، ج٨ ص ١٢٨ ، الكاساني، **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع** دار الكتاب العربي بيروت عام ١٩٨٢ ج٧ ص ١٤٢.

(٣) ابن جزي الغرناطي، **القوانين الفقهية** ص ٢١٦.

(٤) الماوردي، **الحاوي في فقه الشافعي**، دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٥ ج٧ ص ١٣٥، النووي، **المجموع شرح المهذب**

هو الإستيلاء على مال غيره بغير حق[1].

وهذه التعريفات متقاربة وتتفق على أن الغصب هو أخذ المال أو منع صاحبه من الانتفاع منه بغير حق، ولكن أقرب التعريفات إلى نص القانون هو التعريف الأخير للحنابلة حيث عبر بلفظ الاستيلاء.

وبما أن التصرف الوارد في المادة غصب فإن العقوبة المحددة والتي هي السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ولا تتجاوز خمسة آلاف شلن الصومالي يمكن تخريجها على أنها عقوبة تعزيرية لهذا الغاصب، ومن هنا لا توجد أي مخالفة في القانون للشريعة لأن باب التعزير واسع كما سبق غير مرة.

ولكن المادة أغفلت وجوب إعادة العين المغصوبة أو المستولى عليها إلى صاحبها في حال وجودها، أو تضمين الغاصب في حال تلفها وعدم وجودها، وكان من المفروض أن يكون هذا من أولى أولويات القانون لئلا يؤدي إلى حرمان المالك من ملكه، ولا يمكن أن يعتبر الغرامة المالية المحددة في القانون عوضا عن المال المغصوب لاحتمال النقص أو الزيادة وكلاهما غير مقبول، فمن هذا المنطلق يمكن القول بأن القانون قصر في بيان كل ما يتعلق بهذا الاستيلاء كما هو وارد في الفقه الإسلامي، حيث أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله و لم يتغير أو يتلف، ويرد بزيادته إن زادت، سواء كانت هذه الزيادة متصلة به أم منفصلة عنه، وذلك لأنها نماء المغصوب. والله تعالى أعلم.

وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كتميم لصيغة هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي: **كل من استولى على المنقولات مملوكة للغير بحرمانه من حيازتها قاصدا الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب تعزيرا بالسجن مدة لا**

....

(١) ابن قدامة، **المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني**، دار الكتب العلمية بيروت، ط/١ سنة ١٤٠٥ ج٥ ص ٣٧٤.

تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائه شلن ولا تتجاوز خمسة آلاف شلنا صوماليا مع رد الشيء المستولى عليه بعينه أو قيمته.

المطلب الثاني: المادة ٤٨١ الظروف المشددة:

أولا: نص المادة:

١- تكون العقوبة بالسجن من سنة إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف شلن ولا تتجاوز عشرة آلاف شلن صومالى:

د- إذا ارتكب السرقة (بخفة اليد) أو بخطف منقولات من يد آخر أومن جسمه.

ه- إذا حدثت السرقة بواسطة ثلاثة أشحاص أو أكثر أو حتى بواسطة شخص واحد تخفى أو ادعى أنه موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة.

و- إذا حصلت السرقة في أمتعة المسافرين الموجودة في أي نوع من أنواع عربات النقل على أرصفة المحطات أو الموانى أو الفنادق أو فى أماكن أخرى يقدم فيها الطعام أو الشراب.

ز- إذا وقعت السرقة على المنقولات في المكاتب العامة أو المؤسسات أو على المنقولات الموضوعة تحت الحراسة أو الحجز التحفظي أو معروضة بحكم الضرورة أو العادة أو تكون ملكا عاما للدولة أو مخصصة للخدمة أو المنفعة العامة، أو للدفاع أو للعبادة.

ح- إذا وقعت السرقة على ثلاثة رؤوس أو أكثر في قطيع متجمع من الأغنام أو الأبقار أو الخيل ولو لم تكن متجمعة في شكل قطيع.

ط- فى حالة قيام طرفين أو أكثر من الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة أو في حالة وجود طرف منها مع آخر في الظروف المشار إليها في المادة ٣٩[1]. تكون العقوبةُ السجنَ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفين من الشلنات ولا تزيد على الخمسة عشر ألف من الشلنات الصومالية.

ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة:

---

(١) ظروف الجريمة:

الظروف العادية المشددة:

تعد الظروف الآتية مشددة الجريمه رغم إنها ليست من أركانها أو من الظروف الخاصة المشددة:

(أ) ارتكاب الجريمة بدوافع دنيئة أوتافهة.

(ب) إذا ارتكبت الجريمة لتسهيل ارتكاب أو إخفاء جريمة أخرى أو بقصد ضمان إفلات مرتكب الجريمة أو غيره من العقوبة المقررة الجريمه أخرى.

(ح) في حالة ارتكاب جريمة من جرائم خطئية رغم العلم بنتائجها.

(د) استعمال وسائل غير إنسانية أو أعمال عنف تجاه الغير.

(ه) استغلال الظروف المتصلة بالمكان أو بالزمان أو بالأشخاص بقصد إعاقة الدفاع العام والخاص.

(و) إذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة في وقت كان يحاول فيه عمدا الإفلات من تنفيد أمر صادر بالقبض عليه أو من حكم صادر بسجنه من جريمة سابقة.

(ز) في حالة الجرائم التي تقع على الممتلكات إذا تسببت في إحداث أضرار جسيمة لممتلكات المجني عليه.

(ط) تشديد أو محاولة تشديد أثار الجريمة المرتكبة.

(ظ) في حالة ارتكاب الفعل بسوء استعمال السلطة أو بانتهاك مقتضيات الواجبات التي هي من مستلزمات الوظيفة العامة أو الخدمة العامة.

(ك) ارتكاب الجريمة ضد موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة أو ضد عضو في السلك الدبلوماسي أو القنصلي لدولة أجنبية أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.

(ي) ارتكاب فعل عن طريق استغلال السلطة أو النفود أو الأوامر العائلية أو فيما له علاقة مباشرة للعمل سواء عن طريق السكن معا أو تقديم العطايا أو قبولها.

جمعت هذه المادة من خلال بنودها التسعة قضيتين اثنتين:

القضية الأولى: ارتكاب مقدمات السرقة.

القضية الثانية: ارتكاب السرقة نفسها.

وقد سبق تناول القضية الأولى (الجزء المتعلق بمقدمات السرقة) في المبحث الأول.

وأما القضية الثانية وهي ارتكاب الجريمة نفسها (السرقة) فهذا بيّن سواء كان من فرد واحد أم من متعدد، وسوف نتناول كل نقطة بالتحليل لمعرفة التكييف الحقيقي للجريمة الواردة فيها ومن ثم عرضها على الشريعة للموافقة والمخالفة.

فالبند (د) نص على ارتكاب السرقة بخفة اليد أو خطف المنقولات من يد إنسان أو من جسمه، وهذه الجريمة في الحقيقة لا تسمى سرقة في اصطلاح الفقهاء كما تقدم معنا في تعريف السرقة، وإنما يسمى الأول (وهو السرقة بخفة اليد) اختلاسا، والاختلاس هو أخذ الشيء بحضرة صاحبه على حين غفلة منه وقد يرافقه الفرار بالسرعة غالبا[1]، كما يسمى الثاني: (وهو خطف منقولات من يد آخر أو من جمسه) نهبا، والنهب هو أخذ الشيء من يد صاحبه أو من جسمه جهارا سواء أكان على مرأى من الناس أم لا[2].

والبند (ه) نص على حصول السرقة من قبل مجموعة أشخاص أو من شخص واحد ادعى أنه موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة وهذا أيضا في الحقيقة يسمى خديعة وليست سرقة، والخديعة والخدعه بالضم ما يخدع به الإنسان[3]، أي بإظهار خلاف الحقيقة ليتمكن من تحقيق غرضه وهو اقتناء ملك الغير ووضع يده عليه.

---

(١) السرخسي، المبسوط، ج٩،ص١٦٠.

(٢) الجرجاني، تعريفات، ج١ص١٦٢.

(٣) المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ج١،ص١٥٢.

والبند (و) نص على حصول السرقة في أماكن التجمعات مثل أخذ الأمتعة من فوق عربات النقل في المحطات أو الموانئ أو حتى المطاعم، فهذا في الحقيقة إن اعتبرنا هذه الأمكان حرزا وهو الأقرب كانت الجريمة سرقة حسب تعريف الفقهاء وكان صاحبها سارقا، أما إذا اعتبرنا المكان مكانا عاما لا يصلح حرزا فتكون العملية إما نهبا أو اختلاسا أو غير ذلك، والله تعالى أعلم.

والبند (ز) نص على وقوع الجريمة (السرقة) على المنقولات في الأماكن العامة كالمكاتب العامة، أو المؤسسات، أو وقوع الجريمة (السرقة) على الأشياء الموضوعة تحت الحراسة أو الحجز التحفظي، أو وقوع الجريمة (السرقة) على المنقولات المعروضة بحكم الضرورة أو العادة، أو منقولات مملوكة ملكا عاما للدولة أو تم تخصيصها للخدمة أو المنفعة العامة أو للدفاع أو للعبادة، وعليه فيمكن تناول هذا البند في عدد من النقاط كالآتي:

الأولى: أن تكون الجريمة على المنقولات في الأماكن العامة أو المؤسسات فهذا إما أن يصدر عن الموظف الموجود في تلك المكاتب أو المؤسسات وإما أن تصدر عن شخص أجنبي عن المكاتب أو المؤسسة، فإن صدرت الجريمة من الموظف سميت هذه الجريمة خيانة، وهي أخذ ما لآخذه فيه أمانة أو يد على وجه غير مشروع[1]. وأما إن صدر من إنسان آخر غير موظف فلا شك أنه سيختفي ويأخذ هذه المنقولات وحينئذ يعتبر سارقا ويعتبر العمل الذي قام به سرقة.

الثانية: أن تكون الجريمة (السرقة) على المنقولات الموضوعة تحت الحراسة أو الحجز التحفظي، فهذا واضح أن العملية تكون سرقة، وذلك لأن الحراسة أو الحجز التحفظي يعتبر حرزاً لها، فأخذها منه يكون أخذاً للشيء من حرزه.

الثالثة: أن تكون الجريمة (السرقة) على المنقولات المعروضة بحكم الضرورة أو العادة كالأشياء المخصصة للخدمة العامة أو المنعفة العامة أو المخصصة للعبادة أو غيرها، فهنا يحتمل أن تكون الجريمة سرقة ويحتمل أن تكون خيانة، فإن اعتبر المكان الذي هي فيه حرزا لها بحكم

---

(١) الفيومي،أحمد بن محمد، **مصباح المنير في غريب شرح الكبير**، مكتبة العلمية –بيروت، ج١، ص:١٨٤.

الضرورة كانت العملية سرقة، وإلا كانت خيانة، وفي رأي الباحثة أن اعتبار مثل هذه الأماكن حرزا أولى من باب سد الذريعة والله تعالى أعلم.

والبند (ح) نص على كون المسروق حيوانا من بقر أو غنم أو خيل، وكان عددا من ثلاثة فما فوق سواء كانت مجتمعة في شكل قطيع أم لم تكن كذلك، وهذا البند يمكن تناوله من جانبين:

الجانب الأول: وقوع الجريمة (السرقة) على الحيوان وهذا إما أن يكون في حظيرة أو مكان يمكن اعتباره حرزا له أو لا، فإن كان الأول كانت الجريمة سرقة، وإلا فلا.

الجانب الثاني: أن يكون الحيوان المسروق عددا من ثلاثة أو أكثر مجتمعة في مكان واحد أو متفرقة، وهذا لا علاقة له بتكييف العملية، وإنما يعتبر ذلك عند اعتبار النصاب لإقامة الحد، وكذلك عند تضمين السارق في حال فقدان أو تلف العين، وعليه فإن ذكر العدد يعتبر وصفا طرديا في باب التكييف الفقهي. والله تعالى أعلم.

والبند الأخير من المادة وهو البند (ط) نص –فيما يظهر– على وجود الجمع بين ظرفين أو حالتين من الظروف والحالات الواردة في المادة، أو وجود دمج بين ظرف أو حالة واردة في هذه المادة وبين ظرف أو حالة أخرى واردة في المادة ٣٩ فكأنها تشير إلى ارتكاب شخص واحد لظرفين سواء كانا من المادة ٤٨١ أو كان أحدهما منها والآخر من المادة ٣٩ وهذا بحاجة إلى تفصيل أكثر وإبداء احتمالات كثيرة وذلك لاختلاف الظروف في حقائقها وكذلك في أحكامها وهذا ليس محل بسطه لأن هذه الظروف لا تتعلق بأخذ مال الغير وإنما تتعلق بحالات أخرى كما هو بين في بنود المادة المشار إليه (٣٩) والله تعالى أعلم.

وبعد هذا التحليل نعرض هذه المادة ببنودها على الشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة.

ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية:

لقد سبق الكلام عند تحليل وتكييف الجرائم الواردة في المادة، وتقسيم تلك الجرائم إلى وسائل (مقدمات) ومقاصد (الجريمة نفسها).

أما البند (د) فقد احتوى على جريمتين هما النهب والاختلاس، والعقوبةالتي وردت في القانونيمكن اعتبارها من باب التعزير وذلك باب واسع يترك تحديده للقاضي، وبذلك لا يكون في البند مخالفة للشريعة، ولكنه أغفل تضمين الجاني عين المال إذا كان موجوداً أو قيمته، وبذلك يعتبر القانون قاصراعن الشريعة الإسلامية لأن عقوبة الغرامة الواردة في القانون لاتكون تعويضاً للمال المجني عليه لاحتمال النقص أو الزيادة.

أما البند (ه) فإن الجريمة التي وردت فيها تعتبر من قبيل الخديعة، وليس فيها حد شرعي، وإنما تكون العقوبة من باب التعزير، وعليه فيمكن اعتبار العقوبة الواردة في المادة من هذا الباب وبالتالي لا يكونهناك أية مخالفة للشريعة اللهم إلا من ناحية عدم التنصيص على تضمين المخادع في حال فقد أو تلف العين المأخوذة. الله تعالى أعلم

أما البند (و) فإما أن يعتبر المكان حرزا للشيء المسروق فتكون العملية سرقة موجبة للحد وهو قطع اليد إن بلغ المسروق نصابا، وبذلك تتبين مخالفة المادة للشريعة الإسلامية في هذا الجانب، وذلك بفرضه عقوبة الحبس والغرامة المالية فقط دون الحد الشرعي.

وأما ألا يعتبر المكان حرزا فتكون العملية إما نهبا وإما خديعة أو غير ذلك وكله لا يوجب حدا وإنما يستحق مرتكبيه التعزير، فلا يكون هناك مخالفة في المادة للشريعة من هذه الحيثية إلا ما تقدم ذكره من عدم الإشارة إلى التضمين. والله تعالى أعلم.

أما البند (ز) ففيه ثلاث نقاط:

النقطة الأولى: الجريمة التي ورد فيها لها جانبان، الأول: أن تصدر الجريمة من الموظف. الثاني: أن تصدر الجريمة من شخص أجنبي، فإن صدرت الجريمة من الموظف فإن الجريمة تسمى خيانة وليس لها عقوبة محددة في الشريعة بل يترك تحديدها للقاضي، وعليه فيمكن القول بأن القانون لم يخالف الشريعة الإسلامية ههنا من حيث العموم.

أما إذا كان الشخص الذي صدر الفعل منه أجنبيا فإن الجريمة تكون سرقة، وعقوبتها في الشريعة هي القطع إذا توفرت فيه شروط إقامة الحد، وعليه فإن القانون يعتبر مخالفا لما في الشريعة الإسلامية من هذه الحيثية؛ لأن عقوبة السرقة حدية وليست من العقوبات التعزيرية و لم يرد في نص القانون عقوبة القطع.

النقطة الثانية: الجريمة التي وردت فيها هي السرقة لأن الحراسة أو الحجز التحفظي يعتبر حرزاً للأشياء التي فيها، وبالتالي يكون أخذها سرقة، وعقوبة السرقة القطع كما سبق تقريره.

أماالنقطة الثالثة: فإن الجريمة التي وردت فيها لها احتمالان:

الأول: أن تكون سرقة.

الثاني: أن تكون خيانة.

وقد تقدم في النقطة الأولى الكلام على مثل هذه الحالات فليراجع ثمت.

أما في البند(ح): إما أن يكون المال المسروق في حرز أو في مكان عام، إذا أصبح المال في حيازة أحد ثم جاء شخص وأخذ المال من تلك الحيازة في هذه الحالة تكون الجريمة سرقة وعقوبتها القطع إذا بلغ المسروق نصاباً.

أما إذا كان المال ليس في حيازة أحد أي في مكان عام، فإذا حصلت الجريمة في هذه الحالة لا تعتبر سرقة، وليس فيها عقوبة مقررة ولا تمنع الشريعة عقوبة التعزير في هذه الحالة.

وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كتتميم أو بديل لصيغة بنود هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي:

١- تكون العقوبة تعزيرا بالسجن من سنة إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف شلن ولا تتجاوز عشر آلاف شلن صومالي، مع ضمان العين المأخوذة:

د- إذا ارتكب السرقة بخفة اليد (الاختلاس)، أو بخطف منقولات من يد آخر أومن جسمه (النهب).

ه- إذا حدثت السرقة (الاحتيال) بواسطة ثلاثة أشحاص أو أكثر أو حتى بواسطة شخص واحد تخفّى أو ادّعى أنه موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة.

و- إذا حصلت السرقة في أمتعة المسافرين الموجودة في أي نوع من أنواع عربات النقل على أرصفة المحطات أو الموانى أو الفنادق أو في أماكن أخرى يقدم فيها الطعام أو الشراب، وهذا فيما إذا لم يبلغ المسروق النصابَ، أما إذا بلغ النصاب فتكون العقوبة القطع.

ز- إذا وقعت السرقة على منقولات في المكاتب العامة أو المؤسسات أو على المنقولات الموضوعة تحت الحراسة أو الحجز التحفظي، أو معروضة بحكم الضرورة أو العادة أو تكون ملكا عاما للدولة أو مخصصة للخدمة أو المنفعة العامة، أو للدفاع أو العبادة وهذا فيما إذا لم يبلغ المسروق النصابَ، أما إذا بلغ النصاب فتكون العقوبة القطع.

ح- إذا وقعت السرقة على ثلاثة رؤوس أو أكثر فى قطيع متجمع من الأغنام أو الأبقار أو الخيل ولو لم تكن متجمعة في شكل قطيع، وهذا فيما إذا لم يبلغ المسروق النصابَ، أما إذا بلغ النصاب فتكون العقوبة القطع.

المطلب الثالث: المادة ٤٨٢ السرقة التى يعاقب عليها بناء على شكوى المجني عليه:

أولا: نص المادة:

١- فى الحالة المشار إليها في المادة ٤٨٠ توقع عقوبة السجن مدة أقصاها سنة أو بغرامة أقصاها ألفان من الشلنات الصومالية وتكون العقوبة على الجريمة بناء على الشكوى المجنى عليه:

أ- إذا ارتكب الجانى الفعل بقصد واحد هو الإفادة المؤقته من المنقولات التى استولى عليها ثم أعادها مباشرة بعد استعمالها.

ب- إذا ارتكب السرقة في المنقولات تافهة القيمة بقصد مواجهة حالة ضرورة عاجلة وخطيرة.

ج- إذا تضمن الفعل قطعا أو تكديساً أو جمعاً من حقول شخص آخر لم تنقل المحاصيل منها بعد.

٢- لا تطبق هذه الأحكام إذا وجد توافق فى أحد الظروف المبينة من البند أ[١]، ب[٢]، ج[٣]، من الفقرة ١ من المادة السابقة[٤].

ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة:

هذه المادة تشير إلى حالة أخرى من حالات السرقة التي يعاقب عليها القانون الصومالي، إلا أن العقوبة لا تأتي تلقائياً وإنما تأتي بناءً على شكوى المجني عليه (المسروق منه)، وهذا هو الأصل في مثل هذه العقوبات أن يتم رفع الدعوى إلى القاضي، وقد احتوت المادة على فقرتين اثنتين هما:

الفقرة الأولى في بيان عقوبة من ارتكب الأفعال المشار إليها في البنود الثلاثة (أ و ب و ج) حيث توقع عليه العقوبة المحددة وهي السجن لمدة أقصاها سنة أو غرامة مالية قد تصل إلى ألفين من الشلنات الصومالية، وتفصيل البنود كالآتي:

---

(١) إذا دخلا لجاني مبنى أومكانامعدا للسكن بقصد ارتكابالجريمة:

(٢) إذا استعملا لجاني العنف ضد الأشياء أولجأ إلى أية وسيلة من وسائل الاحتيال:

(٣) إذاكان الجانى يحمل صلاحا أو مواد مخدرة حتى ولو لم يستخدمها:

(٤) وهي المادة رقم ٤٨١.

البند (أ) فإن الجريمة الواردة فيه عبارة عن الاستيلاء على ممتلكات الغير، إلا أن المستولي لم يقصد تأبيد الاستيلاء لنفسه، وإنما أخذ المنقول لكي يستفيد منه بشكل مؤقت ثم يعيده بعد ذلك، وهذا كما سبق بيانه إنما يسمى غصبا في الفقه الإسلامي وليس سرقة، وقد أشارت المادة إلى أن هذا المستولي أعاد الشيء المنقول إلى صاحبه بعد فترة من الزمن، وسوف يأتي تفصيل حكمه عند المقارنة بالشريعة الإسلامية.

البند (ب) فالجريمة الواردة فيه هي السرقة إلا أن صاحبها قد ارتكبها بناء على ضرورة قائمة أو حاجة خطيرة قد تؤدي إلى الهلاك إلم يرتكبها كمن أخذ طعام غيره أو شرابه ليدفع عن نفسه المخمصة أو الغصة أو غير ذلك، ولذلك عبرت المادة بالأشياء التافهة، وهذا يحتمل أن تكون هذه الأشياء لم تبلغ النصاب الموجب لإقامة حد السرقة على الجاني، ويأتي كذلك تفصيل القول في حكمه عند المقارنة بالشريعة الإسلامية.

وأما البند (ج) فإن الجريمة الواردة فيه عبارة عن قطع أو تكديس أو جمع الأشياء من حقول الغير وذلك قبل نقل المحاصيل الزراعية وهذا كما يظهر ليس بسرقة وإنما هو إذهاب عين الشيء أو منفعته عن صاحبه، فيدخل في باب المتلفات، إذن فالجريمة ههنا هي الإتلاف.

والبند الثاني: أشار إلى الحالة التي تمنع من تطبيق العقوبة الواردة في هذه المادة، إلا أنه لم يتبين للباحثة بعد البحث المقصود من الفقرة.

ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية:

إن الفقرة الأولى من المادة نصت على أن العقوبة تقام بناء على شكوى المجني عليه، وهذا هو الأصل، بحيث لا توقع العقوبة على الجاني إلا إذا رُفع ضده دعوى وثبتت الجريمة في حقه بالإقرار أو بالبينات والبراهين، ومن هنا تكون الفقرة موافقة لإجراءات التحري في العقوبات وتنفيذها في الشريعة الإسلامية، فيكون المجني عليه في سعة من أمره من حيث التنازل والعفو عن الجاني، وأما بعد رفع القضية إلى القاضي فإن تنفيذ العقوبة يصبح واجبا

ولا يقبل تراجع المجني عليه بدليل ما جاء في السنن: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَيَّ خَمِيصَةٌ لِي ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ الرَّجُلُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ، قَالَ :فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا؟ قَالَ: ((فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ)) [1]. فقوله صلى الله عليه وسلم: ((هلا قبل ذلك))، يعني: كان ينبغي أن تعفو وتتنازل قبل أن ترفع إلي القضية، ومفهومه أنه لو لم يشتك لما أُوْقعت العقوبة (الحد) على الجاني. والله تعالى أعلم.

أما البند (أ) فيتعلق بمسألة: من أعاد شيئا مغصوبا بدون تلف أو بتلف، وتفصيلها أن يقال بإن الحكم الأصلي الثابت في الشيء المغصوب وجوب رد العين إلى المالك وعلى هذا من غصب شيئا لزمه رده[2] بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ)[3]، إلا أن للشيء المغصوب ثلاث حالات هي:

الحالة الاولى: أن يكون باقيا على حاله من غير زيادة أو نقصان.

الحالة الثانية: أن يكون تالفا بذهاب عينه.

الحالةالثالثة: أن يكون ناقصا.

فإن كان باقيا بحاله ارتجعه المالك منه[4]، وهذا لاخلاف فيه[5].

---

(١) أبو داود، سنن أبي داود، باب من سرق من حرز، ج٤،ص١٣٨، حديث رقم:٤٣٩٤.

(٢) السرخسي، المبسوط، ج١١، ص٤٩.

(٣) البيهقي، **السنن الكبرى للبيهقي**، باب رد المغصوب إذا كان باقيا، حديث رقم:١١٥١٩، ج٦، ص١٥٨، الأعظمي، محمد، **المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى**، مكتبة الرشد-السعودية- رياض،سنة: ١٤٢٢ه-٢٠٠١م، باب العارية، ج٥،ص٣٧٠، حديث رقم: ٢١٠٢.

(٤) الماوردي: **الحاوي الكبير**، ج٧ ص١٣٦.

(٥) ابن رشد، **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**، ج٤ ص١٠١.

وإن كان تالفا: فهو مضمون على الغاصب سواء تلف بفعله أم بغيره لقوله صلى الله عليه وسلم: ((عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ)).

وإن كان ناقصا فعلى ضربين:

أحدهما: أن يكون مما يتميز بعضه عن بعض كالحنطة بحيث يتلف بعضها دون بعض فيكون ضامنا لما تلف فقط فيرد بالمثل إن وجد وإلا فبالقيمة ويرد الباقي بعينه سواء كان التالف أكثر المغصوب أو أقله[1].

والضرب الثاني: أن يكون مما لا يتميز بعضه عن بعض كثوبٍ شقه أو إناءٍ كسره، فلا يخلو إما أن يكون الناقص أقل منافعه، وإما أن يكون أكثر منافعه.

فإن كان الناقص أقل منافعه أخذه وما ينقص من قيمته إجماعا.

وأما إذا كان الناقص أكثر منافعه فقد اختلف الفقهاء فيه على أقوال:

القول الأول: ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يأخذه وما نقص من قيمته كالحالةالأولى[2].

القول الثاني: وبه قال مالك: يكون المالك مخيرا بين تسليمه إلى الغاصب ويأخذ منه جميع القيمة وبين أن يمسك به ناقصا ولا أرْش له[3].

القاول الثالث: وبه قال أبو حنيفة: يكون المالك مخيرا بين أن يتمسك به ويرجع بأرش نقصه وبين أن يسلمه للغاصب ويرجع بجميع قيمته[1].

---

(١) الماوردي، **الحاوي الكبير**، ج٧ ص١٣٨.

(٢) الشافعي، **الأم**، ج٣ ص٢٥٥.

(٣) ابن رشد الحفيد، **بداية المجتهد ونهايةالمقتصد**، ج٤، ص١٠٢.

وبعد معرفة ما يتعلق برد العين المغصوبة نقول بأن القانون قد حددالعقوبة بالسجن أو بالغرامة المالية على مرتكب هذه الجريمة، فإذا اعتبرت هذه العقوبة من باب ردع المجرم وتقليل الإجرام فليس هناك أي إشكال في عدم مخالفة القانون للشريعة الإسلامية حيث يعتبر ذلك من باب التعزير، لكن يبقى الإشكال في كيفية رد العين المغصوبة إلى صاحبها حيث إن القانون أغفل هذا الجانب ولم يتطرق إليه ولو بالإشارة، ولا يمكن اعتبار الغرامة المالية كتعويض للشيء المغصوب لعدم التنصيص على ذلك في القانون أولا، ولأن الغرامة المالية قد تم تحديد أدناها وأعلاها، والعين المغصوبة قد تكون أقل من الغرامة وقد تكون أكثر منها، ومن هذا الجانب يمكن اعتبار القانون ناقصا في تحديد حق المغصوب منه من حيث رد العين المغصوبة إليه بالتفاصيل التي سبقت آنفا، وعليه يعتبر القانون قاصرا في بيانه عن الشريعة الإسلامية، بل يمكن اعتباره مخالفا للشريعة من وجه آخر وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز، إذ الفرض أن يكون القانون قد أوضح كل شيء بالتفصيل الدقيق بما يزيل أي إشكال أو لبس. والله تعالى أعلم.

أما البند (ب) فيتعلق بمسألة أخذ مال الغير لدفع الضرورة: هذه المسألة مبنية على قاعدة فقهية معروفة وهي: (الضرورات تبيح المحظورات):

قال الله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾ [٢].

أي كاره للإثم، وقد أباح الإسلام للإنسان الذي لا يملك مالا ولم يجد من يقرضه ليشتري طعاما أو دواءوكانت به ضرورة ملحة أن يأخذ مال الغير لدفع تلك الضرورة ولكن على قدر الضرورة[٣]، فلا يباح للمضطر من مال أخيه إلا قدر الضرورة، فيأكل أو يشرب بقدر الحاجة ولا يتزود بشيء منه[٤].

---

(١) ابن نجيم، **البحر الرائق**، ج٨، ص١٢٥.

(٢) سورة المائدة: الآية:٣.

(٣) تفسير الشعراوي، ج١، ص٢٠٢٣.

(٤) ابن قدامه، شرح الكبير، ج١١، ص١٠٥

كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قال أبو هريرة[1] رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا اضطر إليه؟ قال: ((يأكل ولا يحمل، يشرب ولا يحمل))[2].

وقد اتفق العلماء على أن الإنسان إذا أخذ مال الغير لدفع ضرورة الجوع أو العطش أو أي ضرورة قد تؤدي إلى هلاكه أنه لا حد ولا عقوبة عليه، إلا أنه يضمن ما أخذه من مال أخيه[3].

جاء في المغني: "لا قطع في المجاعة يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه لأنه كالمضطر،

وروى الجوزجاني عن عمر أنه قال: (لا قَطع في عام سِنَة)[4]. وقال: سألت أحمد عنه فقلت: تقول به؟ فقال أي لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في الشدة والمجاعة"[5].

وبالنظر إلى هذا البند يوجد أن القانون عاقب من استفاد من ملك الغير(المضطر) لدفع الضرورة بكل من السجن لمدة عام واحد، أوالغرامة المالية، وفي هذا زيادة معاناة هذا المضطر، مع أن الشريعة الإسلامية قد جعل هذا الشخص في مثل هذه الحالة في سعة من أمره

---

(١) هو هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الملقب بأبي هريرة: صحابي، كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له، نشأ يتيما ضعيفا في الجاهلية، وقدم المدينة ورسول صلى الله عليه وسلم بخيبر، فأسلم سنة ٥٧، ولزم صحبة النبي فري عنه٥٣٧٤ حديثا نقلها عن أبي هريرة، وكان أكثر مقامه في المدينة وتوفي فيها. الزركلي، الأعلام، ج٣، ص٣٠٨.

(٢) البيهقي، **السنن الكبرى**، ج٩، ص ٣٦٠.

(٣) النووي، **روضةالطالبين وعمدة المفتين**، ج٣، ص٢٨٣.

(٤) ابن أبي شيبة، **مصنف ابن أبي شيبة**، ج١٠، ص٢٨. ابن الملقن، سراج الدين، **البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في شرح الكبير**، المحقق: مصطفى أبو الغيط، وعبدالله ابن سليمان، دار الهجرة للنشر والتوزيع –الرياض– السعودية، ط الأولى: ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م، ج٨، ص٦٧٩.

(٥) ابن قدامه، **المغني**، ج١٠، ص٢٨١.

أن يتصرف في ملك الغير بما ينقذ حياته ويدفع عنه الضرورة من غير اعتداء، ولاحترام الشريعة للحقوق والملكية الفردية؛ فقد حملت هذا المستفيد ضمان ما استفاد به من ملك غيره ليعيش الناس في طمأنينة، وبذلك يمكن اعتبار العقوبة الواردة في القانون من هذا الجانب مخالفة للشريعة، حيث لم يراع و لم يعتبر الظرف الذي جعل هذا الشخص يتصرف، وهذا من محاسن الشريعة السمحة التي جاءت لتحقيق الراحةللبشرية قاطبة، وحماية النفوس من الضياع، والعدل بين الناس بما يضمن الحقوق لأصحابها. والله تعالى أعلم.

والبند (ج) أشبه بالتصرف في ملك الغير بما يذهب عينه أو منفعته، فيكون من باب الإتلاف، وعليه فالتكييف الفقهي للجريمة الواردة في البند هو الإتلاف كما سبق، ومعلوم أن من أتلف مال غيره فإنه يضمنه، جاء في الدر المختار: "فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك: أجزت أو رضيت أو أمضيت لم يبرأ من الضمان"[1]. يعني أن الضمان يكون موجودا في كل الأحوال حتى يصرح المالك بإسقاطه، فمثلا من أكل أو استهلك طعام غيره وجب عليه الضمان لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه، فإن كان متعديا لغيرضرورة أثم مع الضمان، وإن كان للضرورة فلا إثم عليه ما لم يتجاوز قدر الضرورة، كما جاء في البهجة في شرح التحفة: "من هدم جدار غيره دون ضرورة لزمه أن يبنيه كما كان لأنه أتلف مال غيره بغير موجب"[2].

وقد حدد القانون العقوبة بالسجنأو بالغرامة المالية على مرتكب هذه الجريمة، فإذا اعتبرت العقوبة من باب ردع المجرم وتقليل الإجرام فليس هناك أي إشكال في عدم مخالفة القانون للشريعة الإسلامية حيث يعتبر ذلك من باب التعزير وبابه واسع، ويبقى الإشكال في كيفية ضمان الشيء المتلف، حيث إن القانون قد أغفل هذا الجانب و لم يتطرق إليه ولو بالإشارة، ولا يمكن اعتبار الغرامة المالية كتعويض للشيء المتلف لعدم التنصيص على ذلك في

---

(١) ابن عابدين، **الدر المختار**، ج١، ص٣١٥.

(٢) التسولي، أبو الحسن، **البهجة في شرح التحفة**، تحقيق:محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية-لبنان- بيروت، ١٤١٨ه-١٩٩٨م، ط:الأولى، ج٢ ص٢٥٦.

القانون أولا، ولأن الغرامة قد تم تحديد أدناها وأعلاها، والعين المتلفة قد تكون أقل من الغرامة وقد تكون أكثر منها، ومن هذا الجانب يمكن اعتبار القانون ناقصا في تحديد حق المتلف منه من حيث رد العين المتلفة إليه، وعليه يعتبر القانون قاصرا في بيانه عن الشريعة الإسلامية، بل يمكن اعتباره مخالفا للشريعة من وجه آخر وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز، إذ الفرض أن يكون القانون قد أوضح كل شيء بالتفصيل الدقيق بما يزيل أي إشكال أو لبس. والله تعالى أعلم.

وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كتميم أو بديل لصيغة بنود هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي:

- توقع عقوبة التعزير بالسجن مدة أقصاها سنة أو بغرامة مالية أقصاها ألفان من الشلنات الصومالية وتكون العقوبة على الجريمة بناء على شكوى المجنى عليه، مع ضمان الشيء المأخوذ أو المتلف:

أ- إذا ارتكب الجانى الفعل بقصد واحد هو الإفادة المؤقته من المنقولات التى استولى عليها ثم أعادها مباشرة بعد استعمالها.

ب- إذا ارتكب السرقة في المنقولات تافهة القيمة بقصد مواجهة حالة ضرورة عاجلة وخطيرة وكان لديه مخرج آخر غيره، أما إذا لم يكن لديه مخرج آخر فتسقط العقوبة دون الضمان.

ج- إذا تضمن الفعل قطعا أو تكديسا أو جمعا من حقول شخص آخر لم تنقل المحاصيل منها بعد.

الخلاصة:

وبعد دراسة وتحليل المواد المتعلقة بهذا الفصل، وبيان التكييف الفقهي لنوع الجريمة الواردة في كل مادة، ومقارنتها بالشريعة الإسلامية لبيان الموافقة والمخالفة تبين ما يأتي:

أولا: أن هناك موادا خالفت العقوبات الواردة فيها الشريعة الإسلامية من جميع الجوانب و لم يمكن تخريجها بتاتا على أي مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة، وهذه المواد هي:

المادة ٤٨٠:

الجريمة التي وردت في القانون:

وردت في المادة جريمة الاستيلاء على المنقولات مملوكة للغير.

العقوبة التي وردة في القانون:

السجن مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائه شلن ولا تتجاوز خمسة آلاف شلنا صومالى.

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف الجريمة الواردة في المادة على أنها جريمة الغصب.

نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:

فبعد المقارنة وجد أن القانون يخالف الشريعة الإسلامية في عدم الحكم على الجانيوجوب رد المغصوب إذا كان بحاله و لم يتغير أو يتلف، والضمان حين تلفه، ويرد بزيادته إن زادت سواء كانت هذه الزيادة متصلة له أم منفصلة عنه وذلك لأنها نماء المغصوب، ويمكن اعتبار العقوبة الواردة فيه (السجن) من باب التعزير وبذلك يعتبر قاصرا عما نصت عليه الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

ثانيا: أن هناك موادا وافقت العقوبات الواردة فيها الشريعة الإسلامية من أكثر الجوانب وذلك بعد عرضها على المذاهب الفقهية المعتمدة، وهذه المواد هي:

المادة ٤٨١:

الجريمة التي وردت في المادة:

وردت في المادة جريمة محاولة الدخول الجاني مكان معد للسكن واستعمل القوة والعنف وكان معه صلاح ومواد مخدرة وإن لم يستخدمها.

العقوبة التي وردت في القانون:

السجن لمدة سنة إلى ستة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف شلن ولا تتجاوز عشرة آلاف شلن صومالى.

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف الجريمة الواردة في المادة على أنها تصرفات أو مقدمات ووسائل إلى السرقة.

نتيجة المقارنةبين الشريعة والقانون:

فبعد المقارنة وجد أن القانون لم يخالف الشريعة الإسلامية في الحكم على الجاني بالعقوبة البدنية والمالية بالحد الأدنى والأعلى حسب الظروف والملابسات، مادام أن مرتكب المقدمات يستحق التعزير،لأن الشريعة دائما تسعى إلى سد باب الجريمة وذلك بسد الطرق والوسائل المؤدية إليها، بل إن الشريعة أحيانا تعامل الوسائل بنفس معاملة المقاصد، وبذلك يعتبر أن هذه المادة موافقة لروح الشريعة من حيث الجملة.والله تعالى أعلم.

ثالثا: أن هناك موادا تبدوا في ظاهرها مخالفة، ولكن يمكن تخريجها بما يصححها ويجعلها موافقة لروح الشريعة الإسلامية، وهذه المواد هي:

المادة ٤٨٢:

الجريمة التي وردت في المادة:

وردت في المادة جريمة الإستيلاء، السرقة، الإتلاف.

العقوبة التي وردت في القانون:

السجن مدة أقصاها سنة أو بغرامة أقصاها ألفان من الشلنات الصومالية وتكون العقوبة على الجريمة بناء على الشكوى المجنى عليه:

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف الجريمة الواردة في المادة على أنها:

في البند (أ) استيلاء على ممتلكات الغير.

في البند (ب) سرقة.

في البند (ج) إتلاف.

نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:

في بند(أ)وبعد المقارنة وجد ان القانون خالف الشريعة الإسلامية في عدم مطالبة الجاني رد عين المغصوبة، والعقوبة التي حدد القانونعلى مرتكب هذه الجريمةهي بالسجن و بالغرامة المالية ويمكن أن نعتبرها من باب ردع المجرم وتقليل الإجرام فليس هناك أي إشكال في موافقت القانون بالشريعة، إذن تكون النتيجة أن القانون خالف الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

أما في البند (ب) وجد أن القانون خالف ما عليه بالشريعة الإسلامية فيمعاقبة من استفاد من ملك الغير(المضطر) لدفع الضرورة بكل من السجن لمدة عام واحد، والغرامة المالية، لأن الشريعةقد جعل هذا الشخص في مثل هذه الحالة في سعة من أمره أن يتصرف في ملك الغير بما ينقذ حياته ويدفع عنه الضرورة من غير اعتداء، ولكن الشريعة حملته هذا المستفيد بالضمانما استفاد به من ملك غيره، إذن أصبح القانون مخالف لما أتت به الشريعة الإسلامية لعدم مراعات تلك الأحوال. والله تعالى أعلم.

الفصل الثالث: الزنا وعقوباتها في القانون الصومالي. وفيه توطئة ومبحثان، وخلاصة:

التوطئة: في بيان ما يتعلق بالزنا من أحكام في الفقه الإسلامي، وسرد المواد المتعلقة بالزنا في نظام العقوبات الجنائية الصومالي.

وفيها فرعان:

الفرع الأول: في بيان ما يتعلق بالزنا من أحكام في الفقه الإسلامي.

مفهوم الزنا في الشريعة الإسلامية:

إن الزنا في الشريعة الإسلامية هي كل وطء محرم خال عن أي شبهة، وتعاقب الشريعةُ الفاعلَ والمفعولَ به سواء حدثت بين متزوجين أم غير متزوجين، أم بين متزوج وغيره، ذلك لأن الزنا رذيلة تمس كيان المجتمع وتؤدي إلى خرابه، وفقدان المسؤولية فيه، كما أنها تؤدي إلى عدم الاعتناء بنظام الأسرة، لذا حرصت الشريعة على المحافظة على المجتمع وبقاء نظام الأسرة وسلامتها وعدم السماح بكل عمل يؤدي إلى انفكاكها أو هتك حرمتها.

وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الزنا بناء على اختلافهم فيما يمكن أن يدخل في حده ويعتبر زنا أو لا يمكن اعتباره زنا، وكذلك في بعض الشروط التي لاحظوها في الزنا، فلذا سوف تعرض الباحثة تعريفا واحدا للزنا في كل مذهب من المذاهب الأربعة ثم تعقب ذلك ببيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، ومن ثم بيان التعريف الذي تراه مناسبا:

تعريف الزنا اصطلاحا:

أولا: تعريف الحنفية:

لقد عرف الحنفية الزنا بأنها: "وطء الرجل المرأة في القبل في غير ملك وشبهة الملك"[١].

شرح التعريف:

وطء: أي إيلاج فرج الرجل في فرج المرأة[٢]. هذا الوطء يخرج منه مادونه كالقبلة والمعانقة، أما الوطء في القبل يخرج منه الوطء في الدبر لأن هذا الوطء لا يسمى زنا عند الحنفية.

في غير ملك: والمراد بالملك هنا الأعم من ملك العين ومن ملك حقيقة الاستمتاع[٣].

وشبهة الملك: أي شبهة عقد النكاح كما إذا وطئ إمراة تزوجها بغير شهود أو بغير إذن وليها[٤].

ثانيا: تعريف المالكية:

أما تعريف الزنا عند المالكية فهو : "وطء مكلف فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا"[٥].

وطء مكلف:يخرج وطء الصبي والمجنون لأن وطء المجنون والصغير لا يعتبر زنا.[٦].

فرج آدمي: قوله في فرج أخرج به مغيبها في غير فرج، وفي قوله آدمي:أخرج به حشفة غيره[٧].

---

(١) ابن الهمام، **فتح القدير**، ج:٥، ص: ٢٤٧.

(٢) السمرقندي، محمد، **تحفة الفقهاء**، ط:الثانية،١٤١٤هـ-١٩٩٤م دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، ج:٣، ص:١٣٨.

(٣) ابن نجيم، **البحر الرائق** ، ج:٥، ص:٥.

(٤) البابرتي، **العناية شرح الهداية**، ج:٥،ص:٢١٣.، السمرقندي، **تحفة الفقهاء**،ج:٣،ص:١٣٩.

(٥) الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل، ج٦، ص:٢٩١.

(٦) ابن الهمام، **فتح القدير**، ج:٥،ص:٢٤٧.

(٧) ابن عرفه، **شرح حدود ابن عرفة**، ج:١،ص:٤٩٢.

باتفاق: أي أن يتفق الطرفان على فعل الزناوبإرادة كاملة ليس فيه عنوة ولا غصب.

تعمدا: أي أن يقصد الطرفان ارتكاب هذه الجريمة، ويخرج ما حصل من غير قصد كالوطء في نكاح فاسد كمن وطء امرأة بعقد نكاح ثم تبين أنها أخته من الرضاعة.

ثالثا: تعريف الشافعية:

من تعريفات الشافعية للزنا أنها: " إيلاج الذكر في فرج محرم لعينه خال من الشبهة"[١].

إيلاج الذكر: إدخال فرج الرجل في فرج غيره[٢].

محرم لعينه:يخرج به عن وطء المنكوحة الصائمة والمحرمة والحائض والرجعية فلا حد فيه إذ ليس التحريم لعينه[٣].

خال من الشبهة: أي شبهة عقد النكاح كما إذا وطئ امراة تزوجها بغير شهود أو بغير إذن مولاها[٤].

رابعا: تعريف الحنابلة:

لقد عرف الحنابلة الزنا بأنها: " فعل الفاحشة في قبل أو دبر"[٥].

---

(١) الشربيني، **مغني المحتاج إلى معرفة الألفاظ**، ج:٥،ص:٤٤٢

(٢) السمرقندي، **تحفة الفقهاء**، ج:٣،ص:١٣٨.

(٣) محمد الغزالي، أبو حامد، **الوسيط في المذهب**، ط:الاولى،١٤١٧دار السلام –القاهرة، ،ج:٦،ص:٤٤٣.

(٤) البابرتي، **العناية شرح الهداية،للبابرتي**، ج:٥،ص:٢١٣.، السمرقندي، **تحفة الفقهاء**، ج:٣،ص:١٣٩.

(٥) الحجاوي، موسى بن موسى بن سالم بن عيسى بن بن سالم، **الإقناع في فقه الإمام احمد بن الحنبل**، النشر: دار المعرفة بيروت- لبنان، ج٤ ص٢٥٠.

فعل الفاحشة: الفاحشة هي الزنا كما جاءت هذه الآية: ﴿ وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ﴾[1]. ومعنى فعل الفاحشة وقوع الزنا سواء في القبل أو في دبر.

وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن العلماء اتفقوا في بعض الجوانب واختلفوا في البعض الآخر، فمما اتفقوا عليه أن الزنا هو الوطء في قبل محرم شرعا مشتهى طبعا، بمعنى أن الشارع حرم هذا الوطء و لم يبحه بحال من الأحوال لا في ضرورة ولا في غيرها، وأن يكون موضع الوطء مما يشتهى طبعا وسوف يأتي تفصيل الكلام في ذلك عند الكلام عن التعريف الراجح للزنا في نظر الباحثة، وأن يكون هذا الوطء عن تعمد واختيار وبلا شبهة، واختلفوا في دخول الوطء في غير القبل في حد الزنا، فالحنفية لا يرون أن الوطء في الدبر يسمى زنا سواء كان الموطوء ذكرا أم أنثى، وبالتالي لا يسري عليه حكم الزنا من وجوب الحد، وإن كانوا يرون إيقاع عقوبات أخرى على الفاعل تعزيرا، بينما يرى الأئمة الثلاثة إلحاق الواطئ في الدبر بالواطئ في القبل في التسمية وفي إيجاب الحد (حد الزنا) على مرتكبه، إلا أنهم اختلفوا في حقيقة وصف هذا الحد:

فقال بعضهم يجب عليه حد الزنا: فيرجم إن كان محصنا، ويجلد ويغرب إن كان غير محصن، وهو أظهر قولي الشافعي[2]، وإحدى روايتين عن أحمد[3].

وقال بعضهم يجب عليه حد القتل: وهو قول مالك[4] والشافعي[5]في أحد قوليه وراية عن أحمد[1].

---

(١) سورة النساء، الآية:١٥.

(٢) النووي، **روضة الطالبين وعمدة المفتين**، ج١٠، ص٩٠.

(٣) ابن قدامه، **المغني**، ج٩، ص٦٠.

(٤) النفراوي، أحمد ابن غانم، **الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيدالقيرواني**، دار الفكر، ١٤١٥ه، ١٩٩٥م، ج٢، ص٢٠٩.

(٥) النووي، **روضة الطالبين وعمدة المفتين**، ج١٠، ص٩٠.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٣﴾﴾[٢].

وهذه المسألة مبنية على مسألة أصولية وهي إثبات الحدود بالقياس أو جريان القياس في الحدود، وفيها الخلاف المشهور بين الحنفية والجمهور[٣].

والباحثة ترجح التفريق بينهما في الحكم بين الوطء في القبل والوطء في الدبر بناء على التفريق بينهما في اللغة حيث سمي الإتيان في القبل المحرم زنا والإتيان في الدبر لواطا، هذا من ناحية اللغة، ومن ناحية المقصد الشرعي، فإن الزنا يؤدي إلى اشتباه واختلاط الأنساب وتضييع الأولاد وعدم وجود المسؤول عنهم مما يؤدي إلى انتشار أولاد الطرقات، فيصبحوا آفة في المجتمع، وليس الأمر كذلك في اللواط، يقول الكاساني رحمه الله تعالى: (وَاخْتِلَافُ الْأَسَامِي دَلِيلُ اخْتِلَافِ الْمَعَانِي فِي الْأَصْلِ وَلِهَذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ في حَدِّ هذا الْفِعْلِ وَلَوْ كان هذا زِنًا لم يَكُنْ لِاخْتِلَافِهِمْ مَعْنًى لِأَنَّ مُوجِبَ الزِّنَا كان مَعْلُومًا لهم بِالنَّصِّ فَثَبَتَ أَنَّهُ ليس بِزِنًا وَلَا في مَعْنَى الزِّنَا أَيْضًا لِمَا في الزِّنَا من اشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ وَتَضْيِيعِ الْوَلَدِ و لم يُوجَدْ ذلك في هذا الْفِعْلِ إنَّمَا فيه تَضْيِيعُ الْمَاءِ الْمَهِينِ الذي يُبَاحُ مِثْلُهُ بِالْعَزْلِ ... فلم يَكُنْ في مَعْنَى الزِّنَا فَوُرُودُ النَّصِّ هُنَاكَ ليس وُرُودًا هَهُنَا وَكَذَا اخْتِلَافُ اجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ دَلِيلٌ على أَنَّ الْوَاجِبَ بِهذا الْفِعْلِ [اللواط] هو التَّعْزِيرُ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ التَّعْزِيرَ هو الذي يَحْتَمِلُ الِاخْتِلَافَ في الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ لَا الْحَدِّ وَالثَّانِي

---

(١) ابن قدامه، **المغني**، ج٩، ص٦٠.

(٢) سورة الذاريات، الآية:٣٣.

(٣) حيث ذهب الجمهور إلى إثبات الحدود بالقياس، ومنعه الحنفية.

احتج القائلون بإثبات القياس في الحدود بأن الدليل الدال على حجية القياس يتناولهما بعمومه فوجب العمل به فيهما، ويؤيد ذلك أن صحابة حدو في الخمر القياس حتى تشاورو فيه فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا شرب سكر وإذا سكر هدى وإذا هدى إفترى فأرى عليه حد الإفتراء، فأقام مظنة الشيء مقامه وذلك هو القياس.

واحتج المانعون بأن الحدود مشتملة على التقديرات لا تعقل، كعدد المائة في الزنا والثمانين في القدف فإن العقل لا يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد، والقياس فرع تعقل معنى حكمة الأصل. الآمدي، أبو الحسن، **الأحكام في أصول الأحكام**، **ت**حقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتبة الإسلامي، بيروت–دمشق– لبنان، ج٤، ص٦٢.

أَنَّهُ لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِي الْحَدِّ بَلْ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِالتَّوْقِيفِ وَلِلِاجْتِهَادِ مَجَالٌ فِي التَّعْزِيرِ)[1] وعليه فإن الباحثة ترجح تعريف الحنفية وهو أن الزنا هي: (وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك).

هذا وقد اعتبر القانون الجنائي الصومالي ولوج العضو الذكري جماعا جنسيا مما يوحي بأن أي ولوج يدخل في هذا الاعتبار، إلا أنهم فرقوا بين الجرائم الطبيعية التي هي ولوج العضو الذكري في قبل المرأة فاعتبروها زنا حقيقية، والجرائم غير الطبيعية وهي الاستمتاع بغير الإيلاج مطلقا أو الإيلاج في غير القبل، وهذا يدل على التفريق بين الزنا واللواط في القانون. والله تعالى أعلم.

أركان الزنا:

لئن كان سبق الكلام أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريف الزنا، إلا أنهم اتفقوا عموما على أن الزنا هو الوطء المحرم المتعمد، ومؤدى هذا أنهم متفقون على أن لجريمة الزنا ركنين، أولهما: الوطء المحرم، وثانيهما تعمد الوطء، وستتناول الباحثة الركنين بشيء من التفصيل وذلك ببيان الاتفاق والاختلاف فيهما.

الركن الأول: الوطء المحرم:

الوطء المعتبر زنا: هو الوطء في الفرج المحرم بحيث يكون الذكر في الفرج كالميل في المكحلة والرشاء في البئر، وإدخال الحشفة أو قدرها في الفرج يعتبر زنا، سواء حدث إنزال أم لم يحدث،والقاعدة أن الوطء المحرم المعتبر زنا هو الذي يحدث في غير ملك، أما إذا حدث الوطء أثناء قيام الملك فلا يعتبر زنا ولو كان الوطء محرما كوطء الرجل زوجته الحائض أو الصائمة فلا حد في هذه الأحوال لأن التحريم ليس لعينه بل لأمور عارضة[2].

---

(١) الكاساني، **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج:٧، ص:٣٤.

(٢) الحجاوي، **الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل**، ،ج:٤،ص:٢٥٦.،عبد القادر عودة، **التشريع الجنائي الإسلامي**، ج:٢،

أما الوطء في الدبر فيقاس على الوطء في القبل عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومحمد وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة،فيستوي في الحكم والتسمية أن يكون الوطء المحرم في قبل أو دبر من أنثى أو رجل.

وحجتهم في التسوية أن الوطء في الدبر مشارك للزنا في المعنى، ويستدلون بقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ [1]، وقال أيضا: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾[2]. فجعل الوطء في الدبر فاحشة، والوطء في القبل فاحشة فسمى أحدهما بما سمى به الآخر.

ويرى أبو حنيفة أن الوطء في الدبر لا يعتبر زنا سواء أكان الموطوء ذكرا أم أنثى، وحجته أن الإتيان في القبل يسمى زنا والإتيان في الدبر يسمى لواطا واختلاف الأسامي دليل على اختلاف المعاني ولو كان اللواط زنا لما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه[3].

الركن الثاني: تعمد الوطء

لكي يعتبر الوطء المحرم زنا شرعا يشترط فيه أن يكون عن تعمد وقصد لفعل الوطء، وذلك بأن يرتكب الزاني الفعل متعمدا وهو عالم أنه يطأ امرأة محرمة عليه، وكذلك إذا مكنت المرأة من نفسها وهي تعلم أن من يطأها محرم عليها، فإن أتى أحدهما الفعل متعمدا وهو لا يعلم بالتحريم فلا حد عليه، كمن زفت إليه غير زوجته فوطئها على أنها زوجته، وكذلك المرأة[4].

ص:٣٥٠، **مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج**، ج:٥، ص:٤٤٣.

(١) سورة النساء، الآية:١٥.

(٢) سورة العنكبوت، الآية:٢٨.

(٣) الكاساني، **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج٧، ص:٣٤

(٤) عبد القادر العودة، التشريع الجنائي، ج:٢ ص:٣٧٤.

تحريم الزنا:

ثبت تحريم الزنا بالكتاب والسنة والإجماع:

أولا: تحريم الزنا من الكتاب:

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾[1]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [2].

ثانيا: تحريم الزنا من السنة:

١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ))[3].

٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا) [4].

عقوبة الزنا:

كانت عقوبة الزنا في أول الإسلام الحبس في البيوت إلى الموت والأصل في ذلك لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي

---

(١) سورة الإسراء،الآية:٣٢.

(٢) سورة الفرقان: الآية:٦٨.

(٣) البخاري، **صحيح البخاري مع الفتح**، كتاب الحدود، باب لا يشرب الخمر،حديث رقم٦٧٧٢، ج٨، ص١٥٧.

(٤) المصدر نفسه، كتاب النكاح، باب الغيرة، حديث رقم:٥٢٢١، ج:٧ ص:٣٥.

ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ﴾ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (كان الحكم في بداية الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة، حبست في البيت فلا تمكن الخروج منه إلى أن تموت، ولهذا قال: ﴿ وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ ﴾ يعني الزنا ﴿ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ﴾ ، فالسبيل الذي جعل الله هو الناسخ لذلك، قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور، فنسخها بالجلد أو الرجم)[1].

ولكن الحكم الذي جاء في الآية: ﴿ وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ﴾ جاء بحكم النساء فقط وليس فيه حكم الرجال، وأما النص الثاني في الآية التي بعدها: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا ١٦ ﴾ [2]. فقد جاء العطف على النص الأول عطفا متصلا بقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَا ﴾ فكان هذا حكما زائدا للرجال مضافا إلى ما قبله من حكم النساء[3].

ولكن هذين النصين نسخا بقوله تعالى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴾ [4].

وهذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد، وللعلماء فيه تفصيل، فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج، أو محصنا وهو الذي وطء في نكاح صحيح وهو حر بالغ.

---

(١) ابن الكثير، إسماعيل، **تفسير القرآن العظيم**، ط١،سنة١٤٢١ه-٢٠٠٠ م مؤسسة القرطبة،مصر، ج٢ص:٢٠٤.

(٢) سورة:النساء، الآية:١٦

(٣) المحلى، جلال الدين، **تفسير الجلالين**، ط:الأولى دار الحديث-القاهرة، ،ج:١،ص:١٠٢.

(٤) سورة النور، الآية٢.

فإذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده مائة جلدة ويزاد في ذلك عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة أن يغرَّب عاما عن بلده، وأما أبو حنيفة وأصحابه فيرون أن التغريب ليس واجبا، ولكنهم يجيزون أن يجمع الإمام بين الجلد والتغريب إن رأى في ذلك مصلحة، فعقوبة التغريب عندهم ليست حدا وإنما هي عقوبة تعزيرية، ويرى مالك والشافعي وأحمد وجوب الجمع بين الجلد والتغريب[1].

وإذا كان محصنا وهو الذي وطء في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإنه يرجم[2].

دليل عقوبة الزاني غير المحصن:

عقوبة الزاني غير المحصن يعني البكر سواء كان رجلا أم امرأة جلد مائة والتغريب عاما، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ))[3].

وكما جاء في قصة العسيف: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم: فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله واذن لي قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فاخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره؛ المائة شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها)[4].

---

(١) الكاساني، **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج٧ ص:٣٩.

(٢)ابن كثير، **تفسير ابن كثير**، مصدرالسابق، ج٦ ص:٣.

(٣) الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا،ج:٣ ص:١٣٢٣.

(٤) البخاري، **صحيح البخاري مع الفتح**، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، حديث رقم:٦٨٢٧، ج٨ ص١٦٧.

عقوبة الزاني المحصن:

إن عقوبة الزاني المحصن تكونالرجم،وهذا القول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين معا، ولكن الخلاف بين الفقهاء هل يجب الجمع بين الجلد والرجم:

لا يجمع بين الجلد والرجم، ويكون الجلد في حق غير المحصن والرجم في حق المحصن وبه قال الحنفية[١]، والمالكية[٢]، والشافعية[٣]، وراية عن احمد، وفي رواية أخرى عنه: يجمع بين الجلد والرجم[٤].

شروط الحد:

تقدم آنفا أن الزاني والزانية يجب على كل واحد منهما حدا وهو إما الجلد والنفي إذا كان الزاني بكرا غير المحصن، وإما الرجم إذا كان محصنا، ولكن الإقامة هذا الحد شروط وهي:

الشرط الأول: أن يطأ الزاني في فرج أصلي من آدمي حي قبلاكان أو دبرا، بذكر أصلي وأقله تغييب الحشفة من فحل أو خصي أوقدرها عند عدمها، فإن وطء دون الفرج أو تساحقت امرأتان أو جامع خنثي المشكل أو جومع في قبله فلا حد ولكن عليهم التعزير، ولو وجد رجل مع امرأة يقبل كل منهما الآخر و لم يعلم أنه وطئها فلا حد ولكن عليهما التعزير.

الشرط الثاني: أن يكون الزاني مكلفا فلا حد على الصغير والمجنون[٥].

---

(١) السرخسي، **المبسوط**، ج٩ ص٣٦.

(٢) القاضي، **التلقين في الفقه المالكي**، ج٢ ص١٩٧.

(٣)المزني، **مختصر المزني**، ج٨، ٣٦٨.

(٤)الكلوذاني، محفوظ ابن أحمد، **الهداية على مذهب الإمام أحمد**، المحقق:عبد اللطيف- ماهر ياسين، موسسة الغراس للنشروالتوزيع، ط الأولى: ١٤٢٥ه-٢٠٠٤م، ج١، ص٥٣٠.

(٥) الحجاوي، **الإقناع في فقه إمام أحمد**، ج:٤ ص:٢٥٣-٢٥٦.

شرط الثالث:انتفاء الشبهة، إذا حدث الوطء أثناء قيام الملك فلا يعتبر الفعل زنا ولو كان الوطء محرما كأن يطأ الرجل زوجته الحائض أو النفساء أو الصائمة كل ذلك حرام ولكنه لا يعتبر زنا[1].

الشرط الرابع: ثبوت الزنا، تثبت الزنا بأحد أمرين هما:

الإقرار، والشهادة

الأمر الأول: الإقرار هو أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا، لأن قول الصبي والمجنون لايعتبر أو غير موجب للحد[2].

فذهب مالك[3]، والشافعي[4] إلى عدمشتراط التكرار مستدلين بأن الأصل عدم اشتراطه في سائر الأقارير كالقتل والسرقة، وبأنه- صلى الله عليه وسلم-قال لأنيس: ((فإن اعترفت فارجمها)) ولم يذكر له تكرار الاعتراف فلو كان شرطا معتبرا لذكره صلى الله عليه وسلم، وذهب أبو حنيفة[5]، وأحمد[6]، إلى أنه يشترط في الإقرار بالزنا أربع مرات مستدلين بحديث ماعز، وهو ما روي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

---

(١) الرملي، شمس الدين، **نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج**، ج:٧، ص:٢٤٢.

(٢) البابرتي، **العناية شرح الهداية**، ج:٥، ص:٢١٨.

(٣) القاضي عبد الوهاب، **أبو محمد، التلقين في الفقه المالكي**، المحقق: أبي أويس، محمد، دار الكتب العلمية، ط الأولى:١٤٢٥ه-٢٠٠٤م، ج٢، ص١٩٧.

(٤) الصنعاني، **سبل السلام**، ج٢، ص: ٤٠٩.

(٥) البابرتي، العناية شرح الهداية،ج:٥،ص:٢١٨.

(٦) البهوتي،كشاف القناع عن متن الإقناع، ج٦، ص١٠٣.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((أَبِكَ جُنُونٌ؟)) قَالَ: لَا، قَالَ: ((فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟)) قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ))[1].

الأمر الثاني: الشهادة:

من المتفق عليه أن الزنا لا تثبت إلا بشهادة أربعة رجال مسلمين عدول وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم[2]. لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾[3].

الفرع الثاني: سرد المواد المتعلقة بالزنا:

جرائم ضد الأخلاق والآداب العامة

المادة٣٩٨ العنف الجنسي:

١- كل من واقع بالعنف أو بالتهديد يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين الخمس سنوات والخمسة عشر سنة.

٣- توقع نفس العقوبة على الشخص الذى يواقع أنثى ليست أهلا للرضا أو يواقع أنثى مدعيا أنه شخص آخر.

---

(١) مسلم، **صحيح مسلم بشرح النووي**،كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا ،ج٣ ص:١٣١٨، حديث رقم:١٦٩١.

(٢) الإقناع في فقه إمام أحمد، ج:٤ ص: ٢٥٣-٢٥٦.

(٣) سورة النساء،الآية: ١٥.

٣- توقع نفس العقوبة أيضا على كل موظف عمومى أساء استعمال سلطته بأن زنى بأنثى قبض عليها أو عهد إليه بالتحفظ عليها بحكم وظيفته أو التنفيد الأمربشأنها صادر من السلطات المختصة.

٤- يعتبر عند التطبيق قانون العقوبات ولوج العضو الذكر جماعا جنسيا.

المادة ٣٩٩

كل من ارتكب مع أنثى مستعملا الوسائل المبينة في المادة السابقة أو متأثرا بظروفها فعلاً من أفعال الشهوة بخلاف الجماع الجنسى يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.

المادة(٤٠٠) **الجرائم غير الطبيعية ترتكب بالعنف :**

تزداد العقوبة فى الحالة ارتكاب الفعل من الأفعال المشار إليها فى المادتين ٣٩٨ و٣٩٩ مع الشخص من نفس الجنس أو من جنس آخر بطريقة غير الطبيعية.

المادة ٤٢٦**الزنا:**

١- كل شخص مرتبط بعلاقة زوجية منتجة لآثارها القانونية باشر علاقة جنسية مع غير زوجة يعاقب بالسجن مدة أقصاها سنتان وتوقع نفس العقوبة على الشريك فى الجريمة.

٢- تقام الدعوي فى الجريمة بناء على شكوى مجني عليه.

المادة ٤٢٧ **الزنا بالمحارم:**

١- كل من زنى بامرأة أو كل امرأة زنت بآخر محظور عليهما الزواج ببعضهما وفق قواعد الأحوال الشخصية يعاقب كل منهما بالسجن مدة لاتقل عن سنتين ولا تتجاوز عن خمس سنوات.

٢- تزداد العقوبة فى حالة وجود علاقات جنسية بالمحارم.

جرائم ضد الأخلاق والآداب العامة

المادة ٣٩٨ العنف الجنسي:

١- كل من واقع بالعنف أو بالتهديد يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين الخمس سنوات والخمسة عشر سنة.

٢- توقع نفس العقوبة على الشخص الذى يواقع أنثى ليست أهلا للرضا أو يواقع أنثى مدعيا أنه شخص آخر.

٣- توقع نفس العقوبة أيضا على كل الموظف عمومى أساء استعمال سلطته بأن زنى بأنثى قبض عليها أو عهد إليه بالتحفظ عليها بحكم وظيفته أو التنفيد الأمربشأنها صادر من السلطات المختصة.

٤- يعتبر عند التطبيق قانون العقوبات ولوج العضو الذكر جماعا جنسيا.

المادة ٣٩٩

كل من ارتكب مع أنثى مستعملا الوسائل المبينة في المادة السابقة أو متأثرا بطروفها فعلا من افعال الشهوة بخلاف الجماع الجنسى يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.

المبحث الأول: المواد المتعلقة جرائم ضد الأخلاق والآداب العامة:

جرائم ضد الأخلاق والآداب العامة

المطلب الأول: المادة٣٩٨ العنف الجنسي:

أولا: نص المادة

١- كل من واقع بالعنف أو بالتهديد يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين الخمس سنوات والخمس عشرة سنة.

٢- توقع نفس العقوبة على الشخص الذى يواقع أنثى ليست أهلا للرضا أو يواقع أنثى مدعيا أنه شخص آخر.

٣- توقع نفس العقوبة أيضا على كل موظف عمومى أساء استعمال سلطته بأن زنى بأنثى قبض عليها أو عهد إليه بالتحفظ عليها بحكم وظيفته أو تنفيذ الأمر بشأنها صادر من السلطات المختصة.

٤- يعتبر عند تطبيق قانون العقوبات ولوج العضو الذكر جماعا جنسيا.

ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة:

تضمنت المادة (٣٩٨) من خلال بنودها الأربعة عددا من أنواع مواقعة المرأة عن طريق القوة والعنف، أو الخداع أو استغلال السلطة أو غير ذلك، ففي البند الأول نُصّ على أن من واقع أنثى بغير رضاها وذلك باستخدام العنف أو التهديد؛ يعاقب بالسجن، ويقصد بالمواقعة ههنا الجماع الجنسي وهو ولوج عضو الذكر في قبل المرأة كما أشار إليه البند الرابع من المادة نفسها،

فهذا النوع من المواقعة يسمى بالاغتصاب، والغصب هو أخذ الشيء ظلما[1]، وهذا طبعا ليس تعبير الفقهاء حيث إنهم يستخدمون كلمة الاغتصاب في أخذ الشيء بالقوة والغلبة والقهر دون رضا صاحبه، ونادرا ما يستخدمونها بمعنى راتكاب الفاحشة مع المرأة مباشرة بل يضيفون إليها لفظ يدل على ذلك: كقولهم: من اغتصب امرأة ووطئها أو زنى بها للتفريق بين الاغتصاب وبين الزنى، بل يعبرون عن مثل هذا بالإكراه، إلا أن هذا المصطلح أصبح الآن يستخدم فيمن غصب امرأة فقط وأيا كان فإن المواقعة تعتبر زنا وبالتالي يعتبر مرتكبها زانيا، وعليه؛فالجريمة في نظر الإسلام هي زنا. وعندما ننظر إلى هذا البند نجد أن القانون لا يعاقب إذا كانت المواقعة بالرضا.

ونص البند الثاني من المادة على نوع آخر من المواقعة، وهي مواقعة امرأة ليست أهلا للرضا، أي أن رضى مثلها لا يعتبر في القانون كأن تكون صغيرة غير مميزة، أو مجنونة، أو سفيهة بحيث يسهل خداعها، وهذا طبعا واضح أنه يعتبر زنا في الشريعة الإسلامية بلا خلاف.

وتحدث البند الثالث عن نوع آخر من أنواع المواقعة وهو استغلال الوظيفة أو السلطة، بأن يرتكب الموظف العمومي جريمة المواقعة مع امرأة دخلت تحت مراقبته مستغلا في ذلك سلطته، فإن هذه المواقعة أيضا تعتبر زنا في نظر الشريعة الإسلامية، وإن كان الموظف قد أساء العمل أيضا حيث خان الأمانة التي أؤتمن عليها.

وأما البند الرابع فقد أعطى تعريفا واضحا لما يعتبره القانون مواقعة أو زنا وهو: لوج عضو الذكر جماعا جنسيا. الولوج هو الدخول أي إدخال الذكر، ويقصد بذلك تحقق هذا الإدخال مطلقا سواء كان في القبل أو في الدبر، وسواء كان مع ذكر أو امرأة، إلا أن التقييد الوارد في نهاية الفقرة وهو (جماعا جنسيا) يفهم منه أن المقصود به الإيلاج في قبل الأنثى، وذلك لعدة أمور:

١- أن المادة الموجود بها البند تتكلم في جملتها عن ارتكاب المواقعة مع أنثى كما هو بين في البنود الثلاثة الأُوَل.

---

(١) التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، ج:١،ص:١٦٢.

٢- ثانيا: أن القانون سمى بقية أنواع الإيلاج بمسى آخر وهو: جرائم غير طبيعية.

وعليه فيكون تعريف الزنا حسب القانون: إيلاج ذكر في قبل غير شرعي مطلقا وبغير رضا الطرف الآخر، أو برضا من لا يعتبر رضاها. والله تعالى أعلم.

وبعد معرفة تكييف أنواع الجرائم المذكورة في المادة، آنت الأواني أن نعرضها على الفقه الإسلامي لمعرفة الموافقة والمخالفة.

ثالثا:مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة:

إن العقوبة المقررة لدى القانون في أنواع المواقعة الثلاثة السابق ذكرها هي السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة، يعني أن أقلها خمس سنوات، وأعلاها خمس عشرة سنة، وبالنظر إلى التكييف الفقهي لهذه الأنواع الثلاثة تبين أنها جميعا تعتبر زنا وبالتالي تكون عقوبتها في الشريعة الإسلامية عقوبة الزنا وهي الرجم إن كان الجاني محصنا والجلد والتغريب – على خلاف في التغريب- إن كان بكرا.

ولكن هناك ملاحظة حيث قد تقدم في البند الأول أن الفعل يسمى اغتصابا، فهل يترتب على هذا الفعل أي غرامات أخرى غير الحد، وهذا ما تناوله علماء الفقه الإسلامي وعبروا عنه بوجوب الصداق على المغتصب، وقد اختلفوا في ذلك:

فقال مالك والليث والشافعي: المستكرهة إن كانت حرة فلها صداق مثلها على من استكرهها إضافة إلى الحد[1].

وقال أبو حنيفة. وأبو يوسف ومحمد وسفيان الثوري عليه الحد دون الصداق[1].

---

(١) ابن عبد البر، أبو عمر،**الإستدكار**، المحقق: سالم محمد عطا، دار الكتب العلمية-بيروت، ط:الأولى١٤٢١ه- ٢٠٠٠م ج:٧ ص:١٤٦، الشافعي، الأم، ج٣ ص٢٦٤.

والذي تراه الباحثة أن على المغتصب الصداق كما ذكره أصحاب القول الأول، بدليل أن الحد والصداق حقان مختلفان، أحدهما لله والثاني للمخلوق فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة ورد المسروق.

وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصب الحد إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد أو أقر بذلك وإن لم يكن فعليه العقوبة ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها وذلك يعلم بصراخها وإن كانت بكرافما يظهر من دمها[٢].

وكذلك في البند الثاني فإن الفعل وإن لم يسم اغتصابا إلا أنه ارتكاب الفعل لمن ليست أهلا للرضا أو لمن تخدع مثلها غالبا، فهل يجب على الفاعل صداق أو لا، فهذا فيه تفصيل، وذلك أن الصغيرة تنقسم إلى صغيرة تميز وصغيرة لا تميز، فإن كانت تميز ومكّنت رجلا من نفسها فوطئها فإن كان مثلها يخدع فلها الصداق، وإن كان مثلها لا يخدع فلا صداق لها[٣].

وبذلك يتبين أن العقوبة الواردة في القانون وهي السجن ما بين خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة مخالفة لما أقره الفقه الإسلامي من وجوب الحد على المرتكب في الأنواع الثلاثة، وثبوت الصداق في النوع الأول والثاني، وبعد ذلك يرجع الأمر إلى الحاكم أو القاضي أو ولي الأمر في إضافة أي عقوبات تعزيرية أخرى لردع غيره من الإقدام على ارتكاب هذه الجرائم من حبس أو غيره مما يرى فيه المصلحة للمجتمع. والله تعالى أعلم.

وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كتميم أو بديل لصيغة بنود هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي:

---

(١) الباجي، أبوالوليد، **المنتقى شرح الموطأ**، ، ج:٥ ص:٢٦٨-٢٦٩،

(٢) ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد **الاستذكار**، ،ج٧ ص:١٤٦.

(٣) الاستذكار، مرجع سابق، ج٧ ص:١٤٦.

١- كل من واقع بالعنف أو بالتهديد يقام عليه حد الزنا، وهو الجلد والتغريب إذا كان بكر، والرجم إذا كان محصنا مع وجوب الصداق عليه.

٢- توقع نفس العقوبة على الشخص الذى يواقع أنثى ليست أهلا للرضا، أو يواقع أنثى مدعيا أنه شخص آخر وظهر كذبه في دعواه.

٣- توقع نفس العقوبة أيضا على كل موظف عمومى أساء استعمال سلطته بأن زنى بأنثى قبض عليها أو عهد إليه بالتحفظ عليها بحكم وظيفته أو التنفيد الأمربشأنها صادر من السلطات المختصة.

المطلب الثاني:المادة٣٩٩

أولا: نص المادة:

كل من ارتكب مع أنثى مستعملا الوسائل المبينة في المادة السابقة أو متأثرا بظروفها فعلا من أفعال الشهوة بخلاف الجماع الجنسى يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.

ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة:

تشير المادة إلى أن من ارتكب فعلا من الأفعال التي يؤدي إلى قضاء شهوته دون الجماع الجنسي الذي هو الإيلاج –كما أشار إليه البند الرابع من المادة السابقة- مستخدما الوسائل والظروف المشار إليه في المادة السابقة في بنودها الثلاثة الأولى وهي العنف أو التهديد أو الخداع أو استغلال السلطة أو برضى من ليست أهلا للرضا وهذا لا يسمى زنا في الفقه الإسلامي وإنما هو سوء الخلق والإتيان بمقدمات الزنا.

وبعد هذه الدراسة والتحليل فلنعرض المادة على الشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة أو المخالفة.

ثالثا:مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة:

يلاحظ أن حدد عقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات، وما دامت هذه الجريمة ليست بزنا فإن عقوبته تكون تعزيرية، لذلك يمكن اعتبار هذه العقوبة من باب التعزير، وهذا تقره الشريعة الإسلامية وتعطي صلاحية تحديد نوع العقوبة للحاكم أو القاضي ذلك لأن الشريعة تعاقب كل من خالف الآداب العامة بعقوبة تعزيرية من ضرب أو حبس أو فرض غرامة أو غير ذلك مما فيه المصلحة لردع من تسول له نفسه الإقدام على ما يشينالمجتمع.

ملاحظة: تم تناول هذه المادة بالدراسة –وإن كان الفعل الوارد فيها لا يعتبر زنى– وذلك لأنها جاءت ضمن مواد الزنا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الفعل الوارد فيها يعتبر مقدمة للزنا فكان حريا أن تتناول بشيء من التفصيل. والله تعالى أعلم.

وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كتميم لصيغة هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي:كل من ارتكب مع أنثى مستعملا الوسائل المبينة في المادة السابقة أو متأثرا بظروفها فعلا من أفعال الشهوة بخلاف الجماع الجنسى يعاقب تعزيرا بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.

المطلب الثالث: المادة ٤٢٦

أولا: نص المادة:

١– كل شخص مرتبط بعلاقة زوجية منتجة لآثارها القانونية باشر علاقة جنسية مع غير زوجه يعاقب بالسجن مدة أقصاها سنتان وتوقع نفس العقوبة على الشريك فى الجريمة.

٢– تقام الدعوى فى الجريمة بناء على شكوى مجني عليه.

ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة:

المادة ٤٢٦ من قانون العقوبات الصومالي ورد في بندها(١) حكم الزنا للأشخاص المتزوجين إذا باشروا علاقة جنسية مع غير أزواجهم، وحدد القانون العقوبة في هذه الحالة بالسجن مدة أقصاها سنتان وفي نفس الوقت توقع العقوبة ذاتها على الشريك في الجريمة، بعد النظر في هذه

الجريمة نجد أنها جريمة الزنا لأن القانون نص على مباشرة العلاقة الجنسية من المتزوج للطرف الآخر قد يكون متزوجا وقد لا يكون، ومباشرة العلاقة الجنسية هي الزنا في الشريعة الإسلامية بغض النظر عن حصول التراضي بين الفريقين أو عدم حصوله، والقانون لم يفرق في الحكم بين ما إذا كان الطرف الآخر متزوجا أو لا.

أما البند (٢) من المادة فقد ورد فيه أن العقوبة توقع بناء على شكوى الزوج أو الزوجة، وهو كذلك في الشريعة إلا أن الشريعة تطالب المشتكي بالبينة أو القيام بالملاعنة في حال عدم وجود البينة كما ورد ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴾[1]..، وهذا ما لم يتناوله القانون بالتفصيل.

وبعد التحليل ومعرفة حكم القانون نعرضه على الشريعة الإسلامية لمعرفة الوافقة والمخالفة.

ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة:

إن القانون الصومالي في البند الأول من المادة ٤٢٦ نص على أن عقوبة المتزوج إذا ارتكب جريمةالزنا هي السجن مدة أقصاها سنتان ويعاقب أيضا نفس العقوبة الشريك في الجريمة، هذا الحكم مخالف تماما لما في الشريعة الإسلامية، لأنه قد تقدم أن الجريمة زنا وبالتالي تكون العقوبة في الشريعة الحد، فيرجم الزوج الذي باشر مثل هذه العلاقة، وينظر في حال الشريك فإن كان محصنا رجم أيضا وإلا جلد وغرّب على خلاف في التغريب.

أما البند (٢) من المادة ففيه بيان بأن العقوبة تقام بناء على دعوى أحد الزوجين، وهذا صحيح ولكن الموقف يحتاج إلى تفصيل، حيث قد سبق أن جريمة الزنا تثبت بالبينة أو بالإقرار، وعليه فإذا رفع أحد الزوجين دعوى على الآخر بارتكابه الزنا فإن عليه أن يأتي بالبينة على ما قاله وهي أربعة شهداء يشهدون له وفي حال عدم البينة تتم الملاعنة بينهما، فإن امتنع عن الملاعنة جلد

---

(١) سورة النور: الآية:٦.

حد القذف ومن هنا يمكن القول بأن هذا البند أيضا مخالف لما في الشريعة الإسلامية، من حيث عدم البيان والتفصيل في إجراءات رفع الدعوى من حيث البينات أو إقرار الجاني، والله تعالى أعلم.

وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كتميم أو بديل لصيغة بندي هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي:

١- كل شخص مرتبط بعلاقة زوجية منتجة لآثارها القانونية باشر علاقة جنسية (الزنا) مع غير زوجه يقام عليه حد الرجم، وتوقع نفس العقوبة على الشريك فى الجريمة إن كان محصنا أو الجلد والتغريب إن كان بكرا.

٢- تقام الدعوى فى الجريمة بناء على شكوى المجني عليه مع البينات أو الإقرار.

المطلب الرابع: المادة (٤٢٧) الزنا بالمحارم:

أولا: نص المادة:

١- كل من زنى بامرأة أو كل امرأة زنت بآخر محظور عليهما الزواج ببعضهما وفق قواعد الأحوال الشخصية يعاقب كل منهما بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عن خمس سنوات.

٢- تزداد العقوبة فى حالة وجود علاقات جنسية بالمحارم.

ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة:

هذه المادة نصت في بندها (١) على عقوبة كل رجل راتكب جريمة الزنا مع امرأة أو امرأة مع رجل محظور عليهما الزواج ببعضهما كالأصهار وحلائل الأبناء وغير ذلك وتكون العقوبة بالسجن ما بين السنتين والخمس سنوات، بينما في النبد (٢) بيان حكم الزناالخاصة بالمحارم بحيث تزداد العقوبة، وهنا ينبغي التعرض لأنواع المحارم فيقال:

المحارم ينقسمون إلى قسمين إما محرمات مؤبدة وإما محرمات مؤقتة، ويكون التحريم إما بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة، وعلى أية حال فإن قانون أحوال الشخصية الصومالي بين المحرمات كالآتي:

المادة ١٠ التحريم بسبب القرابة(النسب)

يحرم على الشخص الزواج بأصوله وفروعه وفروع والديه وفروع أجداده وفروع جداته من الدرجة الأولى.

المادة ١١ تحريم بسبب المصاهرة:

يحرم على الرجل بسبب المصاهرة الزواج:-

(أ) زوجة أحد أصوله.

(ب) زوجة أحد فروعه.

(ج) أصول زوجته.

(د) فروع زوجته إذا كان قد دخل بها دخولاً حقيقيًّا.

(هـــ) فروع من دخل بها دخولاً حقيقيًّا بعقد فاسد.

المادة ١٢ التحريم بسبب الرضاع:

١- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

٢- لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا تم إرضاع الطفل باللبن في السنتين الأوليين من حياته خمس رضعات مشبعات متفرقات.

أما المحرمات من ناحية الفقه الإسلامي

محرمات من النكاح هم:

من النسب سبعة:

١- الأم وإن علت. ٢-البنت وإن سفلت. ٣-الأخت. ٤-بنت الأخ. ٥-بنت الأخت. ٦-العمة. ٧-الخالة.

أما من الرضاع وهم سبع أيضا:

١- الأم من الرضاع، ٢-البنت من الرضاع، ٣-الأخت من الرضاع، ٤-بنت الأخ من الرضاع، ٥-بنت الأخت من الرضاع، ٦- العمة من الرضاع، ٧- الخالة من الرضاع

ومن جهة المصاهرة هم:

١- زوجة الأب وأن علا، ٢- زوجة الابن وإن سفل، ٣- أم الزوجة وإن علت، ٤- الربيبةوهي بنت الزوجة، ٥- وذوات الأزواج[١].

كما هو بين في قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾[٢].

---

(١) البغدادي، عبد الرحمن، **إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك**، ط:ثالثة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر ج:١ ص:٦٠.

(٢) سورة النساء: الآية:٢٣-٢٤.

وقد نصت المادة على أن الجريمة زنا حيث صدرت بـــ: "كل من زنى ...". وبعد هذا التحليل والتفصيل نعرض الحكم الذي ورد في القانون على الشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة.

ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة:

تقدم أن هذه الجريمة هي الزنا بالمحرمات أو المحارم، وقد اختلف العلماء في عقوبة الذي يزني بمحارمه على قولين:

القول الأول: من أتى ذات محرم فإنه يعامل معاملة الزاني:وبه قال الشافعي وهو أظهر قوليه وإحدى الروايتين عن أحمد.

قال الإمام المالك: الذي يزني بأمه الذي ولدته أو خالته أو عمته، إن كان ثيبا رجم، وإن كان بكرا جلد مائة وغرب عام[1].

واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴾ [2].

القول الثاني: من أتى ذات محرم يقتل مطلقا: وبه قال مالك، والشافعي في أحد قوليه ورواية عن أحمد.

قال الإمام أحمد: الزاني بذات محرمه أن حده رجم سواء أكان بكرا أم محصنا.

واستدل عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ))[1].

---

(١) مالك بن أنس، **المدونة**، ج٤ ص٤٨٣.

(٢) سورة النور، الآية:٢.

بعد عرض أقوال الفقهاء ترى الباحثة أن الرأي الراجح ما ذهب إليه القول الأول: وهو من أتى ذات محرم فإنه يعامل معاملة الزاني، يرجم إذا كان محصنا ويجلد ويغرب -عند من يقول به- إذا كان غير محصن.

وعندما ننظر إلى الحكم الذي ورد في الفقه الإسلامي نلاحظ أن هناك فرقا كبيرا بينه وبين القانون، حيث إن القانون يعاقب الزاني بالسجن فقط، وأقل ما يمكن أن يقال أن عقوبة الزاني ههنا الحد إما جلدا وإما رجما، وعليه فإن القانون خالف الشريعة الإسلامية في هذه المادة. والله تعالى أعلم.

وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كتميم أو بديل لصيغة بنود هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي:**كل من زنى بامرأة أو كل امرأة زنت بآخر محظور عليهما الزواج ببعضهما إما بالتأبيد أو بالتوقيت، وفق قواعد الأحوال الشخصية يقام عليه الحد رجما إن كان محصنا وجلدا وتغريبا إن كان بكرا.**

(١) الترمذي، سنن الترمذي، حديث رقم:١٤٦٢، ج٤، ص٦٢.

المبحث الثاني:جرائم غير الطبيعية ترتكب بالعنف:

المطلب الأول: المادة ٤٠٠

أولا: نص المادة

تزداد العقوبة في حالة ارتكاب الفعل من الأفعال المشار إليها فى المادتين ٣٩٨(١). و٣٩٩(٢). مع الشخص من نفس الجنس أو من جنس آخر بطريقة غير طبيعية.

ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في الفقه الإسلامي:

إن المادة ٤٠٠ ورد فيها حكم الجرائم غير الطبيعية، ويقصد بها قضاء الشهوة بطريقة مخالفة للفطرة السليمة سواء كان ذلك بالإيلاج أو بغيره، وقد اشتملت المادة على بيان نوع الجرائم غير الطبيعية، وبيان الظروف التي وقعت فيها الجريمة، وطبيعة هذه الجريمة. ولذلك سوف تتناول الباحثة كل ذلك بالتفصيل.

فأما نوع الجريمة، فقد أوضحت المادة نوعين وهما:

---

(١) المادة (٣٩٨) العنف الجنسي:

١- كل من واقع بالعنف أو بالتهديد يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين الخمس سنوات والخمسة عشر سنة.

٢- توقع نفس العقوبة على الشخص الذى يواقع أنثى ليست أهلا للرضا أو يواقع أنثىمدعيا أنه شخص آخر.

٣- توقع نفس العقوبة أيضا على كل الموظف عمومى أساء استعمال سلطته بأن زنى بأنثى قبض عليها أو عهد إليه بالتحفظ عليها بحكم وظيفته أو التنفيد الأمربشأنها صادر من السلطات المختصة.

٤- يعتبر عند التطبيق قانون العقوبات ولوج العضو الذكر جماعا جنسيا.

(٢) المادة (٣٩٩):كل من ارتكب مع أنثى مستعملا الوسائل المبينة في المادة السابقة أو متأثرا بطروفها فعلا من افعال الشهوة بخلاف الجماع الجنسى يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.

النوع الأول: أن يرتكب الشخص قضاء شهوته مع شخص آخر من جنسه كإتيان الرجلِ الرجلَ أو المرأة المرأةَ.

النوع الثاني: أن يرتكب الشخص قضاء شهوته مع شخص آخر من غير جنسه بطريقة غير طبيعية كإتيان الرجل المرأةَ في دبرها.

وأما الظروف التي وقعت فيها الجريمة فهي ثلاثة كما في المادة ٣٩٨.

الظرف الأول: استخدام القوة والعنف والتهديد.

الظرف الثاني: أخذ رضا من لا يعتد القانون برضاها، أو من يسهل خداع مثلها.

الظرف الثالث: استغلال السلطة.

وأما طبيعة الجريمة فهي أيضا قسمان هما:

القسم الأول: أن يحصل الإيلاج.

القسم الثاني: ألا يحصل الإيلاج بل مجرد قضاء الشهوة.

وعلى أية حال فإن كان قضاء الشهوة مع شخص آخر من جنسه وحصل فيه الإيلاج كإتيان الرجل الرجل أو مع غير جنسه بطريقة غير طبيعية كإتيان المرأة في دبرها سمي لواطا.

وإن كان قضاء الشهوة من غير إيلاج كإتيان المرأة المرأةَ سمي سحاقا.

وأما بقية الحالات فهي مخالفة للفطرة السليمة والطبع السليم في قضاء الشهوة.

وبذلك يتحصل لدينا تسعة أقسام:

القسم الأول: أن تكون الجريمة عن طريق العنف والتهديد مع شخص آخر من جنسه ويحصل فيه الإيلاج.

القسم الثاني: أن تكون الجريمة عن طريق العنف والتهديد مع شخص آخر من غير جنسه ويحصل فيه إيلاج في غير المحل الطبيعي.

القسم الثالث: أن تكون الجريمة عن طريق العنف والتهديد مع شخص آخر من جنسه ولا يحصل فيه الإيلاج.

القسم الرابع: أن تكون الجريمة مع شخص آخر من جنسه برضاه إلا أن رضاه لا يعتبر قانونيا أو يسهل خداع مثله ويحصل فيه الإيلاج.

القسم الخامس: أن تكون الجريمة مع شخص آخر من جنسه برضاه إلا أن رضاه لا يعتبر قانونيا أو يسهل خداع مثله ولا يحصل فيه الإيلاج.

القسم السادس: أن تكون الجريمة مع شخص آخر من غير جنسه برضاه إلا أن رضاه لا يعتبر قانونيا أو يسهل خداع مثله ويحصل فيه الإيلاج في غير المحل الطبيعي أو المعتاد.

القسم السابع: أن تكون الجريمة باستغلال السلطة مع شخص آخر من جنسه ويحصل فيه الإيلاج.

القسم الثامن: أن تكون الجريمة باستغلال السلطة مع شخص آخر من جنسه ولا يحصل فيه الإيلاج.

القسم التاسع: أن تكون الجريمة باستغلال السلطة مع شخص آخر من غير جنسه ويحصل فيه الإيلاج في غير المحل الطبيعي.

وبعد هذا التكييف نعرض العقوبة الواردة في المادة على الفقه الإسلامي لمعرفة الموافقة والمخالفة فنقول:

ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة:

إن العقوبة الواردة في القانون هي السجن المتضاعف لمن ارتكب شيئا من الجرائم المشار إليها في المادة ٤٠٠ من غير تفريق بين كل نوع، وإذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية نجد أن العقوبة المحددة في هذه الأنواع كلها عقوبة تعزيرية يمكن أن يتصرف فيها القاضي بزيادة أو نقصان وذلك بناء على ما سبق اختياره من أن اللواط لا يعتبر زنا وبالتالي لا حد على اللائط وإنما عليه التعزير، وعليه فيمكن القول بأن القانون من هذا الجانب لم يخالف الشريعة والفقه الإسلامي طالما ترك تحديد العقوبة التعزيرية إلى اجتهاد القاضي حسبما يراه مصلحة وطريقة لردع المجرم الأثيم وغيره. والله تعالى أعلم.

الخلاصة:

وبعد دراسة وتحليل المواد المتعلقة بهذا الفصل، وبيان التكييف الفقهي لنوع الجريمة الواردة في كل مادة، ومقارنتها بالشريعة الإسلامية لبيان الموافقة والمخالفة تبين ما يأتي:

أولا: أن هناك موادا خالفت العقوبات الواردة فيها الشريعة الإسلامية من جميع الجوانب و لم يمكن تخريجها بتاتا على أي مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة، وهذه المواد هي:

٤٢٦، ٤٢٧ و ٣٩٨:

المادة٤٢٦:

الجريمة التي وردت في المادة:

مباشرة علاقة جنسية مع غير الزوج.

العقوبة التي وردت في القانون:

السجن مدة أقصاها سنتان وتوقع نفس العقوبة علي الشريك فى الجريمة.

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف الجريمة الواردة في المادة على أنها جريمة زنا من متزوج أي محصن من طرف، ومن محصن أو بكر من طرف آخر.

نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:

فبعد المقارنة وجد أن القانون خالف الشريعة الإسلامية في حكمه على الجاني بالسجن بينما الشريعة توجب الحد على الجاني. والله تعالى أعلم.

المادة ٤٢٧:

الجريمة التي وردت في المادة:

وردت في المادة جريمة الزنا بالمحارم.

العقوبة التي وردت في القانون:

السجن مدة لاتقل عن سنتين ولا تتجاوز عن خمس سنوات.

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف الجريمة الواردة في المادة على أنها زنا بالمحارم.

نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:

فبعد المقارنة وجد أن القانون خالف الشريعة الإسلامية في حكمه على الجاني بالسجن، لأن الراجح أنالزاني بمحارمه يعامل معاملة الزاني مطلقا فيرجم المحصن ويجلد البكر ويغرب. والله تعالى أعلم.

المادة: ٣٩٨

الجريمة التي وردت في المادة:

وردت في المادة جريمة المواقعة بالعنف أو التهديدبأنثى ليست أهلا للرضا أو زنى موظف عمومي بأنثى قبض عليها.

العقوبة التي وردت في القانون:

السجن مدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة.

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف الجريمة الواردة في المادة على أنها الزنا.

نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:

فبعد المقارنة وجد أن القانون خالف الشريعة الإسلامية لأنالعقوبة المقررة لدى القانون في المواقعة هي السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة، يعني أن أقلها خمس سنوات، وأعلاها خمس عشرة سنة، والزنا تكون عقوبتها في الشريعة الإسلامية الرجم إن كان محصنا والجلد والتغريب –على خلاف في التغريب- إن كان بكرا.

ثانيا: أن هناك موادا وافقت العقوبات الواردة فيها الشريعة الإسلامية من أكثر الجوانب وذلك بعد عرضها على المذاهب الفقهية المعتمدة، وهذه المواد هي:

٣٩٩، ٤٠٠.

المادة: ٣٩٩.

الجريمة التي وردت في المادة:

وردت في المادة جريمة ارتكاب أفعال الشهوة بخلاف الجماع الجنسي.

العقوبة التي وردت في القانون:

السجن من سنة إلى خمس سنوات.

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف الجريمة الواردة في المادة على أنها سوء الأخلاق والإتيان بمقدمات الزنا.

نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:

فبعد المقارنة وجد أن القانون لم يخالف الشريعة الإسلامية في الحكم على الجانيبالسجن من سنة إلى خمس سنوات، حيث يمكن اعتبار العقوبة الواردة فيه (السجن) من باب التعزير، وهذا تقره الشريعة الإسلامية وتعطي صلاحية تحديد نوع العقوبة للحاكم أو القاضي ذلك لأن الشريعة تعاقب كل من خالف الآداب العامة بعقوبة تعزيرية من ضرب أو حبس أو فرض غرامة أو غير ذلك.

المادة: ٤٠٠

الجريمة التي وردة في الفقه الإسلامي:

جرائم غير الطبيعية ترتكب بالعنف:

ارتكاب الفاحشة مع شخص من نفس الجنس أو من جنس آخر بطريقة غير طبيعية.

العقوبة الواردة في القانون:

يضاعف السجن من سنة إلى خمس سنوات.

التكييف الفقهي للجريمة:

تم تكييف الجريمة الواردة في المادة بأنها إما لواط وإما سحاق.

نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:

في الشريعة الإسلامية نجد أن العقوبة المحددة في هذه الأنواع كلها عقوبة تعزيرية على الراجح.

وعليه فيمكن القول بأن القانون من هذا الجانب لم يخالف الشريعة والفقه الإسلامي طالما ترك تحديد العقوبة التعزيرية إلى اجتهاد القاضي حسبما يراه مصلحة وطريقة لردع المجرم الأثيم وغيره. والله تعالى أعلم.

النتائج والتوصيات:

وبعد هذه الرحلة العلمية التي تناولت في طيها دراسة وتحليل الجرائم وعقوباتها في نظام قانون العقوبات الجنائية لجمهورية الصومال الديموقراطية ومقارنة تلك العقوبات بالشريعة الإسلامية، وما تخلل ذلك من دراسة تاريخية لدولة الصومال فقد توصل البحث إلى عدد من النتائج تجملها الباحثة فيما يأتي:

أولا: على الرغم من كون الإسلام هو الدين الرسمي لجمهورية الصومال إلا أن نظام العقوقات الجنائية لم يكن مصدره الشريعة الإسلامية، وإنما أخذ من القانون الوضعي، ولذلك لم يرد فيه لفظ القصاص ولا الحد، وإنما ورد فيه لفظ الإعدام والعقاب بالسجن والغرامة المالية.

ثانيا: أن نظام العقوبات الجنائية لم يتعرض لتعريف القتل ولكنه قسم القتل إلى عمد وخطأ، فجعل القتل العمد هو ارتكاب القتل بشكل مباشر قاصد إيقاع القتل، وجعل القتل الخطأ ما عدا ذلك.

ثالثا: أن القانون جعل عقوبة من ارتكب القتل نظريا هي الإعدام، إلا أنه عند التطبيق ضيق دائرة الإعدام فحصره في حالات قليلة محددة وهي القتل العمد العدوان الخالي من الشبهة، والذي ارتكب ضد شخص قتل بغير رضاه، أو برضاه ولكن رضا مثله غير معتبر في القانون لصغره أو سفهه أو جنونه، أو أن رضاه جاء نتيجة الإكراه والاحتيال والخداع.

رابعا: خلا القانون مطلقا عن ذكر القصاص والحد، وسلطان ولي الدم، والدية والكفارة وغير ذلك، وإنما ذكر الإعدام، والعقوبات بالسجن أو الغرامة المالية أو هما معا.

خامسا: أن القانون لم يتعرض لتعريف السرقة مطلقا، ولذلك جاء في مواد السرقة ما لا يصدق عليه اسم السرقة عادة، كالغصب، والنهب، والخديعة، والاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وغير ذلك.

سادسا: أن القانون لم يقض بإقامة حد السرقة (قطع يد السارق) وتضمين الشيء المسروق على من ثبتت عليه السرقة، وإنما قضى بالسجن والغرامات المالية فقط.

سابعا: تعرض القانون لتعريف الزنا بأنه ولوج العضو الذكري جماعا جنسيا مما يدل على أنه حدد الزنا في إتيان المرأة في قبلها فقط، وأما ما عدا ذلك فجعله في قسم الجرائم غير الطبيعية أو سوء الخلق والأدب، فيكون تعريفه وعليه فيكون تعريف الزنا حسب القانون: إيلاج ذكر في قبل غير شرعي مطلقا وبغير رضا الطرف الآخر، أو برضا من لا يعتبر رضاها.

ثامنا: لم يوجب القانون حد الزنا (الجلد والتغريب للبكر، والرجم للمحصن) على الزاني، وإنما أوجب السجن فقط.

تاسعا: بلغ عدد المواد التي تم تناولها بالدراسة في جريمة القتل ٧، فكان عدد المواد التي وافق جزء منها الشريعة وخالف آخر ستا، كماوجدت مادة واحدة منها خالفت الشريعة مطلقا.

عاشرا: بلغ عدد المواد التي تم تناولها بالدراسة في جريمة السرقة ثلاثا، وافقت مادة واحدة منها الشريعة مطلقا، وخالفت مادة واحدة للشريعة مطلقا،كما أن هناك مادة أخرىوافق جزء منها الشريعة وخالف الجزء الآخر.

حادي عشر: بلغ عدد المواد التي تم تناولها بالدراسة في جريمة الزنا خمسا، فوجدت مادتان وافق جزء منهما الشريعة وخالف آخر، كما أن هناك ثلاث مواد خالفت الشريعة مطلقا.

وأخيرا توجه الباحثة النداء إلى الباحثين من أبناء دولة الصومال المتخصصين في مجال العلوم الإسلامية والقضاءوتوصيهم بضرورة الاهتمام بما تبقى من مواد القانون، وتناولها بالبحث والتحليل واقتراح البديل الشرعي لموادها المخالفة للشريعة بغية الوصول إلى إيجاد قانون للعقوبات الجنائية في الدولة يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ويحفظ الأرواح والحقوق، والأموال، والأعراض يكون مستمده من الشريعة الإسلامية.

وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

فهرس الآيات القرآنية:

الآية	اسم السورة	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾	البقرة	١٧٩	٣
﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ ﴾	إبراهيم	٧	٧
﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ﴾	النساء	٩٢	٤٣
﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾	النساء	٣٩	٤٣-٥٠
﴿ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴾	الإسراء	١٧	٤٩
﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾	المائدة	٤٥	٦٤
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ﴾	البقرة	١٧٨	٦٣
﴿ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾	الإسراء	٣٣	٦٤
فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ	البقرة	١٧٨	٦٥
فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ	المائدة	٤٥	٦٥

﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ﴾	المائدة	٣٣	٦٥
﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ وَأَحۡسِنُوٓاْۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴾	البقرة	١٩٥	٧١
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ﴾	النساء	٢٩	٧١
﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوۡمِي ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا ﴾	الفرقان	٣٠	٨٤
﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ﴾	المائدة	٣٨	٩٣
﴿ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾	المائدة	٣	١٢٣
﴿ وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعٗا مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ﴾	النساء	١٥	١٣٣-١٣٦-١٣٨-١٣٩-١٤٣
﴿ لِنُرۡسِلَ عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةٗ مِّن طِينٖ ﴾	الداريات	٣٣	١٣٤
﴿ وَلُوطًا إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦٓ إِنَّكُمۡ لَتَأۡتُونَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنۡ أَحَدٖ مِّنَ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴾	العنكبوت	٢٨	١٣٦

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾	الإسراء	٣٢	١٣٧
﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾	الفرقان	٦٨	١٣٧
﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ﴾	النساء	١٦	١٣٩
﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾	النور	٢	١٣٩-١٥٧
﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾	النساء	٢٣	١٥٦

فهرس الأحاديث والآثار:

الحديث أو الأثر	رقم الصفحة
لا يُصَلِّيَنَّ أَحدُكم وهو زَناءٌ	٣٩
ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل	٤٤
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخري بحجر، فقتلتها وما في بطنها،	٤٤
لايحل قتل امرئ مسلم يشهد أن لا أله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدي الثلاث	٥٠
أن رجلا من بني مدلجيقال له قتادة، حذف إبنه بسيف فأصاب ساقه فترى	٥٣
(ليس لقاتل ميراث)	٥٣
وإن في النفس مائة من الإبل	٥٥

في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة	٥٧
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاثة	٦٤
لا يقتل الوالد بالولد	٦٦-٦٧-٨٠
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده	٨٤
رفع القلم عن ثلاثة	٩٥
لا قطع فيما دون عشرة دراهم	٩٦
لم تكن اليد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه	٩٧
جاء رجلٌ فاستل بردتي من تحت رأسي،	١٢٠
لا قطع في عام سنة	١٢٤
خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا	١٤٠
والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله	١٤٠

المصادر والمراجع

أولا: المراجع العربية:

١. ابن الأثير، مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد، **النهاية في غريب الحديث والأثر**، تحقيق: طاهر أحمد-محمود الطناحي، مكتبة العلمية –بيروت ١٣٩٩ه-١٩٧٩م.

٢. ابن المفلح برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن عبد الله، **المبدع في شرح المقنع**، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان،ط الأولى:١٤١٨ه،١٩٩٧م.

٣. ابن المفلح شمس الدين،محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، **الفروع**، تحقيق: عبد الله ابن محسن التركي، مؤسسة الرسالة،ط الأولى:١٤٢٤ه-٢٠٠٣م.

٤. ابن الهمام كمال الدين،محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد، **فتح القدير**، دار الفكر.

٥. ابن تيمية تقي الدين،أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، **السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية**، ط:الاولى ١٤١٨ه، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية،

٦. ابن جزي الكلبي، محمد بن محمد بن أحمد، **القوانين الفقهية**.

٧. ابن حجرالعسقلاني، أحمد بن علي، **الدراية في تخريج أحاديث الهداية**، دار المعرفة-بيروت.

٨. ابن حجر العسقلاني، أحمدبن علي، **فتح الباري شرح صحيح البخاري**، دار المعرفة-بيروت، ١٣٧٩.

٩. ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، **المحلى بالآثار**، دار الفكر-بيروت.

١٠. ابن رشد الحفيد، أبو الوليد، **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**، ط:بدون، دار الحديث القاهرة، ١٤٢٥ه-٢٠٠٤م

١١. ابن عابدين، محمد أمين، **رد المحتار على در المختار**، ط:الثانية ١٤١٢ه-١٩٩٢م، دار الفكر-بيروت.

١٢. ابن عبد البرأبو عمر،يوسف بن عبد الله بن محمد، **الاستذكار**، تحقيق سالم محمد عطا، دار الكتب العلمية-بيروت، ط:الأولى١٤٢١ه- ٢٠٠٠م .

١٣. ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، **الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب**، تحقيق: محمد الأحمدي دار التراث للطبع والنشر القاهرة.

١٤. ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، **تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام**، ط:الاولى ١٤٠٦ه-١٩٨٦م ،مكتبة الكليات الأزهرية.

١٥. ابن كثير أبو الفداء، إسماعيل بن عمر، **البداية والنهاية**، الطبعة الأولي: ١٤٠٨ه-١٩٨٨م.

١٦. ابن كثير أبو الفداء، إسماعيل بن عمر، **تفسير القرآن العظيم**، ط١، مؤسسة القرطبة، مصر، سنة١٤٢١ه-٢٠٠٠ م.

١٧. ابن ماجه، أبو عبد الله، محمد بن يزيد، **سنن إبن ماحه**، تحقيق محمد فؤاد دار إحياء الكتب العلمية.

١٨. ابن منذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، **الإقناع لابن المنذر**، التحقق: دكتور عبد الله ابن عبد العزيز الجبرين، ط الأولى: ١٤٠٨ه.

١٩. ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، **لسان العرب**، ط:٣(١٤١٤)، النشر: دارالصادر بيروت.

٢٠. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،**الأشباه والنظائر**، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط الأولى:١٤١٩ه-١٩٩٩م.

٢١. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، **البحر الرائق شرح كتر الدقائق**، دار الكتاب الإسلامي، ط الثانية.

٢٢. ابن هبيرة أبو المظفر، يحيى، **اختلاف الأئمة العلماء**، تحقيق، السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية- لبنان- بيروت.

٢٣. أحمد جمعالي محمد، **مملكة أوفات الإسلامية في منطقة القرن الإفريقي وآثارها الحضارية**، رسالة ماجستير (غير منشورة) جامعة أمدرمان الإسلامية ١٩٨٥م.

٢٤. أحمد عبد الله ريراش، **كشف السدول عن تاريخ الصومال وممالكها السبعة**.

٢٥. الأعظمي، محمدضياء الرحمن، **المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى**، مكتبة الرشد-سعوذية- رياض،سنة:١٤٢٢ه-٢٠٠١م.

٢٦. الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد، **الأحكام في أصول الأحكام**، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتبة الإسلامي، بيروت-دمشق- لبنان.

٢٧. البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، **العناية شرح الهداية**، دار الفكر.

٢٨. الباجي، أبو الوليد، سليمان بن خلف، **المنتقى شرح الموطأ**، طبعة الأولى، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر.

٢٩. البخاري، محمد بن إسماعيل، **صحيح البخاري**، تحقيق محمد زهير، دار طرق النجاة، ط: الأولى ١٤٢٢ه.

٣٠. بدر الدين العيني، أبو محمد محمود بن أحمد، **عمدة القاري شرح صحيح البخاري**، دار إحياء التراث العربي بيروت.

٣١. البغدادي، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر، **إرشادالسالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك**،

ط: الثالثة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر.

٣٢. بلال، أحمدعوض،**النظرية العامة للجزاء الجنائي**، ط: الأولى، نشر: دار النهضة العربية، ١٩٠٥.

٣٣. بهاء الدين، عبد الرحمنبن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد، **العدة شرح العمدة**، دار الحديث- القاهرة، ١٤٢٤ه-٢٠٠٣م.

٣٤. البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، **كشاف القناع عن متن الإقناع**، دار الكتب العلمية.

٣٥. البيهقي، علاء الدين، **الجواهر النقي على سنن البيهقي**، دار الفكر.

٣٦. الترمذي، محمد بن عيسى بن سؤرة، **الجامع الكبير-سنن الترمذي**، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي-بيروت ١٩٩٨.

٣٧. التسولي، علي بن عبد السلام أبو الحسن، **البهجة في شرح التحفة**، تحقيق:محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية-لبنان- بيروت، ١٤١٨ه-١٩٩٨م، ط:الأولى.

٣٨. الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، **التعريفات**، دار الكتب-بيروت، ط الأولى١٤٠٣ه١٩٨٣م.

٣٩. الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى، **الإقناع في فقه الإمام احمد بن الحنبل**، دار المعرفة بيروت-لبنان.

٤٠. الحدادي، أبو بكر بن علي بن محمد، **الجوهرة النيرة**، ط الأولى:١٣٢٢، المطبعة الخيرية.

٤١. حسن محمد جوهر، **الصومال، سلسلة شعوب العالم** العدد ١٧،(القاهرة، ١٩٦٥).

٤٢. حسن، يوسف علي، الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد وأجزيتها المقررة في الفقه الإسلامي، دار الفكر.

٤٣. الحميدي، محمد بن الفتوح بن عبد الله، **الجمع بين الصحيحين-بخاري ومسلم**، تحقيق: علي ابن حسن البواب، دار ابن الحزم-لبنان، بيروت، ط الثانية:١٤٢٣ه-٢٠٠٢م.

٤٤. الخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله، **متن الخرقى على مذهب أبي عبد الله أحمد ابن حنبل الشيباني**، ط:١٤١٣ه،١٩٩٣م، دار الصحابة للتراث.

٤٥. الخليلي، حبيب إبراهيم، **مدخل للعلوم القانونية**.

٤٦. داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، **مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر**،ط:بدون، دار أحياء التراث العربي-بيروت لبنان.

٤٧. دستور الصومالي لسنة ١٩٧٩.

٤٨. الدسوقي، محمد ابن أحمد بن عرفه،**شرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي**، دار القكر.

٤٩. الرازي، زينا لدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، **مختار الصحاح**، محقق: يوسف شيخ محمد، المكتبة

العصرية دار النموذجية، بيروت- صيدا، ط: الخامسة ١٤٢٠ه، ١٩٩٩م،

٥٠. الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي، **مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى**، ط: الثانية ١٤١٥ه-١٩٩٤م النشر: المكتب الإسلامي.

٥١. الرصاع، محمد بن قاسم الأنصاري أبو عبد الله، **شرح حدود ابن عرفة**، مكتبة العلمية،ط:الأولى، ١٣٥٠ه.

٥٢. الرعيني، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، **مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل**، ط الثانية،١٤١٢ه-١٩٩٢، دار الفكر.

٥٣. الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس، **نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج**، دار الفكر، بيروت، ط أخيره، ١٤٠٤ه-١٩٨٤.

٥٤. الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي، **الأعلام**، دارالعلم للملايين، ط:خامسة عشر أيار/مايو٢٠٠٢م.

٥٥. الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف، **نصب الراية لآحاديث الهداية**، تحقيق: محمد عوامه، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت-لبنان،/دار القبلة للثقافة الإسلامية، جده-السعودية، ط الأولى:١٤١٨ه-١٩٩٧م.

٥٦. الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن، **تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي**، المطبعة الكبرى الأميرية بولاق، مصر، ط:الأولى١٣١٣ه.

٥٧. السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين،**طبقات الشافعية الكبرى**، تحقيق: د.محمود الطناحي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط الأولى: الثانية ١٤١٣ه.

٥٨. السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق، **سنن أبي داود**، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة العصرية،صيدا-بيروت.

٥٩. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، **المبسوط**، ط:بدون، دار المعرفة-بيروت، ١٤١٤ه-١٩٩٣م.

٦٠. السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر علاء الدين، **تحفة الفقهاء**، ط:الثانية،١٤١٤ه-١٩٩٤م دار الكتب العلمية بيروت- لبنان.

٦١. الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس،**الأم**، ط الثانية:دار المعرفة بيروت ٢٠٤ه-٨٢٢م، سنة النشر:١٣٩٣ه.

٦٢. الشافعي، محمد ابن إدريس بن العباس، **المسند** ، دار الكتب العلمية-بيروت، ١٤٠٠م.

٦٣. الشربيني، الخطيب، **مغني المحتاج إلى معرفة الألفاظ**، دار الكتب العلمية، ط الأولى: ١٤١٥م-

.١٩٩٤

٦٤. الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد، **مغني المحتاج إلي معرفة معاني الألفاظ المنهاج**، ط:الأولى١٤١٥ه-١٩٩٤م دار الكتب العلمية.

٦٥. الشعراوي، محمد متولي، **تفسير الشعراوي**، مطابع أخبار اليوم.

٦٦. الشنقيطي، محمد الأمين بن المختار بن عبد القادر، **مذكرة في أصول الفقه**، مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة، ط الخامسة: ٢٠٠١م.

٦٧. الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، **بلغة السالك لأقرب المسالك بحاشية الصاوي على الشرح الصغير**، دار المعارف.

٦٨. صلاح العقاد وجمال زكريا ، **زنجبار** ، سلسلة ألف كتاب العدد ٢٩٩ ، القاهرة ، ١٩٥٩م مكتبة الأنجلو المصرية .

٦٩. الصنعاني، محمد ابن إسماعيل بن سلاح بن محمد الحسني، **سبل السلام**، دار الحديث.

٧٠. الطبري، محمد بن حرير بن يزيد بن كثير، **تهذيب الآثار مسند بن عباس**، المحقق: محمد شاكر، مطبغة المدني- القاهرة.

٧١. الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك، **شرح معاني الآثار**، طبعة: الأولى، ١٤١٤ه- ١٩٩٤م، عالم الكتب.

٧٢. عبد القادر القرشي عبد القادر بن محمد بن نصر الله، **الجواهر المضية في طبقات الحنفية**، مير محمد كتب خانه- كراتش.

٧٣. عبد القادر عودة، **التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي**، دار الكاتب العربي، بيروت.

٧٤. عبد المنعم عبد الحليم ، **الجمهورية الصومالية الإقليم الجنوبي**.

٧٥. العسكري، أبو الهلال حسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد، **الفروق اللغوية**، محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع- القاهرة، مصر.

٧٦. عليش، محمدبن أحمد بن محمد، **منح الجليل شرح مختصر خليل**، دار الفكر-بيروت، تاريخ: ١٤٠٩ه،١٩٨٩م.

٧٧. الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، **الوسيط في المذهب**، تحقيق:أحمد محمود، دار السلام- القاهرة، ط الأولى: ١٤١٧.

٧٨. فيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن بعقوب، **القاموس المحيط**، تحقيق: مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي،ط الثامنة،١٤٢٦ه-٢٠٠٥م، بيروت لبنان.

٧٩. الفيومي،أحمد بن محمد بن علي، **مصباح المنير في غريب شرح الكبير**، مكتبة العلمية –بيروت.

٨٠. القاضي عبد الوهاب، أبو محمد عبد الوهاب بن علي، **التلقين في الفقه المالكي**، تحقيق: أبي أويس، محمد، دار الكتب العلمية، ط الأولى:١٤٢٥ه-٢٠٠٤م

٨١. **قانون العقوبات لجمهورية الصومال الديمقراطية** لسنة ١٩٧٠، طبعة: بمعرفة مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع

٨٢. القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، **الذخيرة**، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي –بيروت، ط الأولى: ١٩٩٤م.

٨٣. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر، **الجامع لأحكامالقرآن**، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية- القاهرة، ط الثانية:١٣٨٤ه، ١٩٦٤م.

٨٤. الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن أحمد بن مسعود، **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، طبعة:الثانية، ١٤٠٦ه-١٩٨٦م دار الكتب العلمية.

٨٥. الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن حسن أبو الخطاب، **الهداية على مذهب الإمام أحمد**، تحقيق: عبد اللطيف وماهر ياسين، موسسة الغراس للنشروالتوزيع، ط الأولى: ١٤٢٥ه-٢٠٠٤م.

٨٦. مالك، ابن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، **المدونة**: ط:الأولى،١٤١٥ه-١٩٩٤م، دار الكتب العلمية

٨٧. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بمن محمد بن حبيب، **الحاوي في فقه الشافعي**، تحقيق، الشيخ علي، دار الكتب العلمية بيروت، ط الأولى: ١٤١٩ه-١٩٩٩م.

٨٨. مجموعة من المؤلفين: إبراهيم مصطفى، احمد زياد، حامد عبد القادر، محمد، **المعجم الوسيط**، النجار، دار الدعوة.

٨٩. المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد، **تفسير الجلالين**، ط:الأولى دار الحديث-القاهرة.

٩٠. محمد أحمد، شيخ علي، **القبائل الصومالية، الأصل، والبناء، والوظيفة**.

٩١. محمد حاج مختار ، **تاريخ الاستعمار الإيطالي في الصومال**.

٩٢. محمود محمد حسن، **الذهب الأسود في الصومال**، مركز الشاهد للبحوث والدراسات الإعلامية،

٩٣. المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، **الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف**،ط:ثانيةب، مطبعة دار إحياء التراث العربي.

٩٤. المرغيناني، علي ابن أبي بكر بن عبد الجليل، **الهداية في شرح بداية المبتدي**، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياءتراث العربي- بيروت- لبنان.

٩٥. مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري، **صحيح مسلم**، تحقيق محمد فؤاد، دار إحياء التراث العربي- بيروت.

٩٦. المقدسي، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة، **الشرح الكبير على متن المقنع**، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ط: بدون.

٩٧. المناوي، زين الدبن محمد المدعوبعبد الرؤوف بن تاج، **التوقيف على مهمات التعاريف**، تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية، ط١ دار الفكر بيروت، ١٤١٠هـ

٩٨. المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري، **التاج والإكليل لمختصر خليل**، دار الكتب العلمية، ط الاولى: ١٤١٦ه-١٩٩٤م.

٩٩. النفراوي، أحمد بن غانم بن سالم بن مهنا شهاب الدين، **الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني**، دار الفكر، ١٤١٥ه، ١٩٩٥م.

١٠٠. النووي، أبوزكريا محي الدين يحيى بن شرف، **المنهاج شرح صحيح المسلم بن الحجاج**، ط: الثانية،١٣٩٢، دار إحياء التراث العربي.

١٠١. النووي، أبو زكرياء، محي الدين يحيى بن شرف،**المجموع شرح المهذب**، دار الفكر.

١٠٢. النووي، أبو زكرياء، محي الدين يحيى بن شرف، **روضة الطالبين وعمدة المفتين**، المكتبة الإسلامي-بيروت-دمشق-عمان، ط الثالثة: ١٤١٢ه-١٩٩١م.

١٠٣. الهمشري، محمد علي، **انتشار الإسلام في إفريقيا**، ط: الأولى:١٤١٨ه١٩٩٧م، مكتبة العبيكان-الرياض.

ثانيا: المراجع الأجنبية:

1. Lewis, I.M, Understanding Somalia, Haan Associates London , 1993), P.16(

2. Touval op . cit , p.10.

3. Burton , Richard , , First Foot Steps in Africa ,(London 1966), p. 87

4. Cabdulqaadir Salaad Dhoorre, Soomaaliya iyo Taariikhdeedii Hore, P.22

ثالثا: المراجع الإلكترونية:

1http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A

2- http://www.afran.ir/ar/modules/publisher/item.php?itemid=363.